

目 录

法理学	1
第一章 绪论	1
第一节 法学	1
第二节 法理学	4
第二章 法的特征与本质	5
第一节 法的概述	5
第二节 法的基本特征（范遍权义，国威程强）	6
第三节 法的本质	7
第三章 法的起源与演进	8
第一节 法的起源	8
第二节 法的演进	9
第三节 法律全球化	12
第四章 法的作用与法的价值	13
第一节 法的作用	13
第二节 法的价值	16
第五章 法的渊源、效力与分类	21
第一节 法的渊源	21
第二节 法的效力	24
第三节 法的分类	25
第六章 法律要素与法律体系	26
第一节 法律要素	26
第二节 法律体系与法律部门	29
第三节 当代中国的法律体系	31
第七章 立法	36
第一节 立法概述	36
第二节 立法原则	37
第三节 立法程序	38
第八章 法律实施	39
第一节 法律实施概述	39
第二节 执法	40
第三节 司法	42
第四节 守法	45
第五节 法律监督	47

第九章 法律职业与法律方法	48
第一节 法律职业	48
第二节 法律职业伦理	50
第三节 法律解释	51
第四节 法律推理与论证	54
第十章 法律关系	56
第一节 法律关系概述	56
第二节 法律关系的构成要素	57
第三节 法律关系的产生、变更与消灭	60
第十一章 法律责任与法律制裁	61
第一节 法律责任	61
第二节 法律制裁	63
第十二章 法治	64
第一节 法治概述	64
第二节 习近平法治思想与全面依法治国	68
第十三章 法与社会	74
第一节 法与社会的一般关系	74
第二节 法与经济	77
第三节 法与政治	78
第四节 法与文化	80

法理学

第一章 绪论

第一节 法学

一、法学的概念

►法学的含义；法学的研究对象；法学体系

【分析】法学又称法律科学，是一门以法（或法律）这一社会现象及其规律为研究对象的**人文社会科学**。

法学首先是一门科学。科学作为一个普遍性的概念，用于指称人类的一种专门性研究活动和知识，而不仅仅以自然科学作为唯一的存在方式与判断标准。

人类迄今为止拥有的知识，按照构成和存在方式的不同，大致可以归结为三种不同形态，即有关社会的、有关人文的和有关自然的各种知识门类。因此，按照这种对知识形态的概括，人们一般将科学划分为社会科学、人文科学和自然科学。在这一分类标准下，法学是介于社会科学和人文科学之间的知识形态。法学以法律现象为研究对象，考察法的产生、发展及其规律，研究各种法律规范、法律制度的性质、特点及其相互关系，研究法的内部联系和调整机制，研究法与其他社会现象的联系、区别及相互作用，因此具有社会科学的性质；同时，法律又是人们生活意义的规则体现，法学要解决不同民族不同国度人们所面临的问题，要为人们在规则下生活提供精神导向，因此又具有人文科学的性质。

法学体系是一个由互不相同但又有联系的分支学科构成的知识系统。法律调整的社会关系是多种多样的，因而研究社会的各种法律现象及其发展规律的法学所研究的范围也就十分广泛，从而形成若干分支学科。这些分支学科所构成的一个有机联系的知识系统就是法学体系。我们可以从不同的角度划分法学的分支学科，比如，从法律的制定到法律的实施这一角度，法学可以分为立法学、执法学、司法学、监察法学等；从认识论角度，法学可以分为理论法学和应用法学；从法学和其他学科的关系这一角度，法学可以分为法教义学和法学交叉学科。

二、法学的产生和发展

►法学产生的条件；法学的历史发展

【分析】法学是以法或法律现象为研究对象的科学。社会有了法或法律现象，就有了关于这些现象的思想、观点，但**不是一有了法就有了法学，法学是在法发展到一定阶段时才产生的**。法学的产生至少应当具备两个方面的条件：**首先，要有关于法律现象的材料的一定积累；其次，要有专门从事研究法律现象的学者阶层的出现**。恩格斯在《论住宅问题》中谈到法学的产生时指出，随着立法发展为复杂和广泛的整体，出现了新的社会分工的必要性：一个职业法学者阶层形成起来了，同时也就产生了法学。

在中国，法学在春秋战国时期就有了相当的发展，出现了**儒、法、道、墨**（**删改：法家、儒家**）等许多直接或间接探讨法律问题的学派。在西汉中期以后两千多年的封建社会中，儒家的法律思想一直占统治地位，法学衰微。鸦片战争以后，法学领域开始传入一些西方的法律思想。

在西方，法学最早起源于古希腊，到**古罗马共和国时期，法学已发展成为一门独立的学科**，出现了法学派别，编写了法学著作。中世纪欧洲，法学成为神学的一个分支。12世纪至16世纪是罗马法的复兴时期，出现了**以研究和恢复罗马法为核心的新的法学，主要是意大利的注释法学派**。17世纪至18世纪资产阶级革命时期，代表新兴的资产阶级政治、经济要求的思想家们提出了许多重要的法律思想、理论和学说。之后，为了适应资

本主义发展的需要，出现了许多资产阶级法学流派，其中主要有自然法学派、分析法学派、社会法学派等。它们为法学研究积累了大量的资料，提供了不少有价值的、合理的理论观点。

三、西方主要法学流派

►自然法学派；分析法学派；社会法学派；其他法学流派

【分析】自然法学派、分析法学派和社会法学派是现代西方影响较大、占统治地位的法学流派，称为三大法学流派。他们的法学理论，是西方人在探索真理过程中留下的足迹，对我们认识人类法的发展历程、规律及本质，具有非常重要的意义。

自然法学派。自然法学派是一个拥有悠久历史的法学流派。其中，尤以 17 世纪至 18 世纪的古典自然法学影响最大。这个时期的自然法学充分体现了自然法、自然权利与社会契约等人本主义法律观，**崇尚自由平等，主张天赋人权、恶法非法。主张法是人的理性，强调自然法普遍永恒，且高于人定法，人定法符合自然法时才是真正的法律。**近代自然法学派的代表人物有**洛克、孟德斯鸠和卢梭**；现代的新自然法学派代表人物则有**富勒、罗尔斯和德沃金**。

分析法学派。分析法学派是 19 世纪产生的学派，以实证主义哲学为基础，反对形而上学的思辨方式和寻求终极原理的做法，反对超越现行法律制度的任何企图，主张**恶法亦法**，它试图将价值考虑排除在法理学科学研究的范围之外，并把法理学的任务限定在分析和剖析实在法律制度的范围内。早期代表人物有**边沁、奥斯丁**；20 世纪分析法学派代表人物则有**凯尔森、哈特**等。

社会法学派。社会法学派起源于 19 世纪后半期的欧洲，盛于 20 世纪西方各国。该学派的主要代表人物是奥地利的**埃尔利希**，系统地在美国阐述这一学派观点的是**霍姆斯和庞德**。社会法学派**强调研究“现实的法”，研究法律现实的各个方面，反对分析法学派仅仅对法律进行形式逻辑上的研究。他们对于法律的来源、性质和作用的论述，着重于宣扬法的社会性。**法国**狄骥**的社会连带主义法学也是社会法学派的重要一支，强调从社会连带关系的角度研究法律相关问题。

其他法学流派中，影响较大的有 19 世纪的**历史法学派、哲理法学派**；20 世纪的**经济分析法学派、女权主义法学派**等。到 20 世纪末，还出现了以批判法学、法律与文学运动为代表的后现代法学思潮。

四、马克思主义法学

►马克思主义法学的产生与发展；马克思主义法学的特征；坚持用马克思主义的立场观点方法研究法学

【分析】马克思主义法学的形成经历了一个辩证的过程。马克思于 1835 年 10 月至 1841 年 3 月先后在德国波恩大学和柏林大学法律系学习，接受了当时欧洲最好的法律教育。**马克思法学思想的最初出发点是康德法学和黑格尔派的理性主义法学。**马克思在学生时代就自觉地从理想主义转向现实本身去寻找法的观念。从马克思的论述中可以看出，他认为法的内容决定法的形式，而内容来自事物本身的理性。马克思在从事新闻出版工作时期撰写了几篇政论文章，进一步发扬了理性主义法律观。他认为，法律是自由的肯定存在，法典是人民自由的圣经。1843 年夏秋之际，马克思撰写了《**黑格尔法哲学批判**》，他在批判黑格尔理性主义法律观的过程中初步**指明了历史唯物主义法学的基本方向。**他的研究得出这样一个结果：法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反地，它们根源于物质的生活关系。1845 年 9 月到 1846 年年初，马克思和恩格斯在《**德意志意识形态**》一书中，**较为完整系统地表达了他们的唯物主义法律观。**他们认为，法律是作为国家权力基础的其他关系的一种标志和表现。1848 年问世的《**共产党宣言**》是**历史唯物主义法学的纲领性文件。**马克思和恩格斯在批判资产阶级的谬论时指出，资产阶级的法不过是被奉为法律的资产阶级意志，而这种意志的内容是由资产阶级的物质生活条件来决定的。马克思主义的唯物主义法律观

在《资本论》中得到进一步的论证和集中的体现，他认为法的关系是一种反映着经济关系的意志关系。这种法的关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。马克思逝世后，恩格斯勇敢地捍卫了马克思的思想学说，并且根据新的历史条件，先后完成了《论住宅问题》《家庭、私有制和国家的起源》《反杜林论》等著述，从而推进了马克思主义法学的新发展。

列宁在《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人？》等著作中深刻阐述了历史唯物主义法律思想的基本原理，不仅坚持了马克思主义法律观，而且丰富了历史唯物主义社会哲学与法哲学的理论内容。列宁认为，对政治法律形式的说明要到物质生活关系中去寻找，人民的利益是最高的法律。

（删减：马克思主义对法律社会学、自然法学、分析法学、批判法学、女性主义法学、后现代法学、种族批判法学、法律地理学等当代法学流派产生了或多或少的影响。）马克思主义法学具有实践性、批判性、人文性和历史性的主要特征。第一，马克思主义法学的实践性。马克思主义法学创立了实践本位论的法律观。马克思将法律的基础从概念天国拉回到人类生活，从社会意识拉回到社会实践。法律的产生和发展离不开实践，法律是人类实践的产物。第二，马克思主义法学的人文性。马克思主义法学是西方人文主义法律思想的继承者，人的解放问题是马克思主义法学关注的中心问题。马克思主义法学关注的不是抽象的人，而是现实的具体的人。在马克思的学说中，法律也是实现人的解放的一种方式，人的解放的实现离不开法律。第三，马克思主义法学的批判性。马克思主义法学是在批判资本主义法律制度的过程中产生的。马克思主义法学运用阶级分析方法揭示了资本主义法律的实质。第四，马克思主义法学的历史性。马克思主义法学强调法律和权利的时间性和空间性。法律和权利不是超历史的抽象存在物，而是与一定的历史阶段和经济发展水平联系在一起的具体存在物。

坚持用马克思主义的立场观点方法研究法学。坚持以马克思主义为指导，是当代中国法学区别于其他法学的根本标志，必须旗帜鲜明地加以坚持。马克思主义深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律，为人类社会发展进步指明了方向。就法学而言，马克思主义揭示了法律发展的普遍规律，为法学和法治发展指明了方向。马克思主义坚持实现人民解放、维护人民利益的立场，以实现人的自由而全面的发展和全人类解放为己任，反映了人类对理想社会的美好憧憬。马克思主义认为，实现人的解放是法律的价值追求，法律致力于实现人的自由、平等、独立和尊严。马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律，是“伟大的认识工具”，是人们观察世界、分析问题的有力思想武器。马克思主义提出的历史唯物主义和辩证唯物主义是法学研究最根本的方法论。马克思主义具有鲜明的实践品格，不仅致力于科学地“解释世界”，而且致力于积极地“改变世界”。法学是一门经世致用之学，马克思主义的实践观是研究法学实践性认识的重要认识论。

►马克思主义法学中国化的历史进程

【分析】20世纪马克思主义在中国获得广泛传播和深入发展。中国共产党把马克思主义的普遍原理与中国实际相结合，形成了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。这些思想都包含着丰富而深刻的法治理论，尤其是习近平法治思想实现了马克思主义法治思想新的历史性飞跃和中国特色社会主义法治理论的系统性创新发展。

第一，毛泽东思想的法治理论。这主要体现在两个大的方面，一是系统地提出了关于新中国国体和政体的学说；二是提出了社会主义法制的基本思想。其中，关于国家学说的思想散见于《新民主主义论》《论政策》《论人民民主专政》《关于中华人民共和国宪法草案》等论著中。关于国体，毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出：“总结我们的经验，集中到一点，就是工人阶级（经过共产党）领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。”关于政体，毛泽东在《新民主主义论》中指出：“那是指的政权构成的形式问题，指的一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。”国体决定政体，政体体现国体。我国的政体是人民代表大会制度，它是我国的根本政治制度。在社会主义法制理论方面，毛泽东特别强调要从新民主主义革命的实际出发建设新民主主义法制，强调革命的法律应体现阶级性和人民性的统一，并提出了一系列重要的法律思想、法律原则和

法律制度，其中有：坚持原则性和灵活性相结合的立法思想；坚持有法可依、有法必依的法制原则，强调“依法办事是进一步加强法制的中心环节”；坚持“公民在法律面前人人平等”原则；坚持以事实为根据、以法律为准绳的诉讼原则等。

第二，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的法治理论。以1978年12月召开的党的十一届三中全会为标志，中国进入了改革开放的新时期，开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论。中国特色社会主义理论体系适应改革开放和社会主义现代化建设新时期、新形势、新任务的要求，提出了一系列具有重要战略意义的民主法制思想，确立了依法治国基本方略、依法执政基本方式，提出了建设社会主义法治国家的历史任务。在这个过程中，邓小平理论创立了中国特色社会主义法治理论；“三个代表”重要思想、科学发展观丰富和发展了中国特色社会主义法治理论，初步形成了中国特色社会主义法治理论体系。其中，重要的理论观点包括：一是要发展社会主义民主，就必须加强社会主义法制；二是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一；三是坚持科学执政、民主执政、依法执政；四是扩大人民民主，保证人民当家作主；五是坚持以人为本，尊重和保障人权；六是坚持中国特色社会主义政治发展道路。

第三，习近平法治思想。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从坚持和发展中国特色社会主义的全局和战略高度定位法治、布局法治、厉行法治，创造性提出了（删减：一系列）关于全面依法治国新理念新思想新战略，形成了（删减：创立了）习近平法治思想，开启了马克思主义法学中国化新的历史进程。习近平法治思想内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备，其基本精神和核心要义集中体现为“十一个坚持”，即：坚持党对全面依法治国的领导；坚持以人民为中心；坚持中国特色社会主义法治道路；坚持依宪治国、依宪执政；坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化；坚持建设中国特色社会主义法治体系；坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设；坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；坚持统筹推进国内法治和涉外法治；坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍；坚持抓住领导干部这个“关键少数”。

第二节 法理学

一、法理学的概念

►法理学的含义；法理学的研究对象；法理学在法学体系中的地位

【分析】法理学是我国法学体系中的一门重要的理论法学学科。它是从总体上研究法和法律现象的一般规律，研究法的产生、本质、特征、作用、形式、发展、实施等基本知识、概念和原理，研究法的创制和实施的一般理论，并着重研究我国社会主义法和法治的基本理论问题的理论学科。

法理学的研究对象是一般意义上的法，是法和全部法律现象及其规律性。一般意义上的法首先是指法的整个领域或者说整个法律现实，包括所有部门法在内的整个法律领域，以及现行法从制定到实施的全部过程。一般意义上的法还可以指古今中外一切的法。法理学要对古今中外一切类型的法律制度及其各个发展阶段的情况进行综合研究，它的研究结论应能解释法的一切现象。

法理学要概括出各个部门法及其运行的共同规律、共同特征、共同范畴，从而为部门法学提供指南，为法治建设提供理论服务。如同任何国家的法理学都是以本国的现行法律为主要研究对象一样，我国的法理学也是以研究我国的法律问题和法治建设为主，其研究起点、重心和归宿都是建设有中国特色的社会主义法治国家。

法理学在法学体系中占有特殊的地位，它是法学的一般理论、基础理论和方法论。法理学与部门法学之间是“一般”与“特殊”的关系。法理学的材料来源是通过对所有部门法材料进行高度抽象概括来获得的，所以法理学既提供了研究部门法学的立场、观点和方法，同时它所阐述的基本概念、基本原理和基本知识，对部门

法学的研究又具有指导意义。法理学与法律史学的关系是“论”与“史”的关系。法理学的一般概念、定义和原理都是从法律史及部门法提供的材料中抽象概括出来的，没有科学的法律史学的发展，就没有科学的法理学的发展。同时，法律史学的研究又需要以法理学阐明的理论和方法论为指导。法理学把对法律现象的哲学的研究、社会学的研究和专门法律的研究方法结合起来，从不同角度阐明法律现象的共同问题。因此，法理学在整个法学体系中占有非常重要的地位。

二、法理学的研究方法和意义

►法理学的研究方法；研究法理学的意义

【分析】马克思主义的哲学方法，即辩证唯物主义和历史唯物主义的方法是法学研究的核心和基础。马克思主义哲学作为方法论，对法学具有普遍的指导意义，但是不能以马克思主义哲学这一总的方法论代替法学自身的方法论。除马克思主义的哲学方法外，法学还有自身的方法论。日常使用的法学研究方法主要有社会调查的方法、历史调查的方法、价值分析的方法、阶级分析的方法、分析和比较的方法、词义分析的方法、社会效益和经济效益的分析方法等。

学习和研究法理学，有助于树立马克思主义法律观，提高社会主义法律意识、法律文化水平，增强社会主义法治观念，同时也有助于为学习其他部门法学乃至整个法律科学奠定必要的专业理论基础。

第二章 法的特征与本质

第一节 法的概述

一、“法”的词义

【分析】“法”首先是指一种实在的社会现象，其次是指描述这样一个社会现象的概念或名称。

汉语中“法”一词的含义甚为广泛，根据《说文解字》中的释义，它大体有三层含义：第一，“法”与“刑”是通用的；第二，法者，平之如水，含有“公平”之义；第三，法含有“明断曲直”之义。一方面，汉语中的“法”在哲理意义上与“理”通用，指“道理”“天理”；另一方面，汉语中的“法”又在典章制度意义上使用，与“律”“法律”“法制”等通用。

二、当代关于“法”与“法律”的使用

►西方关于“法”与“法律”的使用；当代中国关于“法”与“法律”的使用

【分析】在大部分西方语言中，“法”主要是在哲理意义上使用的。学者们为了方便区别，分别在“法”一词之前加上“客观”和“主观”定语，这便有了“客观法”与“主观法”的称谓。其中，客观法指的是实在法，主观法主要指权利。西方语言中真正在国法意义上使用的“法”（法律）主要是指国家机关制定和颁布的具体法律规则，即实在法。

在当代中国，法与法律有时通用；有时则将法作为比法律更广泛的概念。如以我国宪法和立法法为例，从狭义层面理解法律，即认为法律仅指由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性法律文件；而从广义层面理解法，则认为法是指包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、规章等在内的一切规范性法律文件。

第二节 法的基本特征（范遍权义，国威程强）

一、法具有规范性和普遍性

►法是调整人们行为的规范，具有规范性和普遍性

【分析】从其存在形态看，法首先是一种规范。所谓规范，是指人们行为的标准或规则。法不是一般的规范，而是一种社会规范。其特点在于它所调整的是人们之间的相互关系（社会关系）。法作为社会规范，不同于思维规范、语言规范，也不同于技术规范，而是像道德规范、宗教规范一样，具有规范性。法的规范性是指法律所具有的规定人们行为模式、指导人们行为的性质，表现在法规定了人们的一般行为模式，从而为人们的交互行为提供了模型、标准或方向。法所规定的行为模式包括三种：人们可以怎样行为（可为）、人们不得怎样行为（勿为）、人们应当或必须怎样行为（应为）。从效力范围上看，法的规范性至少有三个特点：（1）它针对的对象是不特定的大多数人；（2）它只对规范制定生效后发生的行为有效；（3）在其有效期内，针对同样的情况反复适用。与此相联系，作为约束人们行为的规范，法也具有普遍性。法的普遍性是指法所具有的普遍约束力，它通常包括两重含义：（1）在一国主权范围内，法具有普遍效力，所有人都要遵守；（2）法对同样的事和人同样适用，即法律面前人人平等。

二、法具有国家意志性和权威性

►法是由国家制定或认可的社会规范，具有国家意志性和权威性

【分析】法是一种特殊的社会规范。这种特殊性就在于它是由国家制定或认可的。从法是由国家制定或认可的意义上看，法体现国家的意志。这一特征明显地表明了法与其他社会规范，如道德规范、宗教规范、政党或其他社会组织的规章以及习惯礼仪等的差别。法由国家制定或认可，这是从法作为一个整体并以国家名义制定或认可来说的，它还表明了创制法律的两种方式。事实上，构成这一整体的各个具体的法律、法规是由不同层次或不同类别的国家机关制定或认可的。国家制定的法律通常称为成文法或制定法。法的认可是指国家通过一定的方式承认其他社会规范（道德、宗教、风俗、习惯等）具有法律效力的活动。法由国家制定或认可这一特征意味着体现国家意志的法具有统一性和权威性。法的权威性不仅表现为人们必须遵守或服从它，还表现为当它与道德、宗教、政策等发生冲突时，它作为国家意志的体现具有更大的权威性。

三、法具有权利和义务的一致性

►法是以权利和义务为内容的社会规范，具有权利和义务的一致性

【分析】法律对人们行为的调整主要是通过权利和义务的设定和运行来实现的，因而法律的内容主要表现为权利和义务。法律上的权利和义务的规定具有确定性和可预测性的特点，它明确告诉人们该怎样行为、不该怎样行为以及必须怎样行为。人们根据法律来预先估计自己与他人之间该怎样行为，并预见到行为的后果以及法律的态度。法律只要规定了权利，就必须规定或意味着相应的义务，法律具有权利和义务的一致性。这一特征也是法律与其他社会规范的一个重要区别。有的社会规范，如政党或其他社会团体的规章，虽然也规定各自成员的某种权利和义务，但是在内容、范围和保证实施的方式上与法律意义上的权利和义务有很大的区别。

四、法具有国家强制性和程序性

►法是由国家强制力保证实施的社会规范，具有国家强制性和程序性

【分析】一切社会规范都具有强制性，都有保证其实施的社会力量。道德规范主要依靠社会舆论、传统习

惯以及人们的内心确信等来加以维持；宗教规范的实施主要是通过精神约束的方式，依靠清规戒律、惩罚制度来保证教徒的遵守。法律不同于其他社会规范，它具有特殊的强制性，即国家强制性。法律以国家强制力为后盾，由国家强制力保证实施。国家的强制力是法律实施的最后的保障手段。法律之所以要由国家强制力保证实施，取决于下面两个原因：一是法律不一定能始终为人们所自愿遵守，需要通过国家强制力强迫人们遵守；二是法律不能自行实施，需要国家专门机关予以运用。与此相关，法还具有程序性，主要是在近现代意义上讲的。无论立法、执法还是司法，都有相应的法律程序。法律程序是保证法律公正的重要手段。

第三节 法的本质

一、关于法的本质的不同学说

►神意论；理性论；命令论；民族精神论；社会控制论；其他学说

【分析】法的本质是相对于法的现象(或法律现象)的一个范畴。在历史上，非马克思主义思想家和法学家们曾对法的本质问题进行过认真的思考，提出过各种各样关于法的本质的学说，他们虽然对很多法律现象作出了科学的说明，但在法的本质这一根本问题上并没有作出科学的回答。非马克思主义思想家和法学家关于法的本质的学说归纳起来主要包括：

神意论。这是历史上较早出现的解释法的本质问题的观点，直接或间接地将法的本质归结为神的意志。在西方法学史上，这种理论的主要代表人物是西罗马帝国后期的圣·奥古斯丁和13世纪经院主义哲学家托马斯·阿奎那。阿奎那在其《神学大全》一书中认为，神的智慧是一切法律的渊源，神的智慧本身具有法律性质。

理性论。这一学说将法的本质解释为理性、人性等。在西方法学史上，首先将法的本质归结为理性的是古希腊的斯多葛学派的哲学家，他们认为整个宇宙由理性构成，自然与理性是等同的，理性是永恒不变的、普遍的自然法的基础。古罗马思想家西塞罗也指出：法是最高的理性，理性在人类理智中稳定而充分发展之时，就是法律。17世纪至18世纪，古典自然法学派的一些学者也将法的本质归结为人的理性和本性，其中的主要代表人物有荷兰的格劳秀斯、斯宾诺莎，英国的霍布斯、洛克，德国的普芬道夫，法国的孟德斯鸠、卢梭等。

命令论。英国哲学家霍布斯说，法是国家对人民的命令，是用口头说明，或用书面文字，或用其他方法所表示的规则或意志，用以辨别是非，指示从违。英国功利主义法学的鼻祖边沁也说过，法是国家行使权力处罚犯罪的威吓性命令。命令论的代表人物是19世纪英国法哲学家、分析法学派的代表人物约翰·奥斯丁。他认为，法律是主权者对其臣民所发布的应当如何行为并以制裁为后盾的命令。法律的显著特点之一在于它是一种命令，每一个法律和规则都是命令，严格意义上的法律和规则是命令的总和。

民族精神论。德国历史法学派代表人物卡尔·冯·萨维尼在《论立法与法学的当代使命》中指出，自古以来，法就像语言、风俗、政治一样，是民族精神、民族特性和民族共同意识的体现。法随着民族的成长而成长，随着民族精神的加强而加强，最后随着民族个性的消亡而消亡。

社会控制论。美国社会法学派代表人物罗斯科·庞德在《通过法律的社会控制》一书中指出，法是社会控制的手段，法是政治上组织起来的高度专门化的社会控制形式，是一种通过有系统有序地适用社会强力的社会控制。

其他关于法的本质的学说。关于法的本质问题，法学史上还有一些学说也很有影响。比如，卢梭的“公意论”、黑格尔的“自由意志论”、罗尔斯的“正义论”、狄骥的“社会连带关系论”等。卢梭在《社会契约论》中指出，法是公意的体现，公意即人们的共同意志、普遍意志。黑格尔在《法哲学原理》中强调法是自由意志的外在表现形式，自由意志是法的内核，“法是自由意志的定在”。狄骥在《法和国家》中认为，社会的基本事实是连带关系，法律就是基于这一事实和为了维护社会连带关系而存在的。

二、马克思主义法学关于法的本质的学说

► 法律是统治阶级意志的体现；法律所体现的意志由一定的物质生活条件所决定；法律所体现的意志也受经济以外诸多因素的影响

【分析】关于法律与意志的关系，马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中写道：由这些特定关系所决定的意志具有国家意志即法律这种一般表现形式，其内容总是由这个阶级的关系决定的。结合上下文，特定关系是指不以人的意志为转移的物质生活关系。统治阶级使他们的意志具有国家意志即法律这种一般形式。在这里，马克思、恩格斯将国家意志等同于法律。这是马克思、恩格斯对资产阶级国家法律的一个客观描述。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出，你们的法不过是被奉为法律的你们这个阶级的意志一样，而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的。由此推出，资产阶级的法是被奉为法律的资产阶级意志，或者说阶级社会的法是统治阶级意志的体现。统治阶级利用掌握国家政权这一政治优势，有必要、也有可能将本阶级的意志上升为国家意志，然后体现为国家的法律。法律所体现的统治阶级意志不是统治阶级内部的各党派、集团及每个成员的个别意志，也不是这些个别意志的简单相加，而是统治阶级的整体意志、共同意志或根本意志。这种共同意志或根本意志是统治阶级作为一个整体在政治上、经济上的根本利益的反映。

马克思认为，法律表面上是国家意志或统治阶级意志的体现，但意志的内容是由一定的物质生活条件所决定的。物质生活条件是指人类社会所包括的地理环境、人口、物质资料的生产方式诸方面，主要指统治阶级赖以建立其政治统治的经济关系。从根本上讲，法律决定于一定的经济关系。法律的产生、发展、性质、内容都受制于一定的经济关系。马克思认为，法律应该是社会共同的、由一定的物质生产方式所产生的利益和需要的表现。生产关系的不断再生产取得了规则和有序固定形式。这种规则和秩序一开始作为习惯和传统固定下来，最后转化为成文的法律。由此可见，法律源于生产关系。列宁对此做出了精彩的总结：生产关系的体系是社会的基础，政治法律形式和某些社会思潮则是这个基础的外表。马克思在批判蒲鲁东时指出，无论是政治的立法或市民的立法，都只是表明和记载经济关系的要求而已。恩格斯认为经济关系是法律的决定性因素，法律等上层建筑归根结底都由经济关系形成的现实基础来说明。

物质生活条件决定阶级意志的内容，但阶级意志的内容还受到经济以外的各种因素的不同程度的影响。法律和这些因素归根结底在由经济因素起决定作用的条件下相互作用。经济以外的各种因素的范围是很广泛的，主要包括政治、思想、道德、文化、历史传统、民族、宗教、习惯等。在分析法律的本质时，不应忽略这些因素。如果将经济条件理解为法律的阶级意志内容的唯一决定因素，实际生活中无数现象就无法理解了。比如，几个国家或一个国家在不同地区、不同时期，虽然经济制度或经济发展水平是一样的，但它们的法律却可以千差万别。不认真分析经济以外的因素，就无法正确解释法律的种种差异。

第三章 法的起源与演进

第一节 法的起源

一、法起源的主要原因

► 法起源的经济因素；法起源的政治因素

【分析】法是人类社会一定发展阶段的产物。在人类原始社会漫长的历史中，没有阶级、私有制，也没有代表复杂社会组织形态的国家和法律。马克思主义法学认为，法的产生和发展是多种社会因素相互作用的产物，但这些因素又是在经济因素最终起决定作用的条件下相互作用的。在原始社会后期，生产力水平有了

很大的提高，产生了私有财产，出现了三次社会大分工，社会分工的发展使经常性的交换成为必要和可能。恩格斯认为，在社会发展某个很早的阶段，产生了这样一种需要：把每天重复着的产品生产、分配和交换用一个共同规则约束起来，借以使个人服从生产和交换的一般条件。这个规则首先表现为习惯，不久便成了法律。

除了经济因素在法的产生过程中起了决定性作用外，法的产生也是当时阶级划分和阶级斗争的结果。随着社会生产力的发展，社会分工及生产与交换发展的同时，社会也出现了私有制和阶级的分化，形成了两个对抗性的社会利益集团——奴隶主阶级和奴隶阶级。作为统治阶级的奴隶主阶级，开始利用国家和法来维护自己的统治，这是法产生的政治根源。

随着社会经济的发展，社会公共事务也比以往原始社会更加复杂和增多，原始社会中的极为简单的习惯已无法适应处理这些事务的要求，这就需要产生一种新的行为规则，即法。另外，随着社会经济的发展，人的独立意识的成长也促进了法的产生。

总之，法的产生，除了经济、政治原因外，还有人文、地理等因素的影响。原始社会的习惯转变为阶级社会的法，两者的具体形式存在着很大的差别。

二、法起源的一般规律

►由个别调整逐步发展为规范性调整；由习惯到习惯法再到制定法；由与道德规范、宗教规范混为一体到相对独立

【分析】由个别到一般、由自发到自觉，是人类认识发展的一条基本规律，也是法起源和发展的规律。先自发产生了氏族习惯，后来发展为国家自觉认可或制定的法律规范；先出现对特定人、特定事的调整，然后才发展为对一般人、一般事的调整。

任何国家法的起源，都不可能在刚形成时就具备完全成熟的形态或只有一种形态。法的形态总是先表现为不成文形式，即习惯和习惯法，然后才发展为成文(制定)形式，即成文法。在这一过程中，文化的因素起着相当大的作用。

法在氏族习惯的母体中孕育生长，而氏族习惯融原始的道德、宗教等多种社会规范于一体，它们之间没有明确的界限。法律规则的专门化、独立化是社会规范分化的结果，法的形成过程实际上是法日益脱离宗教、道德规范而成为独立的专门的社会规范的过程。

第二节 法的演进

一、法的历史类型

►奴隶制法；封建制法；资本主义法；社会主义法

【分析】奴隶制法。奴隶制法是人类历史上最早出现的法，也是最早的私有制类型的法。奴隶制法的本质和特征是由奴隶制社会的经济基础所决定的。在不同的奴隶制国家和奴隶制社会发展的不同阶段，奴隶制法有着不同的特点。但从总体上认识，奴隶制法具有一些共同特征：严格保护奴隶主的所有制，这是奴隶制法的核心作用；奴隶制法还公开反映和维护奴隶主贵族的等级特权；另外，奴隶制法的刑罚手段极其残酷，长期保留着原始社会的某些行为规范残余。公元前18世纪的《汉谟拉比法典》、公元前450年左右的《十二铜表法》等是奴隶制法典的代表。

封建制法。封建制法是继奴隶制法之后出现的一种私有制类型的法。封建制法赖以建立和存在的经济基础是地主或领主占有土地和部分占有农民或农奴。封建制法是地主阶级意志的体现，确认农民对封建地主的依附关系、维护专制王权是封建制法的共同特征。我国的《唐律》是封建制法的典型代表。

资本主义法。总的来说，资本主义法集中体现了资产阶级的意志。在资本主义社会中，尽管也会存在多种经济成分，但是占统治地位的总是以资本家占有生产资料并剥削雇佣劳动为基础的私有制经济。资本主义法律的本质是建立在资本主义经济基础上的法律上层建筑，它首先是资产阶级意志和利益的体现，在垄断资本主义时期，它首先又是垄断集体意志和利益的体现。资本主义法律所代表的是作为一个整体的资产阶级的意志和利益。（删除：资本主义法律绝不是“超阶级”的，所谓“法律是公共意志的体现”的说法是错误的。）

与以往私有制社会法律相比，资本主义法律具有三个方面的特征：首先，维护以剥削雇佣劳动为基础的资本主义私有制。在资本主义社会发展的不同阶段，资本主义法律在调整经济生活领域中的作用以及法律在保护财产权方面的规定是有所不同的，但是其维护资本主义私有制即资产阶级财产权是资本主义法律的核心。其次，资本主义法维护资产阶级专政和“代议制”政府。资产阶级进行政治统治的基本方式和主要形式是建立“代议制”政府，实行资产阶级专政。资本主义法维护资产阶级专政的作用主要体现在公法上。资产阶级与封建主专政的一个重要区别在于，资产阶级是通过自己的政党来执掌政权的，政党制是资本主义政治制度中一项重要的制度。最后，资本主义法维护资产阶级自由、平等和人权。资本主义社会不同于以往私有制社会的一个重要特征就在于，在形式上，人人都处于“平等”地位，都“平等”地享有各种“自由”，这种平等和自由又被称为“人权”。资产阶级的自由、平等、人权都属于资本主义民主的范畴，资本主义法对保障平等、自由和人权具有巨大的历史进步作用。但是资产阶级的平等、自由与人权原则受到其阶级利益的局限，是不彻底的。

社会主义法。我国社会主义法的产生，是以革命根据地时期的法律为基础的，是对革命根据地法的继承和发展。从第一次国内革命战争时期开始到解放战争时期，中国共产党领导下的革命政权就已经创制了革命的法制。废除旧法是社会主义法产生的前提，借鉴人类法治文明成果是我国社会主义法产生的重要条件。社会主义法不是凭空产生的，它首先要符合社会发展的内在需求，同时也要借鉴和吸收人类法治文明的成果。

我国社会主义法的本质特征表现为人民性与阶级性的统一、正义性与政治性的统一、科学性与先进性的统一。首先，我国社会主义法的本质，是工人阶级领导下的全国人民共同意志的体现。我国社会主义法所体现的意志既有鲜明的阶级性，又有广泛的人民性，它不仅强调工人阶级的领导，还强调坚持人民主体地位，一切以人民为中心，因而是人民性与阶级性的统一。其次，我国社会主义法体现出代表社会发展进步方向的正义性；同时，党的领导是我国社会主义法治之魂，是我国法治同西方资本主义国家法治最大的区别。因此，社会主义法是正义性与政治性的统一。最后，我国社会主义法坚持从中国实际出发，吸收借鉴古今中外优秀的法律文化与制度经验，又与时俱进，不断发展与完善自身制度与实践，体现了科学性与先进性的统一。

二、法系

►法系的概念：中华法系；英美法系；大陆法系；西方两大法系的区别

【分析】法系是西方法学家首先使用的一个概念。它是按照世界上各个国家和地区法律的源流关系、历史传统以及形式上的某些特点对法律所作的分类。法系是具有共性或共同历史传统的法律的总称。法系的划分主要是依法律的历史传统进行的，但是影响法系形成的因素很多，也十分复杂。按一些比较法学家的观点，世界上存在并发挥过重要影响的五大法系是中华法系、伊斯兰法系、印度法系、英美法系和大陆法系。其中，英美法系和大陆法系对资本主义法律影响最大。

中华法系是世界五大法系之一。中华法系初步形成于秦朝（前 221—前 206），到隋唐时期发展成熟。中国法律史上自春秋战国时期法律制度的大变革，成文法在各国颁布，到秦朝时中华法系有了雏形。秦朝的法律制度从现在湖北云梦出土的秦简来看，已经比较完备，初步确立了中国古代各项法律的原则。此后，经过西汉和东汉，以及三国两晋南北朝长达七百多年的发展，到隋唐时，法律思想和法律制度更趋成熟，并自成体系。其代表性的法典就是保存至今的永徽律及其律疏，又称《唐律疏议》，这是中华法系发展完备的标志。唐朝以后，宋

元明清各朝都以此为蓝本创制自己朝代的法律制度。日本所学的正是隋唐的法制，至今日本还用的省(相当于中国的部)、地方的县(相当于中国的省)、府、道都是学习隋唐法制的结果。中华法系的主要特点有：第一，法律以君主意志为主。第二，礼法结合是法律的重要原则。第三，刑法发达，民法薄弱。第四，行政司法合一。

英美法系又称普通法法系、判例法系、不成文法系、海洋法系等。普通法法系是以英国中世纪的法律，特别是普通法为基础而发展起来的法律的总称。普通法是一个多义词，这里特指公元 11 世纪诺曼人入侵英国后逐步形成的一种判例法，不同于汉语中所讲的与根本法相对应的普通法概念。14 世纪以后，英国基于大法官法院的判决又形成了衡平法。普通法法系的分布范围包括英国本土(苏格兰除外)及美国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚、新西兰等这些历史上曾是英国的殖民地、附属国的许多国家和地区。其中，英国法与美国法的差别较大，英国法采取不成文宪法制和单一制，法院没有司法审查权；美国法采用成文宪法制和联邦制，法院有通过具体案件确定是否符合宪法的司法审查权，公民权利主要通过宪法规定。英国法和美国法是普通法法系中的两个重要的分支，因此普通法法系也可以称为英美法系。

大陆法系又称民法法系、罗马法系、罗马德意志法系、日耳曼法系、法典法系、成文法法系等。大陆法系是以罗马法为基础而发展起来的法律的总称。它是在罗马法基础上，以 1804 年《法国民法典》和 1896 年《德国民法典》为代表性法典，以及在其影响下仿照它们而形成和发展起来的各国法律的总称。它以罗马法为历史渊源，以民法为典型，以法典化的成文法为主要形式。欧洲大陆大多数国家、前欧洲国家的殖民地、拉丁美洲等许多国家和地区的法律都属于大陆法系。此外，由于历史的原因，日本、土耳其、美国的路易斯安那州、加拿大的魁北克省等国家和地区的法律也基本上属于大陆法系。大陆法系包括法国法系和德国法系两个支系。法国法系是以 1804 年《法国民法典》为蓝本建立起来的，它以强调个人权利为主导思想，反映了自由资本主义时期社会经济的特点；德国法系是以 1896 年《德国民法典》为基础建立起来的，强调国家干预和社会利益，是垄断资本主义时期法的典型。

普通法法系和大陆法系既有联系又有区别。两大法系在赖以存在的经济基础、阶级本质、总的指导思想和基本原则等方面都是一致的。两大法系的区别可以分为两类，一类是微观差别，即具体部门法律制度、法律规则方面的差别；另一类是宏观差别，这类差别主要体现在以下几个方面：(1)法的渊源不同。在大陆法系国家，正式的法的渊源主要是指制定法，法院的判例不是正式意义上的法的渊源；在普通法法系国家，制定法和判例法都是正式的法的渊源，判例法在整个法律体系中占有非常重要的地位。(2)法律分类不同。大陆法系国家法的基本分类是公法和私法，进入 20 世纪后又出现了经济法、劳动法等兼有公法和私法两种成分的法；普通法法系国家无公法和私法之分，法的基本分类是普通法和衡平法。普通法和衡平法都是判例法。(3)法典编纂不同。大陆法系国家承袭古代罗马法的传统，基本法律一般采用系统的法典形式；普通法法系国家，尤其是英国，一般不倾向于法典形式，它的制定法往往是单行的法律、法规。即使后来英美法系国家逐步采用法典形式，也主要是判例法的规范化。(4)诉讼程序和判决程式不同。大陆法系的诉讼程序以法官为重心，奉行职权主义，具有纠问程序的特点。法官审理案件除了案件事实外，首先考虑制定法是如何规定的，随后按照有关规定来判决案件；普通法法系的诉讼程序奉行当事人主义，法官一般充当消极的、中立的裁定者的角色，法官首先要考虑以前类似案件的判例，将本案的事实与以前案件事实加以比较，然后从以前判例中概括出可以适用于本案的法律规则。

以上这些差别主要是由于两大法系的不同历史背景造成的，也体现了不同的哲学倾向。一般来说，大陆法系倾向于理性主义，而普通法法系则倾向于经验主义。进入 20 世纪后，两大法系之间的差异已逐渐缩小，融合也正在发生，但传统不同，差异还将长期存在。

三、法律继承与移植

►法律继承的含义：法律继承的根据与理由

【分析】法律继承是不同历史类型或不同时代的法律制度之间的延续和继受，一般表现为旧法对新法的影响和新法对旧法的承接和继受。

法律继承的根据和理由主要表现在：(1) 社会生活条件的历史延续性决定了法律的继承性。(2) 法律的相对独立性决定了法的发展过程的延续性和继承性。(3) 法作为人类文明成果决定了法律继承的必要性。(4) 法律演进的历史事实验证了法律的继承性。

►法律移植的含义；法律移植的必要性

【分析】法律移植是指在鉴别、认同、调适、整合的基础上，引进、吸收、采纳、摄取、同化外国法，使之成为本国法律体系中的有机组成部分，为本国所用。法律移植反映了一国对其他国家和地区法律制度的吸收与借鉴，法律移植的范围除外国的法律外，还包括国际法律和惯例。

法律移植有其必然性和必要性：(1) 社会发展和法律发展的不平衡性决定了法律移植的必然性；(2) 市场经济的客观规律和根本特征决定了法律移植的必要性；(3) 法治现代化既是社会现代化的基本内容，也是社会现代化的动力，法律移植则是法治现代化的一个过程和途径；(4) 法律移植是对外开放的应有内容。

第三节 法律全球化

一、法律全球化的概念与趋势

►法律全球化的含义；法律全球化的趋势

【分析】法律全球化是指法律跨越国家和地区的疆界，在世界范围传播、流动。具体而言，是指法律的各种要素，如法律原则、法律理念、法律价值观、法律制度、执法标准与原则等，在全球范围内的趋同，并在全球范围形成一个法治的标准或模范。法律全球化是全球化的重要组成部分，与科技和经济的全球化密不可分。

法律全球化的趋势主要表现为：(1) 法律的“非国家化”(denationalization)。法律并非都是由主权国家制定的，越来越多的法律由各种经济联合体、知识产权组织、环境保护组织、新闻媒介联合体等“非国家”的机构制定。例如，《国际贸易术语解释通则》就是由国际商会编订的。(2) 法律的“标本化”或“标准化”(modelization)。由联合国、国际组织、经济联合体制定法律范本，提供给各个国家作为立法的参照。(3) 法律的“趋同化”。所谓法律趋同化，是指调整相同类型社会关系的法律规范和法律制度趋向一致，既包括不同国家的国内法的趋向一致，也包括国内法与国际法的趋向一致。世界范围内的法律趋同首先表现在民商法领域。在商务、金融、知识产权等领域，法律的趋同速度之快、程度之高，超出了人们的预料和想象。(4) 法律的“世界化”。所谓法律世界化，是指全球范围内法律规范的相互联结，国际法与国内法之间的界限正在变得模糊不清，而这种联结的实现就在于国际法高于国内法的信念已得到普遍的确认。法律世界化还意味着某些“全球性法”“世界性法”的出现。

二、法律全球化的进展和主要途径

►法律全球化的重大进展

【分析】当代世界在全球治理和国际法治领域已经取得重大进展，主要表现在以下方面：

1. 《联合国宪章》成为世界共同遵守的基本规范。《联合国宪章》在相当长的时间里被视为政治宣言，是迄今拥有缔约国最多的一项国际公约，与《世界人权宣言》以及其他重要的国际人权公约等构成了国际法治的基本构架，具有了“准世界宪法”的性质，如果违反，不仅会受到国际社会的谴责，而且会受到联合国的经济乃至军事的制裁。

2. 国际法的许多任意性规范成为强制性规范。近几十年来，国际条约的数量迅速增加，覆盖的领域不断扩

大，涉及经济、政治、人权、环境、海洋、外太空等领域，调整的社会关系也日趋具体。另外，根据 1969 年《维也纳条约法公约》的规定，强行规范高于一般规范，由此，一般国际法强制规范的地位得到了确立。

3. 国际司法机制正在强化。冷战结束后，安理会的地位明显加强，在许多重大国际问题上开始取得一致，由此采取行动的力量大为增强。同时，国际法院的作用也在强化，在审理国际案件方面比以前更有作为。特别值得注意的是，伴随着《国际刑事法院罗马规约》(1998) 的生效，2002 年国际刑事法院正式成立，其可跨越主权国家的界域对某些犯罪行为实行管辖。

►法律全球化的主要途径

【分析】法律全球化的主要途径有以下几种：

1. 国际法的国内化、地方化。国际性法律的国内化、地方化，是指联合国、国际组织和国际社会层面的法律被各国全部或部分承认或接受，通过这种承认或接受，全球性的法律成为各国法律的组成部分。这主要表现在以下两个方面：(1) 在人权领域中，联合国和国际组织已经形成了许多标准人权文件。其中最重要的人权文件是《世界人权宣言》《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》。这些国际人权文件规定了一般权利和自由。(2) 世贸组织成立后，缔约方必须根据有关协议调整自己的法律制度，例如取消内部行政规定、修改知识产权保护法、改革司法制度等。世界银行和国际货币基金组织在向发展中国家提供贷款和援助时，常常附有条件要求受援国改革政治体制和法律制度。

2. 地方法或国内法的全球化。地方法或国内法的全球化，主要是指原本是地方性的法律，经由某种途径被全球化。这主要表现在以下两个方面：(1) 新商人法穿越国家领土。早在中世纪后期，伴随着商业的复兴，西欧就出现了跨国的商人法。至 20 世纪后期，跨国商事活动迅速增加，而主权国家的法律不适合规范跨国企业的商事活动，国家的和国际的纠纷解决机制也不便于跨国商事纠纷的解决。因此，跨国企业便在商业实践中形成了新商人法。新商人法有别于国家法和国际法，是一种“自我合法化”的法律，它不依赖国家或国际的法律和传统的法院，是一种“自我繁衍”和“自我发展”的法律制度。(2) 美国等西方国家通过“法律与发展”项目“推销”西方的法律。早在 20 世纪 60 年代，美国等西方国家就开展了法律与发展项目，其主要目的是向发展中国家输出法律。20 世纪 80 年代中期以后，美国发起了新的法律与发展项目。新一轮法律与发展项目是在经济全球化的背景下实施的，美国试图通过法律输出占领世界法律市场，并通过推广美国法的经验进而实现世界法律的美国化。这些项目尽管没有取得完全的成功，但毕竟影响了许多拉美受援国法律发展的方向和法律改革的进程。

必须承认，(对待全球化的态度) 法律全球化在目前仍然只是一个进程，一个过程，一种趋势；法律全球化并不是所有法律的全球化，那些不具有涉外性、国际性的地方性法律不可能、也没有必要化为“全球性”或“世界性”法律；法律全球化并不意味着国家主权概念的过时或消失，而只是意味着主权概念的进步和丰富，各国之间的法律仍将呈现多样性、多元化；各个国家均应当警惕和制止少数或个别国家借助法律全球化的名义而推行政治霸权主义和法律帝国主义。近年来，美国通过其霸权主义的“长臂管辖”条款，试图绕开国际法，用国内法来应对国际挑战，在一定程度上是一种逆法律全球化运动。

第四章 法的作用与法的价值

第一节 法的作用

一、法的作用的概念

►法的作用的含义：法的作用的实质

【分析】法的作用，又称法的功能，是指法律对人们的行为、社会生活和社会关系产生的影响。

对法的作用可以进行不同的划分。依据作用范围，分为整体作用与局部作用；依据作用结果的状态，分为预期作用与实际作用；依据作用的途径，分为直接作用与间接作用；依据作用的效果，分为积极作用与消极作用。

对法的作用的实质可以从两方面来认识：一方面，法的作用是国家权力运行和国家意志实现的具体表现。国家权力是法的载体和支点，法是国家意志这一内容的规范化。法对人的行为以及对社会关系的影响，实质上就是国家把自己的意志和态度通过国家权力加以推行和实现。另一方面，法的作用是社会经济状况的具体表现。法的作用取决于经济基础，在一定的社会中，法能否承担起立法者所赋予它的功能，从根本上说，取决于生产关系或生产方式自身的生命力，而不是取决于立法者的主观愿望。

二、法的作用的分类

►法的规范作用和社会作用：其他分类

【分析】一切社会的法的作用都可以有规范作用和社会作用之分。

法的规范作用是指法作为行为规范，对人们的意志、行为发生的直接影响，对人的行为所起到的保障和约束作用。这是从法是一种调整人们行为的规范，即从法的特征角度来解释法的作用。

根据法的规范作用的不同对象，即不同的行为，规范作用可以大体上被概括为指引作用、评价作用、预测作用、教育作用和强制作用等。

法的社会作用是指法的社会、政治功能，即法作为社会关系的调整器，服务于一定的社会政治目的、目标，承担着一定的社会政治使命，形成、维护、实现一定的社会秩序。这是从法的本质和目的这一角度来解释法的作用。在阶级对立社会，法的社会作用大体上又可以归纳为维护阶级统治和执行社会公共事务两个方面。

法的规范作用和社会作用在考察基点、作用对象、存在方式以及发挥作用的前提等方面存在着一定的差别。但是这两种作用又是相辅相成的，它们之间具有手段和目的的关系。法是通过调整人们行为这种规范作用来实现维护社会经济基础和发展生产力的社会作用的。法的规范作用是手段，法的社会作用是目的。

除了有规范作用和社会作用之分外，法的作用还可以划分为整体作用和局部作用、预期作用与实际作用、直接作用和间接作用、积极作用和消极作用。整体作用是指法作为统一的法律体系在社会生活中的作用，局部作用是指法律体系中的某一子系统在社会生活中的作用；预期作用是指人们在立法时对法所报以期望的按预计情况应当予以实现的作用，实际作用是指法在实施过程中经过诸多环节和诸多因素的复杂影响后所实际达到的作用；直接作用是指具体法律规范对特定关系的定向调整，间接作用是指法调整特定关系时对其他社会关系的影响；积极作用是指人们依据一定的价值标准对法的作用作出肯定的评价，消极作用是指人们依据一定的价值标准对法的作用作出否定的评价。

三、法的规范作用

►指引作用；评价作用；预测作用；教育作用；强制作用

【分析】法的指引作用是指法律规范对本人行为起到的导向和引导的作用。法律规范通过配置人们在法律上的权利义务以及规定违反法律规定所应承担的法律责任，设定人们的行为模式，引导人们在法所许可的范围内开展活动，从而把社会主体的活动引入可调控的、有利于社会稳定的社会秩序之中。法的指引是一种规范指引，它不同于个别指引。规范指引虽然很抽象，存在针对性弱的一面，但是它能避免个别指引在时间、精力和经济上的浪费，它具有连续性、稳定性和高效率的优势，是建立社会秩序必不可少的条件和手段。根据法律规范中行为模式的不同，可以将法律规范的指引作用分为确定性指引和不确定性指引。前者以义务行为模式来对

人的行为进行指引，不允许选择；后者以权利行为模式来对人的行为进行指引，允许自行选择。

法的评价作用是指法作为人们对他人行为的评价标准所起的作用。其作用对象是他人的行为。法的评价作用的特点在于，它是用法的规范性、统一性、普遍性、强制性和综合性的标准来评判人们的行为的，**其标准和核心是合法与否。**法的评价作用的形式主要有专门评价和社会评价。前者是指经法律专门授权的国家机关、组织及其成员对他人的行为所作的评价，如法院、仲裁机构、行政机关对人们行为所作的裁判或决定，其特点是代表国家，具有国家强制力，产生法律约束力，因此又称效力性评价。后者是指普通主体以舆论的形式对他人行为所作的评价，没有国家强制力和约束力，是人们自发的行为，因此又称舆论性评价。

法的预测作用是指人们根据法可以预先估计人们相互间将怎样行为以及行为的后果等，从而对自己的行为作出合理的安排。预测作用的对象是人们的相互行为，比如合同双方当事人根据《民法典》合同编分别进行的预测。法之所以具有预测作用，是因为法具有规范性、确定性的特点。人们根据法律，通过预测相互间的所作所为及其后果，来确定、安排、协调自己行为的方式、方向、取舍，从而作出选择。法是人们行为的预测工具和生活指针。

法的教育作用是指通过法的实施，使法对一般人的行为产生影响。这种作用的对象是一般人的行为。法的教育作用表现在，通过法的实施，法律规范对人们今后的行为发生直接或间接的诱导影响。法的教育作用是通过正反两个方面来实现的。**一方面，通过对违法行为人实施制裁，**对包括违法者本人在内的一般人均起到警示和警诫的作用；**另一方面，通过对合法行为加以保护、赞许或奖励，**对一般人的行为起到表率、示范作用。

法的强制作用是指法可以用来制裁、强制、约束违法犯罪行为。这种作用的对象是违法犯罪者的行为。法的强制作用是不可或缺的一种重要作用，是法的其他作用的保证。如果没有强制作用，法的指引作用就会降低，评价作用就会在很大程度上失去意义，预测作用就会产生疑问，教育作用的实效就会受到影响。强制作用的目的在于实现法律上的权利和义务，确保法的应有权威和尊严，维护正义，建立、维护和发展良性的社会秩序。法的强制功能是法存在的最后屏障。

四、法的社会作用

►维护阶级统治的作用；执行社会公共事务的作用

【分析】首先，维护阶级统治的作用。依照法的阶级分析观点，**调整统治阶级与被统治阶级之间的关系，**是法的社会作用的重要体现。**法维护的是统治阶级整体的长远的利益，**统治阶级中个别成员违背统治阶级整体利益和长远利益的行为，**也会受到法的制裁。**统治阶级需要用法来规定和确认他们自己内部各阶层、集团的相互关系，以此建立起个人意志服从整个阶级的关系，通过这种服从，确保其成员的权力的实现，解决其内部因财产、婚姻等问题而引起的矛盾和纠纷，保证其内部和谐一致。

其次，执行社会公共事务的作用。阶级对立社会的法，除了维护阶级统治这一核心作用外，还具有执行各种社会公共事务的作用。法在执行社会公共事务上的作用具体表现在：**维护人类社会的基本生活条件，**包括维护最低限度的社会治安，保障社会成员的基本人身安全，保障食品卫生、生态平衡、环境与资源合理利用、交通安全，等等。**维护生产和交换条件，**即通过立法和实施法律来维护生产管理，保障基本劳动条件，调节各种交易行为，促进公共设施建设，组织社会化大生产，确认和执行技术规范，保护消费者权益等。**促进教育、科学和文化事业的发展，**如通过法律对人们的受教育权加以保护，鼓励兴办教育和科技发明，保护人类优秀的文化遗产，要求政府兴办各种图书馆、博物馆等文化设施。

维护阶级统治的作用和执行社会公共事务的作用之间存在着明显的区别。**前者的对象是阶级统治，后者的对象是阶级统治以外的事务。**前者主要有利于统治阶级，后者至少在客观上有利于全社会。执行社会公共事务的法，在不同的社会制度下是可以相互借鉴的。执行社会公共事务的法主要体现着法的社会性，但在本质上与

法在维护阶级统治方面的作用并不矛盾。正如恩格斯所说，政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去。

五、法的作用的局限性

►法律调整的范围是有限的；法的特性与社会生活的现实之间存在着矛盾；法的制定和实施受人的因素的制约；法的实施受政治、经济、文化等社会因素的制约

【分析】法只是众多社会调整手段中的一种，而不是唯一的。法是调整社会关系的重要手段，但并不是唯一手段。国家用以调整社会关系的手段，除法律外，还有经济、政治、行政、思想道德、政策、纪律、习俗、舆论等多种手段。法在社会生活调整中具有主导地位，但是并非所有的问题都可以适用法律。很多社会关系需要由法和其他手段并行调整，在对有些社会关系的调整中，法只能起到辅助作用；而对有些社会关系而言，法并不是有效的调整手段，比如人们的思想、信仰或私生活方面，就不宜采取法律手段加以调控。

作为一种规范，法必然具有抽象性、稳定性等特征，而现实生活中的问题却是具体的、千姿百态和不断变化的。想制定出包罗万象、永久适用的法律只是一个幻想。另外，法还具有保守性，它总是落后于现实生活的变化，而立法者认识能力上的局限性也会使法律存在着某种不合理、不科学的地方。

“徒善不足以为政，徒法不能以自行。”如果没有高素质的立法者，就不可能有良好的法律。即使是制定得很好的法律，也需要合适的人正确地执行和适用，才能真正发挥其作用。如果没有具备良好法律素质和职业道德的专业队伍，法律再好，其作用也是难以发挥的。另外，法律的实施还需要绝大多数社会成员的支持，如果他们缺乏一定的法律意识，缺乏自觉遵守法律的思想道德风尚和习惯，法律也不可能有效地实施。

法总是十分依赖其外部条件，其作用总是容易受到社会因素的制约。主要因素有经济体制、政治体制、执法机关的工作状况、各级领导干部及普通公民的法律观、传统法律文化等。

总之，在认识法的作用的时候，我们应该树立正确的态度，一方面要反对法律万能论，另一方面也要反对法律虚无主义、法律无用论。只有全面地认识法的作用的多样性、复杂性，才能真正推进法治事业，推进社会的法治化建设。

第二节 法的价值

一、法的价值的概念

►法的价值的含义和特征

【分析】法的价值是法存在的伦理正当性依据，它构成一个社会的法律主体尤其是法律职业人的精神存在的核心成分，直接决定着该社会的法律主体的法律思维方式与法律实践。

法的价值是指人对于法律的需要和实践过程中所体现出来的法的积极意义和有用性。它既有价值的基本属性，也同时具有法的价值的自身特性。一般而言，法的价值具有以下基本特征：

(1)法的价值是阶级性与社会性的统一。从主体角度看，法的价值是以人为主体的价值关系，具有阶级性与社会性。人是社会发展的产物，又是特定阶级的一员，人的这种双重身份决定了人在实践中所认识和需要的法的价值的双重性。从客体角度看，法的价值的客体，即法律本身也具有双重性。法既是统治阶级意志的反映，也必须承担社会公共职能。任何把法的价值的阶级性与社会性分离开来、对立起来的做法，都是不可取的。

(2)法的价值是主观性与客观性的统一。法的价值的主观性与客观性的统一源于法律主体的社会实践。就其主观性而言，法的价值是以主体的社会需要为基础的。主体需要的变化和发展会促使法律在满足主体需要的方式和程度上发生相应的变化，法律的存在和发展也始终以主体的主观需要和观念的相应转变为前提。就其客观

性而言，法的价值的主体需要并非凭空产生，而是由主体在社会关系中的地位以及主体的社会实践所决定的，最终是由社会物质生活条件所决定的。

(3)法的价值是统一性与多样性的统一。法的价值基于主体的需求而产生，而主体的需求却是多种多样而且不断发展变化的。不同的社会背景、社会制度之下的人们对于法律这种制度安排的认识、理解 and 需求差别也很大，这就必然导致法律在满足主体需求方面也会相应地多样化，从而使法的价值呈现出复杂多样的状态。生活在同一时代、同一社会的人们总有某种共同的价值追求，甚至生活在不同时代、不同社会的人们也会有某种共同的价值标准，即使是统治阶级所形成的价值体系也必须尊重价值中的一些共性成分。因此，法的价值的多样性与其统一性是并存的。

►社会主义法律价值体系的定义与特征

【分析】社会主义法律价值体系是由社会主义社会中一组与法律的制定和实施相关的价值所组成的系统，它是社会主义法律制度的内在精神，是社会主义核心价值观在法律领域的集中体现。

社会主义法律价值体系体现了社会主义法律制度所追求的目的，其特征主要表现在以下两个方面：(1)社会主义法律价值体系关注人民利益与个人权利的统一性。法律一般通过确定权利义务的方式实现其治理目的，社会主义法律价值体系关怀人的真正需求，在关注人的生存和发展需求的过程中实现人民利益与个人权利的统一。(2)社会主义法律价值体系关注价值之间的协调统一。秩序、安全、自由、平等、人权、正义与效率共同构成了社会主义法律的核心价值（删改：基本价值）。在这些价值之间本身可能存在某些冲突，但社会主义法律价值体系可以实现价值之间的协调，在解决价值冲突时确立统一的确定法律价值的位阶顺序的标准，即以是否满足最广大人民的根本利益为标准。

二、法的主要价值

►秩序；安全；自由；平等；人权；正义；效率

1. 秩序

【分析】秩序是指在一定的时间和空间范围内，事物之间以及事物内部要素之间相对稳定的结构状态。秩序分为自然秩序和社会秩序，良好的社会秩序是社会进步的基础。通过法律建立和维护良好的社会秩序是推进改革和建设的重要前提。

法律秩序就是通过法律调整建立起来的人与人、人与社会之间相对稳定、和谐有序的状态。一方面，法律有助于解决社会纠纷和矛盾，减少冲突和混乱，维护正常社会秩序；另一方面，秩序是消解、缓和社会矛盾和冲突的一个基本参照标准。秩序不只从消极角度来调整 and 解决社会矛盾与纠纷，而且还从积极角度来鼓励社会合作，促进社会和谐。

法律有助于社会秩序的建立与维护。(1)在建立秩序方面，法律制度通常依照人们所向往的理想社会秩序来设计。法律不仅通过赋予社会主体一定的权利和自由来引导社会主体的各种行为，还通过给社会主体施加一定的义务与责任的方式，使之对自身的行为加以必要的克制与约束，以建立相应的社会秩序。(2)在维护社会秩序方面，法律既有助于维护合理的政治统治秩序和权力运行秩序，也有助于维护正常的经济秩序和社会生活秩序。

2. 安全

【分析】（删除：安全的概念是一个复杂而多维的哲学命题，它涵盖了从个体生存到国家和社会稳定的广泛领域。在广义上，）安全可以被理解为一种没有危险、不会发生损失的状态，即个体、集体或系统在面对内外威胁时能够有效抵御风险、维持正常运作和秩序的能力。这种状态不仅关乎物理层面的保护，还涉及心理、社会、经济、政治和法律等多个维度。

法的安全价值是指法律在维护安全方面所发挥的核心作用。在法的各种价值中，安全价值是基础性价值、

底线价值。安全价值为私人领域和公共领域的各种主体的利益与价值的实现奠定了基础。法律通过设定明确的规则 and 标准，为社会成员提供了行为的指南和预期。它不仅规定了哪些行为是被允许的，哪些行为是被禁止的，而且通过制裁机制确保这些规则得到遵守。

法律维护安全的方式多种多样。(1)法律通过**预防和制裁犯罪**来维护社会安全。如通过立法限制枪支的流通，可以降低枪击事件的发生率，从而保护公民的生命安全；通过惩罚犯罪来保障人民的安全。(2)法律通过**保护个人权利来维护个体安全**。如民法典关于隐私权保护的规定确保个人信息不被未经授权的披露或滥用，从而保护个人的隐私安全。(3)法律通过**规范政府行为等各类公权力的行使来维护政治安全**。如宪法和相关国家机关组织法通过规定政府的权力结构和运作机制，限制政府的权力范围，防止权力滥用和腐败现象的发生。

此外，**法的安全价值可以体现在其对社会信任的促进上**。当法律公正地对待所有人，并且能够有效维护秩序时，社会成员之间的互信会增强。这种信任是社会合作与和谐的基础，有助于减少冲突和暴力。~~(删除：如有~~有关商业交易方面法律的存在使得双方能够预期对方的行为，从而降低交易风险，促进经济活动的顺利进行。**法的安全价值还可以体现在其对未来不确定性的管理**。法律通过预见和规范新兴的社会现象，如网络安全、生物伦理、人工智能等领域，来应对未来可能出现的风险和挑战。)法正是作为实现安全目标的关键工具，通过设定规则、维护秩序、保护权利、制约权力等多种方式，为个体和社会的安全提供保障。因此，**构建一个健全的法律体系，确保法律的公正实施，对于提升整个社会的安全水平至关重要。**

3. 自由

【分析】自由是指从受到束缚的状态之中摆脱出来，或不受约束的状态。**法学上的自由是指主体的行为与法律的既有规定相一致或相统一。**其主要特点有：(1)自由意味着主体可以自主选择 and 从事相关行为。(2)自由也表现为主体自主选择的行为必须与既有的法律规定相一致。(3)自由是人的本性，正如马克思所说“自由确实是人的本质”“不自由对人说来就是一种真正的致命的危险”。

法律确认和保障自由。(1)法律确认自由通常采用两种方式：一是以权利和义务规定来设定主体享有自由的范围；二是以权利和义务来设定主体自由的实现方式。(2)法律保障自由的方式也是多样的：首先，法律通过划定国家权力本身的合理权限范围，明确规定公权力正当行使的程序，排除各种非法妨碍；其次，法律对每个主体享有的自由进行界定和限制，防止主体之间对各自自由的相互侵害；再次，法律禁止主体任意放弃自由；最后，法律为各种对主体自由的非法侵害确立救济手段与程序。

4. 平等

【分析】平等主要是社会主体能够获得同等的待遇，包括形式平等与实质平等。

平等具有以下特点：(1)平等是一个历史的范畴，其所表达的内涵**随着社会历史环境和条件的变化而变化**。(2)平等并不等于平均。任何社会内绝对的平均都是做不到的，同时，绝对平均从社会效果来看，也是有害于社会发展的。(3)平等要求排除特权和消除歧视。特权是指基于特殊身份或关系而对社会中的一部分人所给予的特殊对待。歧视则以认可人们天生存在身份与地位的高低贵贱为前提和基础，并把一部分人视为低于其他人。特权与歧视都是对平等的否定，与人类文明格格不入。(4)平等与差别对待是有条件共存的。~~(删除：从人的共性与特殊性角度看，一方面，人与人之间在人格和主体资格上的普遍平等是绝对的，这是形式平等的表现；另一方面，由于人与人之间确实存在着自然和社会的各种差异，因而)~~对具有各种差别的人们给予权利、义务方面的差别对待也是合理的，这有助于实质平等的实现。

法律能确认和保障平等价值的实现。法律一般通过立法、执法和司法等活动来确认和保障平等实现。其基本方式有：(1)法律将平等确立为一项**基本的法律原则**。平等贯穿于一个国家的整个法律体系，如宪法层面、民法和程序法领域确认的平等原则等。(2)法律确认和保障主体**法律地位的平等**。主体地位平等是法律形式平等的最重要的体现，也是实质平等的前提。(3)法律确认和保障**社会财富、资源、机会与社会负担的平等分配**。法律

将前述内容转化为相应的法律权利与义务，并保障其实现。(4)法律公平地分配法律责任。责任自负、责任相称、过错责任为主而无过错责任为辅等，都是责任公平原则的体现。

5. 人权

【分析】人权是人作为人所享有或应当享有的那些权利。人权表达了所有人在人格上的普遍平等观念和固有尊严观念。人权具有与其他权利不同的特点：(1)人权是普遍性的权利。也就是说，人权是普遍地为所有的人平等享有或应当享有的权利。(2)人权是本源性的权利。即人权是其他权利存在的正当性根据和理由，在整个权利体系中属于最基础性的权利。(3)人权是综合性的权利。即人权是包含多项权利内容的复杂的综合性权利体系。人权作为一个开放性的权利体系，其具体权利内容也随着人对自身的认识和理解而不断深化，新的权利类型也将不断地出现。(4)人权是历史发展的产物。马克思曾引用黑格尔的论断：“‘人权’不是天赋的，而是历史地产生的。”人权的历史发展特点从其主体、内容到保障措施等方面均可反映出来。

人权作为法律价值具有非常重要的意义。(1)人权作为法律价值表明了法律对作为主体的人的肯定，即对人的独立且平等的人的尊严的尊重。(2)人权作为法律价值，表明法律的来源、法律运作的各个环节以及法律的根本目的都基于人本身，并以人的现实生活为关注焦点，以人的理想生活为直接目标。(3)人权作为法律价值，既是对法律的精神、原则、规范的直接检验和方向引导，也是对法律的内在品质进行批判的标准和完善的依据。

人权的法律分类，可以从不同的角度或标准进行。比如，从主体角度可以分为个体人权和集体人权。集体人权又可以分为一般社会群体的权利和特殊社会群体的权利。就个体人权来说，按照联合国人权公约的划分，可分为两大类：(1)公民权利和政治权利。如生命权、人身自由与安全权、人格尊严权、隐私权、选举与被选举权，宗教信仰、言论、出版、集会、结社与游行、示威自由等。这类权利和自由保障公民的人身自由与安全，并确保其有效参与国家公共事务。(2)经济、社会和文化权利。如财产权、劳动权、休息权、受教育权、社会保障权等。这类权利与前一类权利相对应，旨在实现对公民的物质和文化利益的保障。

6. 正义

【分析】正义是人类追求的共同理想，也是法律的核心价值。它以利益为依归，是对利益的正当分配。一般认为，作为社会基本结构的社会体制的正义，是最为根本和具有决定意义的正义，是社会的首要正义。

正义可以依不同的标准来分类，如实质正义与形式正义、实体正义与程序正义、抽象正义与具体正义等。但从法学和法律角度看，实质正义与形式正义的分类以及相应的实体正义与程序正义的分类更为重要。实体正义是指通过法律上的实体权利和义务来公正地分配社会利益与负担的法律规则所体现出来的正义；程序正义是指为了实现法律上的实体权利与义务而公正地设定一系列必要程序所体现出来的正义。

正义具有以下特点：(1)正义既有普遍性又有特殊性。其普遍性是指正义所反映的是人类文明的基本共识与人类生活的根本理想；正义的特殊性是指这种反映根本理想的普遍正义，始终只能是在具体的和特殊的人类生活境况之中存在并得到体现。(2)正义既具有超时代性又具有时代性。正义是与人的存在和发展相一致的，也反映了人作为同一“类”所共同的情感、理想和需求，这就是正义的超时代性；正义的时代性表现为具体的不同时代的人们对正义的认识、理解和态度又是彼此有所区别的。(3)正义既具有客观性又具有主观性。正义的客观性是指它是人类作为一个整体所具有的共性，这些共性不以具体的人的各种自然和社会差异因素的存在而发生改变；正义的主观性是指现实生活中正义观念的某些具体内容始终与人们的具体生活状况及其感受直接相关，因而体现出强烈的主观性。

正义作为法律价值的作用是：(1)正义是法律的存在根据和评价标准。法律的好坏需要评价标准，正义就是检验现实中法律好坏的根本标准和依据。(2)正义是法律发展和进步的根本动因。正义始终引导着包括法律在内的社会基本制度革故鼎新，使法律等社会制度最大限度地符合正义的时代要求。(3)正义适用于具体的法律实践。作为法的价值的正义往往在法律适用与法律推理中成为解释法律的重要根据，成为解决疑难案件、填补法律空

白或漏洞的依据。

法律对正义的保障表现为：(1)法律通过将社会生活的主要领域及其重要的社会关系纳入法律之内，使正义融入法律规范与制度之中，实行法治化治理，严格依法办事，从而全面促进和保障社会正义；(2)通过法律权利和法律义务机制，公正地分配社会的利益和负担，并设定公正的程序来保障，使实体正义与程序正义得以通过立法来落实；(3)通过法律效果上的认可与惩罚机制，在执法与司法上保障实体正义与程序正义的实现。

7. 效率

【分析】效率，也称效益，是指社会或个人通过一定的投入而获得收益最大化的比率。法的效率价值，即法所具有或应当具有的促进社会财富增长和活动便利并满足人们对物质的需求和便利条件的价值。

法律是通过有利于资源优化配置的权利义务分配来实现这一价值的。通常其实现效率价值的方式包括：(1)确认并保障主体的物质利益，从而鼓励主体增进物质利益；(2)确认和保护产权关系，鼓励人们为着效益的目的而占有、使用或转让财产；(3)确认、保护、创造最具有效率的经济运作模式，使之容纳更多的生产力；(4)承认和保护知识产权，使人类创造性的智力成果最大化的发展；(5)通过设立法律责任、赔偿与惩罚等机制，使社会上的违法、犯罪行为最大限度地减少，从而使人们的人身安全与社会财富总量不受损害或少受损害，从而使社会效率得到一定程度的保障。

三、法的价值的冲突与解决

►法的价值冲突的表现；法的价值冲突的解决原则

【分析】法的各种价值包括基本价值之间有时会发生矛盾，从而导致价值之间的相互冲突。例如，要保证社会正义的实现，在很大程度上就必须以牺牲效率作为代价；同样，在平等与自由之间、秩序与自由之间也都会出现矛盾，甚至会出现必须选择其一而舍弃另一个的局面。

此外，从主体角度看，法的价值冲突主要有三种情况：(1)个体之间法律所承认的价值冲突，如个人自由可能导致与他人利益的冲突；(2)共同体之间发生的价值冲突，如国际人权与一国主权之间的冲突；(3)个体与共同体之间的价值冲突，典型的如个人自由与社会秩序之间常常会出现的矛盾情形。

由于立法不可能穷尽社会生活的一切形态，在个案中更可能因为特殊情形的存在而使价值冲突难以避免，因而必须形成相关的平衡或解决冲突的规则或原则。

解决价值冲突的原则一般有：(1)价值位阶原则。即指在不同位阶的法律价值发生冲突时，在先的价值优于在后的价值。就法律价值而言，前述法律的主要价值或基本价值，如秩序、安全、利益、自由、平等、人权、正义等，与那些非基本的法律价值的位阶顺序不是并列的。当基本价值与非基本价值之间发生冲突时，应以基本价值为优位；而基本价值之间有冲突时，人权和正义作为法治保障的核心和标尺，具有重要的价值地位，这与我国宪法确立的“国家尊重和保障人权”的原则精神相符合，它也是正义原则的具体体现。(2)个案平衡原则。即指在处于同一位阶上的法律价值之间发生冲突时，必须综合考虑主体之间的特定情形、需求和利益，使个案的解决能够适当兼顾双方的利益。(3)比例原则。即指为保护某种较为优越的法律价值须侵害某一法益时，不得逾越达此目的所必要的程度。如为了维护公共秩序，必要时可能会实行交通管制，但应尽可能实现最小损害或最少限制，以保障社会上人们的自由。(4)人民根本利益原则。这是当代中国社会主义法律价值体系中的根本价值原则，即以是否满足最广大人民的根本利益为标准，来解决一些存在重大疑难的法律价值冲突问题。它也可以作为前述价值位阶原则的补充和保障。

第五章 法的渊源、效力与分类

第一节 法的渊源

一、法的渊源的概念

►法的渊源的含义

【分析】法的渊源，又称“法源”或“法律渊源”，在中外法学中，法的渊源一词有多种含义，如法的历史渊源、法的理论渊源、法的形式渊源、法的文件渊源等。法的渊源可以分为实质意义上的渊源和形式意义上的渊源。法的实质意义上的渊源是指法的真正来源、根源和发源，是法得以产生的一定生产方式下的物质生活条件；法的形式意义上的渊源是指法的创制方式和表现形式，即法的效力渊源。我们这里所说的法的渊源是形式意义上的渊源。某一行为规则之所以被认为具有法律规范的效力，就是因为它是被以特定方式创制或认可的，具有特定的表现形式。因此，不同种类的法律规范因其创制主体、创制方式和表现形式的差异而具有不同的效力等级。

二、法的渊源的分类

►法的正式渊源；法的非正式渊源

【分析】法的形式渊源可以分为直接渊源和间接渊源。直接渊源又称正式渊源或法定渊源，是指国家机关制定或认可的具有法律效力的各种规范性法律文件。间接渊源又称非正式意义上的渊源或非法定渊源。

法的正式渊源通常包括制定法、习惯法、国际条约和判例法等。制定法又称成文法，系指由国家机关依照一定程序制定颁布的，通常表现为条文形式的规范性法律文件。习惯法指经有权的国家机关以一定方式认可，赋予其法律规范效力的习惯和惯例。国际条约是两个或两个以上国家就共同关心的问题确定相互权利义务的协议。在不同法系的国家中，判例作为法律渊源的情况是不同的，在大陆法系国家中，判例一般不是正式渊源，或仅是非正式渊源，制定法是法律的主要渊源；而在普通法系国家中，除了制定法外，判例法也是重要的正式渊源。

法的非正式渊源是指那些具有法律意义的准则和观念，这些准则和观念尚未在正式法律中得到权威性的明文体现，如正义标准、理性原则、公共政策、习惯、法律学说、道德原则等。

三、当代中国法的渊源

►宪法；法律；行政法规；监察法规；地方性法规；民族自治法规；经济特区法规；特别行政区的规范性法律文件；规章；军事法规与规章；国际条约和国际惯例

【分析】当代中国的法律渊源比较复杂，对作为主体，即实行社会主义制度的中国内地的法律渊源而言，可以概括为以宪法为核心、以制定法为主的法律渊源。正式意义上的渊源有：宪法、法律、行政法规、监察法规、地方性法规、民族自治法规、经济特区法规、特别行政区的规范性法律文件、规章、军事法规与规章、国际条约和国际惯例等。

1. 宪法

宪法是我国的根本法，是我国社会主义法律的基本渊源。宪法的内容与普通法律不同，它规定国家和社会生活中最基本、最重要的问题。宪法在我国法律渊源体系中居于首要地位，具有最高的法律效力。宪法是我国全部立法工作的基础、根据和最基本的效力来源，一切法律、法规和其他规范性文件，都不得与宪法的规定相抵触。宪法在制定和修改程序上也不同于普通法律。

2. 法律

在我国，作为法律渊源之一的“法律”一词是在狭义上使用的，专指由国家最高权力机关及其常设机关，即全国人民代表大会及其常务委员会制定颁布的规范性文件，其法律效力仅次于宪法。根据现行宪法的规定，法律又可以分为基本法律和基本法律以外的法律。**基本法律是由全国人民代表大会制定和修改，比较全面地规定和调整国家及社会生活某一方面的基本社会关系的法律**，包括关于刑事、民事、国家机构和其他方面的基本法律；基本法律以外的法律，又称**非基本法律**，是指由**全国人民代表大会常务委员会制定和修改的，规定和调整除由基本法律调整的社会关系以外的，关于国家和社会生活某一方面具体社会关系的法律**。（删除：此外，全国人民代表大会及其常务委员会发布的具有规范性内容的决定和决议，也属于法律渊源。）

3. 行政法规

行政法规专指由国家最高行政机关，即国务院，在法定职权范围内为实施宪法和法律而制定的有关国家行政管理的规范性文件。在我国，行政法规是一种重要的法律渊源，其效力仅次于宪法和法律。依宪法和组织法规定，国务院还有权发布决定和命令，其中具有规范性内容的，也是法律渊源，与行政法规具有同等效力。

4. 监察法规

监察法规，是国家监察委员会根据宪法和法律制定的一种规范性文件。监察法规可以就下列事项作出规定：**(1)为执行法律的规定需要制定监察法规的事项；(2)为履行领导地方各级监察委员会工作的职责需要制定监察法规的事项**。监察法规不得与宪法、法律相抵触。监察法规应当经国家监察委员会全体会议决定，由国家监察委员会发布公告予以公布。监察法规应当在公布后的三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。

5. 地方性法规

地方性法规指省、自治区、直辖市和设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本地区具体情况和实际需要，在法定权限内制定发布的适用于本地区的规范性文件。根据我国《宪法》和《立法法》的规定，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规；**设区的市的人民代表大会及其常务委员会**根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对**城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理**等方面的事项制定地方性法规；**自治州的人民代表大会及其常务委员会**可以行使**设区的市制定地方性法规的职权**。

6. 民族自治法规

民族自治法规包括**自治条例**和**单行条例**两类。根据《宪法》和《立法法》的规定，民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例。**自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会批准后生效。**

7. 经济特区法规

经济特区所在地的省、市的人大及其常委会根据全国人大的授权决定，制定（删除：经济特区）法规，在经济特区范围内实施。**经济特区法规在经济特区范围内优先于行政法规、具有隶属关系的地方性法规和地方政府规章适用。经济特区法规与法律相矛盾并不必然失效，而要由全国人大常委会来裁决。**

8. 特别行政区的规范性法律文件

特别行政区基本法属于基本法律，它不同于一般法律的特点在于它只适用于特别行政区。特别行政区的规范性法律文件是根据宪法和特别行政区基本法，在特别行政区内施行的法律。依照现行宪法和特别行政区基本法的规定，特别行政区的立法机关享有自己的专属立法权，可以根据特别行政区基本法的规定和法定程序制定、修改和废除法律。**特别行政区的立法机关制定的法律须报全国人民代表大会常务委员会备案。备案不影响该法**

律的生效。

9. 规章

规章可以分为两类：一是“**部门规章**”，即国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构以及法律规定的机构，根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内发布的规章。二是“**地方政府规章**”，即省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的人民政府，根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规制定的规章。

10. 军事法规与规章

中央军事委员会根据宪法和法律，制定军事法规。（删除：中央军事委员会各职能部门、各战区、各军兵种、武警部队，可以根据法令与军事法规、决定、命令制定军事规章。）军事法规、军事规章在武装力量内部实施，（删除：在军事法院、军事检察院适用。）

11. 国际条约和国际惯例

国际条约是两个或两个以上国家就政治、经济、贸易、军事、法律、文化等方面的问题确定其相互权利义务关系的协议。除条约外，国际条约的名称还包括公约、协定、和约、盟约、换文、声明、公报等。国际条约是国际法的重要渊源，本不属于国内法范畴，但我国签订或者加入的国际条约，具有与国内法一样的约束力，也是我国的法律渊源之一。

国际惯例是在国际交往中逐渐形成的一些习惯做法和先例，通常是不成文的，最初被某些国家长期反复使用，后来为各国所接受并承认其法律的效力，并成为国际法的主要来源之一。国际商会曾先后多次公布了具有国际性的解释贸易术语的通则，这一通则便成了一种国际贸易惯例。因此，国际惯例也构成我国的法律渊源之一。

►习惯；政策；指导性案例

【分析】当代中国法的非正式渊源，主要包括习惯、政策、作为办案参考的指导性案例等。

1. 习惯

习惯是指人们在长期的生产、生活中约定俗成的一种行为规范。除了那些经过国家认可的从而成为习惯法的以外，其他习惯均为非正式渊源。法的渊源是发展的，在不同时代和国情之下的法的渊源中，习惯的地位多有不同。如古罗马，习惯与最高裁判官的告示、法学家的著作都是法的渊源；中国封建社会有关的封建纲常礼教和习惯，也“相沿成俗”地成为其渊源。当代中国社会中来自民间的、行业的、各民族的一些习惯等可以成为法的非正式渊源。

2. 政策

政策种类较多，目前，我国有党的政策和国家政策、中央政策和地方性政策、根本的大政方针与具体领域的指导性政策之分。除了那些上升为国家法律的政策外，其他政策在某种意义上讲均为我国非正式的法的渊源，其表现形式包括以红头文件形式呈现的各类政策性文件，它们或多或少在某些时候和某些地方发挥效用。

3. 指导性案例

指导性案例是新世纪我国法治实践中产生的新生事物，它试图为案件裁判提供统一的标准，为法官或检察官的自由裁量权提供一个尺度范围，同时也促使裁判者在裁判过程中准确适用法律。目前指导性案例包括最高人民法院和最高人民检察院分别发布的多批次指导性案例，它没有经过立法机关发布，但它在实际司法实践中已经开始发挥一些作用，已成为我国非正式法律渊源的组成部分。

第二节 法的效力

一、法的效力的概念与效力等级

►法的效力的含义；法的效力等级的一般原则

【分析】法的效力，是指法律对法律主体的应然约束力或拘束力。狭义上的法的效力是指规范性法律文件的效力，广义上的法的效力还包括非规范性法律文件的效力。一般认为，法的效力主要包括对人的效力、空间效力和时间效力三个方面。

法的效力层次是指规范性法律文件之间的效力等级关系。一般而言，法的效力层次可以概括为以下几点：上位法优于下位法，即规范性法律文件的效力层次决定于其制定主体的法律地位，行政法规的效力高于地方性法规。

特别法优于一般法，指在同一位阶的法律之间，特别法优于一般法。即同一事项，两种法律都有规定的，特别法比一般法优先，优先适用特别法。

新法优于旧法，即在同一位阶的法律之间，两者对同一事项规定不一样的，新颁布的法律优先适用。应该注意的是，这里所说的新法优于旧法适用所针对的行为或事件，均是在这些法律生效期间所发生的，与后面法的时间效力所提及的法不溯及既往原则所针对的行为或事件发生的时间完全不同。

二、法的效力范围

►法对人的效力

【分析】法对人的效力是指法对谁有效力，适用于哪些人。在世界各国的法律实践中，先后采用过四种对人效力的原则：属人主义、属地主义、保护主义和折中主义。属人主义，即法律只适用于本国人，不论其身在国内还是国外。对外国人，即便其身在该国内也不适用。属地主义，即不论本国人或外国人，凡居住在本国管辖领域内的人一律适用本国法律。保护主义，即以维护本国利益为基础，不管是什么国籍的人，在什么地方行为，只要侵害了本国的利益，就适用本国的法律。折中主义，即以属地主义为主，与属人主义、保护主义相结合的原则。这是近代以来多数国家所采用的原则，我国亦然。凡是具有中华人民共和国国籍的人，都是中国公民。中国公民在中国领域内一律适用中国法律。

中国公民在国外的法律适用问题，原则上仍适用中国法律，但当中国法律与所在国的法律发生冲突时，要区别不同的情况，依据具体的国际条约、协定及国内法的规定，来确定是适用中国法律还是适用外国法律。

外国公民广义上指具有某一外国国籍的自然人和无国籍人；狭义上仅指具有外国国籍的自然人。为便于理解，本部分的“外国公民”采用广义上的内涵。中国法律对外国公民的适用包括两种情况：一是对在中国境内的外国公民的适用问题，二是对中国境外的外国公民的适用问题。外国公民在中国境内，除法律另有规定外，一般适用中国法律。中国法律既保护他们在中国的合法权益，又依法处理其违法问题。若外国公民在中国境外对中国国家或中国公民犯罪，按中国刑法规定的最低刑为3年以上有期徒刑的，可以适用中国刑法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

►法的空间效力

【分析】法的空间效力，是指法在哪些地域范围内发生效力的问题。一般说来，在一个主权国家，法适用于主权管辖范围内的全部领域，它包括领陆、领海、领空和底土，以及作为领土延伸的驻外使馆、该国停泊在境外的船舶及境外飞行器。

由于法的制定机关不同，具体法的空间效力是有所区别的。一般来说，凡中央国家机关制定的规范性法律文件在全国有效，凡是地方国家机关制定的规范性法律文件，只能在制定机关所管辖的范围内生效。

所谓法的域外效力是法的效力及于国家主权管辖的领域之外。有的法不仅在国内生效，而且根据国家主权原则还往往规定适用于国外发生的特定事件和行为。例如，我国《刑法》从维护国家统一和国家主权原则出发，规定犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪，我国法院都可以行使管辖权。

►法的时间效力

【分析】法的时间效力是指法何时生效、何时终止效力以及法对其颁布实施前的事件和行为有无溯及力的问题。

法生效的时间主要有三种形式：自法的颁布之日起生效；由法来规定具体生效时间；规定法在颁布后符合一定条件时生效。

法的效力终止是指通过明令废止或默示废止的形式而终止某一法律的效力。我国法的效力终止的形式有明示废止和默示废止。明示废止是指在新法或其他法律文件中明文规定废止旧法。默示废止是指在适用上出现新法和旧法冲突时，适用新法而使旧法在事实上废止。

法的溯及力又称法律溯及既往的效力，是指新法颁布后，对其生效前的事件和行为是否适用的问题。如果适用，则具有溯及力；如果不适用，则不具有溯及力。一般情况下，我国法律坚持“法不溯及既往”的原则，这一原则也是各法治国家通行的法律原则。但这个原则也有例外，特别是在刑法中，目前各国采用的通例是“从旧兼从轻”原则，即新法原则上不溯及既往，但新法不认为犯罪或罪轻的，可以适用新法。我国现行刑法也采用“从旧兼从轻”的原则。

第三节 法的分类

一、法的一般分类

►成文法与不成文法；实体法与程序法；根本法与普通法；一般法与特别法；国内法与国际法

【分析】法的分类就是从不同的角度，按照不同的标准，将法律划分为若干不同的种类。从一定意义上讲，法的历史类型、法系、部门法、法律的渊源等都可以看作对法的分类。法的一般分类是指世界上所有国家共同适用的法的分类。它主要有五类：成文法与不成文法，实体法与程序法，根本法与普通法，一般法与特别法，国内法与国际法。

成文法与不成文法是以法律创制方式和表达形式的不同为标准对法律进行的分类。成文法是指由国家特定机关制定和公布，并以成文形式出现的法律，因此又称制定法。不成文法是指由国家认可其法律效力，但又不具有成文形式的法，一般指习惯法。不成文法还包括同制定法相对应的判例法，即由法院通过判决所确定的判例和先例，它是不以条文(成文)形式出现的法律，因此也是不成文法的主要形式之一。

实体法与程序法是以法律规定内容的不同为标准对法律进行的分类。实体法是指以规定和确认权利与义务或职权与职责为主的法律，如民法、刑法、行政法等。程序法是指以保证权利和义务得以实施或职权和职责得以履行的有关程序为主的法律，如民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法、立法程序法等。实体法和程序法的分类是就其主要方面的内容而言的，它们之间也有一些交叉，实体法中也可能涉及一些程序规定，程序法中也可能有一些涉及权利、义务、职权、职责等内容的规定。

根本法与普通法是根据法律的地位、效力、内容和制定主体、程序的不同而对法律进行的分类。这种分类通常只适用于成文宪法国家。根本法即宪法，它在一个国家中享有最高的法律地位和最高的法律效力；普通法指宪法以外的法律，其内容一般涉及调整某一类社会关系，法律地位和法律效力低于宪法，其制定和修改必须符合根本法，程序也较根本法简单。

一般法与特别法是按照法律适用范围的不同对法律所作的分类。一般法是指针对一般的人和事在不特别限定的地区和期间内普遍适用的法律；特别法是指针对特定人、特定事或特定地区、特定时间内适用的法律。针对特定人的法，如警察法、教师法；针对特定事的法，如国籍法、教育法；在特定地区适用的法，如民族区域自治法；在特定时间适用的法，如戒严法等。一般法和特别法这一分类是相对而言的。

国内法与国际法是按照法律的创制主体和适用主体的不同而作的分类。国内法是指在一主权国家内，由特定国家法律创制机关创制的并在本国主权所及范围内适用的法律；国际法则是由参与国际关系的国家或组织通过协议制定或认可的，并适用于国家之间的法律，其形式一般是国际条约和国际协议等。国内法的法律关系主体一般是个人或组织，国家仅在特定法律关系中成为主体，而国际法的法律关系主体主要是国家。

二、西方两大法系的法律分类

►公法与私法；普通法与衡平法

【分析】西方两大法系根据其历史传统的不同将法律分别区分为公法与私法，普通法与衡平法。

公法与私法的分类源于古罗马法，它是在民法法系中适用的一种法律分类。古罗马法学家乌尔比安提出，公法是关于罗马国家的法律，私法是关于个人利益的法律。现代西方法学著作认为，公法主要是调整国家与公民之间关系的法律，私法主要是调整个人之间的关系。一般认为，宪法、刑法、行政法属于公法，民法、商法属于私法。在当代，公法与私法的界限日益模糊，出现了兼备公法和私法特征的法律，如经济法。

普通法与衡平法是普通法法系的一种法律分类。这里的普通法，不同于前文所讲的法律的一般分类中的普通法概念，而是专指英国在11世纪后由法官通过判决形式逐渐形成的适用于全英格兰的一种判例法；而衡平法是指英国在14世纪后对普通法的修正和补充而出现的一种判例法。今天，我国香港特别行政区的法律也适用这种分类。

第六章 法律要素与法律体系

第一节 法律要素

一、法律规则

►法律规则的含义和特点

【分析】法律是由法律规则、法律原则和法律概念三者共同构成的，其中法律规则是构成法律的基本单位，与其他要素相比，具有微观指导性、可操作性较强、确定性程度较高、可预测性等特征。

法律规则，又称法律规范，是采取一定的结构形式具体规定人们的法律权利、法律义务以及相应的法律后果的行为规范。

与其他社会规范相比较，法律规则的基本特征主要有：第一，法律规则是一种一般的行为规则，它使用同一标准，对属于其效力范围内的主体行为进行指导和评价，这一特点使它有别于任何个别性调整措施；第二，法律规则规定了一定的行为模式，是一种命令式的必须遵守的行为规则，这使它区别于不包含确定行为方案或仅具有倡导性的口号或建议；第三，法律规则是由国家制定或认可的行为规则，具有强烈的国家意志性，这是它区别于其他社会规则的最基本特征；第四，法律规则规定了社会关系参加者在法律上的权利和义务以及违反规则要求时的法律责任和制裁措施；第五，法律规则有明确的、肯定的行为模式，有特殊的构成要素和结构，是一种高度发达的社会行为规则。所有这些特征使法律规则具有其他调整措施所不具备的品质，成为对社会关系进行法律调整的权威性根据。

应当把**法律规则和法律条文区别开来**。法律规则是法律条文的内容，法律条文是法律规则的表现形式。并不是所有的法律条文都直接规定法律规则，也不是每一个法律条文都完整地表述一个规则或只表述一个法律规则。有时候一个法律规则可以包括在几个法律条文中，也有时候一个法律条文可能包含了几个法律规则。

►**法律规则的种类：授权性规则、义务性规则和权义复合性规则；强行性规则与任意性规则；确定性规则、委任性规则和准用性规则**

【分析】按照**规则的内容**规定不同，法律规则可以分为授权性规则、义务性规则和权义复合性规则。授权性规则是指规定人们有权做一定行为或不做一定行为的规则，即规定人们的“**可为模式**”的规则。授权性规则的作用在于赋予人们以一定的权利去设立、变更、终止他们的法律地位或法律关系，其特点是为权利主体提供一定的选择自由，对于权利主体来说不具有强制性。授权性规则又可分为**鼓励性规则**和**容许性规则**。义务性规则是指在内容上规定人们的法律义务，即有关人们应当做或不应当做某种行为的规则。与授权性规则相比，义务性规则表现为对义务主体的约束。义务性规则具有强制性、必要性和利他性。义务性规则又可以分为命令性规则和禁止性规则两种。命令性规则是指规定人们的**积极义务**，即人们必须或应当作出某种行为的规则；禁止性规则是指规定人们的**消极义务**，即禁止人们做一定行为的规则。权义复合性规则是指兼具授予权利、设定义务两种性质的法律规则。法律授予公权力的规则通常是权义复合性规则。

按照**规则对人们行为规定和限定的范围或程度不同**，可以把法律规则分为强行性规则和任意性规则。强行性规则是指内容规定具有强制性，不论人们的意愿如何，都必须加以适用的规则。一般来说，公法类法律，特别是行政法、刑法等，主要涉及公共利益，强行性规则较多。任意性规则是指在一定范围内，允许人们自行选择或协商确定法律关系中的权利义务内容的法律规则。在民商法等私法类法律中，主要涉及私人利益，任意性规则较多。强行性规则和任意性规则的划分是相对的。**公法中也有任意性规则，私法中也有强行性规则。**

按照**法律规则内容的确定性程度**不同，可以将法律规则分为确定性规则、委任性规则和准用性规则。确定性规则是指内容已明确肯定，无须再援引或参照其他规则来确定其内容的法律规则。法律条文中绝大多数法律规则都属于此种规则。委任性规则是指内容尚未确定，而只规定某种概括性指示，由相应国家机关通过相应途径或程序加以确定的法律规则。准用性规则是指内容本身没有规定人们具体的行为模式，可以援引或参照其他相应内容规定的规则。

除了上述三种分类外，常见的分类还有**依据法律规则功能的不同**，将法律规则分为调整性规则和构成性规则。调整性规则是对已有行为方式进行调整的规则，它的功能在于控制行为。调整性规则调整的行为先于规则本身产生，比如交通法规，人们的交通行为先于交通法规产生。调整性规则占法律规则的大多数。构成性规则是组织人们按照规则规定的行为去活动的规则，规则所指定的行为在逻辑上依赖于规则本身。比如设定某一机构的规则就属于构成性规则。

►**法律规则的逻辑结构：假定(条件)；行为模式；法律后果**

【分析】法律规则具有内在的严密的逻辑结构。通说认为，法律规则主要由假定(条件)、行为模式、法律后果三个要素组成。

假定(条件)是规则中关于适用该规则的条件规定，即法律规则在什么时间、空间对什么人适用以及在什么情境下对人的行为有约束力的问题。它包含两个方面：一是**法律规则的适用条件**，其内容是法律规则在什么时间生效，在什么地域生效以及对什么人生效等；二是**行为主体的行为条件**，其往往是法律关系产生、变更或消灭的事实规定，内容包括**行为主体的资格构成**(行为主体的国籍、权利能力、行为能力、免责条件等)和**行为的情境条件**(行为的时间、地点、程序和状态等)。在特定法律条文中有可能省略假定(条件)这一要素，或将其规定在其他条文中，以求文字表达简明扼要。但是省略并不意味着假定(条件)不存在，我们可以根据法律规则的内在逻辑，从法律条文的上下文或若干法律条文的内容规定推导出假定(条件)。

行为模式是指法律规则中关于行为的规定，即法律关于允许做什么、禁止做什么和必须做什么的规定，它是从人们大量的实际行为中概括出来的法律行为要求。根据行为要求的内容和性质不同，法律规则中的行为模式分为三种：可为的模式、应该为的模式和不得为的模式。与此相对应的三种法律规则分别是授权性法律规则、命令性法律规则和禁止性法律规则。命令性法律规则和禁止性法律规则合称为义务性法律规则。

法律后果是指法律规则中对遵守规则或违反规则的行为予以肯定或否定评价的规定。假定(条件)、行为模式是法律后果的前提，法律后果是对人们遵守或违反假定(条件)和行为模式的认定。根据人们对行为模式的实际行为的不同，法律后果又分为肯定性法律后果和否定性法律后果两种。前者是法律规则中规定人们按照行为模式的要求行为而在法律上予以肯定的后果，它表现为法律规则对人们行为的保护、许可或奖励；后者是法律规则中规定人们不按照行为模式的要求行为而在法律上予以否定的后果，它表现为法律规则对人们行为的制裁、不予保护、撤销、停止，或要求恢复、补偿等。法律后果是任何法律规则都不可缺少的要素，但在立法实践中，法律条文一般不明确表述合法的后果，因为根据行为模式，人们可以直接推知该法律后果。违法的后果实际上规定了人们违反法律所应承担法律责任的后果，必须在立法上予以明文规定。

在逻辑结构上，任何一个完整的法律规则都是由假定(条件)、行为模式和法律后果三部分构成的，尽管它们往往不表现于同一个条文当中，或者有些法律规则在表现形式上只有行为模式和法律后果两项要素，而假定(条件)这一要素被省略了。

二、法律原则

►法律原则的含义

【分析】法律原则是指可以作为法律规则的基础或本源的综合性、稳定性原理和原则。法律原则可以是非常抽象的，例如，法律面前人人平等原则、无罪推定原则等；也可能是具体的，例如，任何人不能做自己案件的审判者。法律原则本身不是法律规则，它既没有规定确定的事实状态，也没有规定具体的法律后果，但是在创制、理解或适用法律的过程中，法律原则是必不可少的。法律原则的作用主要有三个：一是为法律规则和概念提供基础或出发点，对法律的制定具有指导意义，对理解法律规则也具有指导意义；二是法律原则有时可以作为疑难案件的断案依据，以纠正严格执行实在法可能带来的不公；三是填补规则可能存在的漏洞。

►法律原则的种类：政策性原则与公理性原则；基本原则与具体原则；实体性原则与程序性原则

【分析】按照法律原则产生的基础不同，可以把法律原则分为政策性原则和公理性原则。政策性原则是国家关于社会发展、进步的决策、指示、决定及目的、目标。如我国宪法中规定的“推行计划生育”的原则等。政策性原则具有针对性、民族性和时代性。公理性原则是从社会关系本质中产生的，得到广泛承认并被奉为法律的公理。如法律面前人人平等原则、无罪推定原则等，它们在国际范围内具有较大的普适性。

按照法律原则对人的行为及其条件之覆盖面的宽窄和适用范围大小，可以把法律原则分为基本原则和具体原则。基本原则是整个法律体系或某一法律部门所适用的、体现法的基本价值的原则，如宪法所规定的各项原则。具体原则是在基本原则指导下适用于某一法律部门中特定情形的原则，如英美契约法中的要约原则和承诺原则等。

按照法律原则涉及的内容和问题不同，可以把法律原则分为实体性原则和程序性原则。实体性原则是直接涉及实体性权利和义务等的原则，宪法、民法、刑法、行政法中所规定的多数原则就属于此类。程序性原则是直接涉及程序法问题的原则，如诉讼法中规定的辩护原则、无罪推定原则等。

►法律原则与法律规则的区别

法律原则与法律规则在内容、适用范围、适用方式上存在区别：在内容上，法律规则的规定是明确具体的，而法律原则不预先设定明确的、具体的假定条件，更没有设定明确的法律后果，其要求比较笼统、模糊。在适

用范围上，法律规则只适用于某一类型的行为，而法律原则具有宏观的指导性，其适用范围比法律规则宽。在适用方式上，法律规则是以“全有或全无的方式”应用于个案当中的，如果一条规则所规定的事实是既定的，或者这条规则是有效的，在这种情况下，必须接受该规则所提供的解决办法。而法律原则的适用则不同，它不是以“全有或全无的方式”应用于个案当中的，当两个原则在具体的个案中冲突时，法官必须根据案件的具体情况及有关背景在不同强度的原则间作出权衡。不同强度的甚至冲突的原则都可能存在于同一部法律之中。

三、法律概念

►法律概念的含义

【分析】法律概念是法律的构成要素之一，是对各种法律事实进行概括，抽象出它们的共同特征而形成的权威性范畴。法律概念与日常生活用语中的概念不同，它具有明确性、规范性、统一性等特点。法律概念的功能主要体现在三个方面：一是表达功能，法律概念间的连接使法律得以表达，没有法律概念，法律是难以想象的；二是认识功能，法律概念使人们得以认识和理解法律，不借助法律概念，人们便无法认识法律的内容，难以进行法律交流，更无法在此基础上进行法律实践活动；三是改进法律、提高法律科学化程度的功能，丰富而明确的法律概念可以提高法律的明确化程度和专业化程度，使法律成为专门的工具，使法律工作成为独立的职业。法律概念与法律规则和法律原则同等重要。

►法律概念的种类

【分析】按照法律概念所涉及的因素，可将其分为四类：主体概念，这是用以表达各种法律关系主体的概念，如公民、法人、原告、行政机关等；关系概念，这是用以表达法律关系主体间权利、义务关系的概念，如所有权、抵押权、交付义务、赔偿责任等；客体概念，这是用以表达各种权利、义务所指向的对象的概念，如动产、主物、支票等；事实概念，这是用以表达各种事件和行为的概念，如失踪、不可抗力、违约等。

依其所涉及的内容，法律概念可以分为涉人概念、涉事概念、涉物概念。法律概念还可以按涵盖范围大小，分为一般法律概念和部门法律概念。

第二节 法律体系与法律部门

一、法律体系的概念

►法律体系的含义与特点

【分析】法律体系，是指一国的部门法体系。它是将一国现行的全部法律规范根据一定的标准和原则划分成不同的法律部门，并由这些法律部门所构成的具有内在联系的统一整体。因此，就法律体系的形式特点而言，它是由一国现行法律规范构成的体系，既不包括具有完整意义的国际法范畴，也不包括已经宣布废止的法律和尚未制定或者虽然制定颁布，但尚未生效的法律。同时，它又是由不同的部门法构成的有机整体。

二、法律部门的划分标准与原则

►法律部门的含义

【分析】法律部门又称部门法，是指一个国家根据一定原则和标准划分的本国同类法律规范的总称。法律部门也是法律分类的一种形式，法律分类是指根据一定的标准和原则对一国现行全部法律规范所作的分类。通常凡是调整同一种类社会关系的法律规范的总和即构成一个相对独立的法律部门，例如调整平等主体之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和即构成民法部门，调整有关犯罪与刑罚的法律规范构成刑法部门等。

法律部门与法律制度是两个既有联系又有区别的概念。法律制度也是由同类法律规范构成的，与部门法是一种交叉关系。一种法律制度可能分属于几个法律部门，如财产所有权制度，就涉及宪法、民法、经济法、刑法和诉讼法等多个法律部门；一个法律部门也可能包含多个法律制度，如作为部门法的刑法就包括了死刑制度、假释制度等多个法律制度。法律部门与规范性法律文件也是两个相互联系又相互区别的概念。规范性法律文件是表现法的内容的形式或者载体，法律部门就是由规范性法律文件构成的。但是，法律部门不等于规范性法律文件。一个法律部门往往是由许多个规范性法律文件构成的。有时候，规范性法律文件的名称与部门法的名称是一致的，如“宪法”，可以是作为一个规范性法律文件的《中华人民共和国宪法》的简称，也可以是作为一个法律部门的宪法部门，当然它还意味着一种作为法的渊源的宪法。需要指出的是，宪法部门除了包括《中华人民共和国宪法》外，还包括《全国人民代表大会组织法》《民族区域自治法》《国籍法》等与宪法制度有关的法律。在许多情况下，部门法的名称与规范性法律文件的名称并不对应。例如行政法部门、经济法部门、军事法部门等就没有一个相同名称的规范性法律文件与之相对应。

法律部门的特征：第一，构成一国法律体系的所有部门法是统一的，各个部门法之间是协调的。比如我国法律部门都是统一于宪法基础之上的。第二，各个法律部门之间既相互联系又相对独立，它们的内容是有区别的。第三，各个法律部门的结构和内容基本上是确定的，但又是相对的和变动的。第四，法律部门是主客观相结合的产物。一方面，法律部门的划分离不开客观的社会关系，它有客观的基础；另一方面，法律毕竟是人们尤其是立法者主观活动的产物，法律部门的划分又带有主观的因素。

所以，法律部门的划分，虽然有着客观的基础，但是最终还是人们主观活动的产物。

►法律部门的划分标准

【分析】法学界一般认为，法律调整的对象(即社会关系)和法律调整的方法是划分法律部门的两个主要标准。

法律调整的对象，即法律调整的社会关系，是划分法律部门的首要标准。法律调整的是社会关系，每部法律规范的制定都是对于某一社会关系的规定，离开了社会关系，就不会有任何法律规范的存在。以法律所调整社会关系的不同为标准，可以把法律规范划归不同的法律部门。比如，将调整国家行政管理关系的法律规范划入行政法部门，将调整平等主体之间的财产关系和人身关系的法律规范划入民法部门，等等。

法律的调整对象虽然是划分法律部门的首要标准，但是仅依据这一标准不能解决所有法律部门的划分问题，有的法律部门是无法按照社会关系的性质来说明的。比如，刑事法律规范，单纯按照社会关系类别，就无法将它列入哪一个法律部门。将法律调整的方法作为划分法律部门的辅助标准，就可以很好地解决上述问题。比如，将以刑罚作为制裁手段的法律规范划分到刑法部门，将以承担民事责任作为调整手段的法律规范划分到民法部门，等等。除了承担法律责任的方式外，法律所调整的社会关系的不同主体以及确定这种主体间权利义务关系的不同原则和形式等，也属于法律调整的方法。

两种标准之间存在着非常密切的关系，法律调整的方法是由法律调整的社会关系的性质决定的，不同性质的社会关系应当以不同的方法来调整。因此，与法律调整的对象相比，法律调整的方法是辅助的、从属的标准。

►法律部门的划分原则

【分析】法律部门的划分是非常复杂的问题，在遵循客观的标准划分法律部门时，还应当坚持正确的原则。我国法学界比较重视法律部门的划分原则，提出的原则主要有客观原则、合目的性原则、适当平衡原则、辩证发展原则、相对稳定原则和主次原则等。

客观原则，又称从实际出发原则。划分法律部门不是主观任意进行的，它有相对稳定的客观依据，这就是社会关系。我们应该考虑到法律调整的不同社会关系的广泛程度以及法律、法规数量的多少。一般来讲，社会关系范围较广并且相应法律法规也较多的，可以成为一个甚至几个独立的法律部门。如经济领域，可以分为民

法、经济法等部门。对于法律规范很少的社会关系领域，可以予以合并，如选举法是一个调整重要的社会关系的法律，但是法律规范的数量不多，而且将来也不会多，因此，我们在划分法律部门时一般将它合并到宪法部门中。

合目的性原则。划分法律部门的目的在于帮助人们了解和掌握本国现行法律，所以合目的性原则是划分部门法时首先应当坚持的原则。如果某种划分不利于这一目的，那么其划分就是无意义的。人们在学习和研究某个问题时，尤其是当人们想从数以千计的法律和法规中找到解决某个问题的有关法律时，必须借助于法律部门的划分的理论和知识，才能顺利达到目的。

适当平衡原则。划分法律部门时应当注意在各种法律部门之间保持适当的平衡，各法律部门所包含的法律范围不宜太宽，也不宜太窄。每个具体的法律部门所包含的法律、法规数量既不能太少，也不能太多。不同部门法所包含的法律、法规应当保持适当的平衡。

辩证发展原则。客观世界是在发展变化的，社会关系也是在发展变化的，那么作为调整社会关系的法律本身当然也会发展变化，法律和法规也始终处在变化中。同时，人们的主观认识也不是一直停留在一个水平上，也在发生变化。由于主客观条件都在变化，因此法律部门的划分就不可能是绝对不变的，只能是相对的。没有也不可能有运用于一切时代、适合于任何国家的、永远不变的法律部门划分模式。

相对稳定原则。虽然法律部门是发展的，但是法律的稳定性特征要求我们不能频繁地变动法律部门的内容和结构。这就要求我们在划分法律部门时不能只考虑目前的法律、法规的多少，而应当具有一定的前瞻性，在划分部门法时应当考虑到法律、法规今后的发展，即考虑到即将制定和可能制定的法律、法规。例如，劳动法和社会保障法，还有自然资源与环境保护法，就目前我国实际情况来看，虽然法律和法规不多，但是就其未来发展和外国的立法实践而言，应该把它们列为单独的两个法律部门，这样才能避免法律体系结构的频繁变动。

主次原则，又称重点论原则。具体的社会关系和法律规范是极为复杂的，有时同一部法律、法规可以被划归几个不同的法律部门。还有的时候，有的法律被采用一个或者几个标准予以划分，也很难弄清楚其到底应属于哪一个法律部门。在这种情况下，我们应该考虑这一法律、法规的主导因素是什么，按照其主导因素来进行划分和归类。比如，著作权法和专利法所调整的社会关系，既属于行政管理领域的社会关系，也属于知识产权关系，按照前者，可以划归行政法部门；若按照后者，则可以划归民法部门。这样应按主次原则，以其主导因素来决定其归属。考虑到它们的主导因素是知识产权，所以将其划归民法部门。

由于划分者的主观情况和意图，注意和强调的角度或者原则、标准有所差别，受到诸多因素影响的程度不同等，法律部门的具体划分也不会是完全一样的，在社会上存在许多不同的划分法也是正常的。但是，力求法律部门划分的科学和实用，既合乎逻辑又便于操作，应该是我们共同的方向和目标。

第三节 当代中国的法律体系

一、当代中国法律体系的特色

►体现中国特色社会主义的本质要求；体现改革开放和现代化建设的时代要求；体现结构内在统一而又多层次的国情要求；体现传承中华优秀传统文化和借鉴人类法治文明成果的文化要求；体现动态、开放、与时俱进的社会发展要求

【分析】当代中国的法律体系是产生于我国社会主义经济基础之上，并为我国社会主义经济基础服务的上层建筑之一。这一法律体系既与人类政治文明发展的普遍性原则相一致，又与中国社会主义初级阶段的基本国情相适应，与社会主义的根本任务相协调，具有鲜明的中国特色。

中国特色社会主义法律体系，是以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分，

由宪法及宪法相关法、行政法、民商法、经济法、环境法、社会法、军事法、刑法、程序法等多个法律部门组成的有机统一整体。它的形成，体现了中国特色社会主义的本质要求，体现了改革开放和社会主义现代化建设的时代要求，体现了结构内在统一而又多层次的国情要求，体现了传承中国优秀传统法律文化和借鉴人类法治文明成果的文化要求，体现了动态、开放、与时俱进的社会发展要求，是中国社会主义民主法治建设的一个重要里程碑。

当代中国特色社会主义法律体系是开放的和发展的。中国正处在社会转型期，法律体系具有阶段性和前瞻性特点，今后仍将继续制定新的法律和修改原有的法律，以使法律体系不断发展和完善。

二、当代中国法律体系的构成

►宪法及其相关法；行政法；民商法；经济法；环境法；社会法；军事法；刑法；程序法

【分析】有法可依是建设社会主义法治国家的前提。经过多年不懈的努力，以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系基本形成。当代中国的法律体系，部门齐全、层次分明、结构协调、体例科学。构成当代中国法律体系的法律部门主要有宪法及其相关法、行政法、民商法、经济法、环境法、社会法、军事法、刑法和程序法九个法律部门。

1. 宪法及其相关法

作为部门法之一的宪法，是我国社会主义法律体系的基础性和主导性的法律部门，是其他部门法所有规范性法律文件的最高依据，处于特殊的地位，起着特殊的作用。宪法作为一个法律部门，除了包括现行《中华人民共和国宪法》这一占主导地位的法律文件外，还包含处于附属层次的一些法律文件：《全国人民代表大会组织法》《人民法院组织法》《人民检察院组织法》《城市居民委员会组织法》《村民委员会组织法》《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《国籍法》《国旗法》《香港特别行政区基本法》《澳门特别行政区基本法》《民族区域自治法》《法官法》《检察官法》《立法法》《监察法》等。

2. 行政法

行政法是有关国家行政管理活动的法律规范的总称，它是由调整行政管理活动中国家机关之间，国家机关同企业事业单位、社会团体、公民之间发生的行政关系的规范性文件组成的。行政法与行政法规是两个不同的概念。行政法作为一个法律部门，是规范和调整行政法律关系的法律的总称。行政法规是国务院制定的规范性文件法律文件的总称，是法的渊源之一。行政法是由众多的单行的法律、法规和规章以及其他规范性文件构成的。行政法可以分为一般行政法和特别行政法两个部分。一般行政法是对一般的行政关系加以调整的法律规范的总称，如《行政处罚法》《行政许可法》《行政复议法》等。特别行政法则指对各专门行政职能部门管理活动适用的法律规范，如《国家安全法》《监狱法》《土地管理法》《高等教育法》《食品安全法》《药品管理法》《海关法》等。

3. 民商法

民商法是调整作为平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。民商法可以分为民法和商法两个次级法律部门。关于民法和商法是分立还是合一，各国做法不尽相同。从立法模式上看，我国采取的是民商合一的模式。民法是指调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。其内容主要包括物权、债权、人格权、知识产权、婚姻、家庭、收养、继承、侵权责任等方面的法律规范。《民法典》《著作权法》《商标法》《专利法》等是其代表性法律。商法是民法的一个特殊部分，是指调整商事法律关系主体和商业活动的法律规范的总称。商法是在民法基本原则的基础上适应现代商事活动的需要逐渐发展起来的，主要包括公司、破产、证券、期货、保险、票据、海商等方面的法律规范。代表性法律有《公司法》《企业破产法》《证券法》《保险法》《票据法》等。

4. 经济法

经济法是有关国家对经济实行宏观调控的各种法律规范的总和。经济法涉及的范围很广，包括关于国民经济和社会发展规划、计划和政策的法律，关于经济体制改革的原则、方针和政策的法律以及《预算法》《审计法》《会计法》《统计法》《农业法》《商业银行法》《企业所得税法》等。

5. 环境法

环境法又称为环境资源法，是关于保护、治理和合理开发自然资源，保护环境、防止污染和其他公害，维护生态平衡的法律规范的总称。它包括环境污染防治法和资源法两方面的法律。前者适用于噪声污染、大气污染、水污染、土壤污染等的防治，包括防沙治沙、清洁生产、气象、野生动物保护等领域的法律；后者适用于对森林、草原、土地、矿山、能源、水等资源的保护。过去，环境法属于经济法与行政法的领域，由于调整对象的特殊性和调整方法的综合性，其重要性日益凸显，环境法成为一个独立部门法的时机已经成熟。代表性法律包括《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等。

6. 社会法

社会法是一个新兴的法律部门，关于这一法律部门的理论还不完善。一般认为，社会法是指调整国家在解决社会问题和促进社会公共事业发展的过程中所产生的各种社会关系的法律规范的总称。该部门的法律规范主要包括：有关劳动关系、劳动保障和社会保障、安全生产方面的法律，如《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》《安全生产法》等；有关特殊社会群体权益保障方面的法律，如《残疾人保障法》《妇女权益保障法》等；有关社会组织和相关活动方面的法律，如《工会法》《慈善法》等。

7. 军事法

军事法是有关国防和军队建设的法律规范的总称。军事法是中国特色社会主义法律体系的重要组成部分，依法治军、从严治军是强军之基，是建军、治军的基本方略。军事法部门的形成，对于构建系统完备、严密高效的军事法律制度体系和提高国防与军队建设法治化水平，具有重要意义。现有军事法包括以下主要法律文件和规范：《国防法》《兵役法》《现役军官法》《军事设施保护法》等，国务院和中央军委联合制定的军事行政法规，以及中央军委制定的军事法规等。

8. 刑法

刑法是规定有关犯罪和刑罚的法律规范的总称。刑法是一个传统和基本的法律部门，在国家生活中起着非常重要的作用，而在人们的日常生活中，也是人们最为关注的一个法律部门。我国有关犯罪和刑罚的基本规定主要集中在《中华人民共和国刑法》。除此之外，还有许多单行决定。这些规范都是刑法部门的组成部分。

9. 程序法

程序法部门指规范因诉讼和非诉讼活动而产生的社会关系的法律规范的总和，由诉讼程序法与非诉讼程序法两部分构成。诉讼程序法是有关诉讼活动的法律规范的总和，简称诉讼法。我国的诉讼法主要由《刑事诉讼法》《民事诉讼法》《行政诉讼法》组成。非诉讼程序法主要由《仲裁法》《人民调解法》等基本法律构成。

三、当代中国法律体系的发展与完善

► 当代中国法律体系的发展

【分析】中国特色社会主义法律体系是在中国共产党领导下，适应中国特色社会主义建设事业的历史进程而逐步形成的。

新中国成立初期，面临着组建和巩固新生政权、恢复和发展国民经济、实现和保障人民当家作主的艰巨任务。根据政权建设的需要，在1954年第一届全国人民代表大会召开前，颁布实施了具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》，制定了《中央人民政府组织法》《工会法》《婚姻法》《土地改革法》《人民法院暂

行组织条例》《中央人民政府最高人民检察署暂行组织条例》《惩治反革命条例》《妨害国家货币治罪暂行条例》《惩治贪污条例》《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》以及有关地方各级人民政府和司法机关的组织、民族区域自治和公私企业管理、劳动保护等一系列法律、法令，开启了新中国民主法制建设的历史进程。

1954年，第一届全国人民代表大会第一次会议召开，通过了新中国第一部《宪法》，确立了人民民主和社会主义原则，确立了人民代表大会的根本政治制度，规定了公民的基本权利和义务。1956年，中国共产党第八次全国代表大会提出，“国家必须根据需要，逐步地系统地制定完备的法律”。此后至1966年“文化大革命”前，国家共制定法律、法令和法规，多达1500多件。这个时期的民主法制建设，为建设中国特色社会主义法律体系提供了宝贵经验。“文化大革命”期间，中国的民主法制建设遭到严重破坏，立法工作几乎陷于停顿。

1978年，中国共产党十一届三中全会深刻总结新中国成立以来正反两方面的经验教训，作出了把党和国家工作重点转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，并提出“为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”。这次会议开启了中国改革开放和社会主义民主法制建设的历史新时期。这个时期立法工作的重点是，恢复和重建国家秩序，实行和推进改革开放。1979年，第五届全国人民代表大会第二次会议通过了修改宪法若干规定的决议，规定县和县以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会，将县级人民代表大会代表改为由选民直接选举等，同时制定了《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《人民法院组织法》《人民检察院组织法》《刑法》《刑事诉讼法》《中外合资经营企业法》7部法律，拉开了新时期中国大规模立法工作的序幕。

1982年，为适应国家经济、政治、文化、社会生活等各方面发生的巨大变化，第五届全国人民代表大会第五次会议通过了现行《宪法》，确立了国家的根本制度、根本任务和国家生活的基本原则，为新时期改革开放和社会主义现代化建设提供了根本保障，标志着中国民主法制建设进入新的历史阶段。为适应以经济建设为中心、推进改革开放的需要，制定了《民法总则》《民法通则》《著作权法》《经济合同法》《企业破产法》等法律；为贯彻落实“一国两制”方针，制定了《香港特别行政区基本法》《澳门特别行政区基本法》；为加强民族团结，发展社会主义民主，维护公民合法权益，制定了《民族区域自治法》《村民委员会组织法》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》《行政诉讼法》等法律；为保护和改善生活环境与生态环境，制定了《环境保护法》《大气污染防治法》等法律；为促进教育和文化事业发展，制定了《义务教育法》《文物保护法》等法律。这个时期立法工作取得的突出成就，为中国特色社会主义法律体系的形成奠定了重要基础。

1992年，中国共产党第十四次全国代表大会作出了建立社会主义市场经济体制的重大战略决策，明确提出社会主义市场经济体制的建立和完善必须有完备的法制来规范和保障。立法机关按照建立社会主义市场经济体制的要求，加快经济立法，在规范市场主体、维护市场秩序、加强宏观调控、促进对外开放等方面，制定了《公司法》《商业银行法》《乡镇企业法》《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》《产品质量法》《仲裁法》《对外贸易法》《劳动法》等法律。为完善刑事法律，修订了刑法，形成了一部统一的、比较完备的《刑法》，修改了《刑事诉讼法》，完善了刑事诉讼程序；为规范和监督权力的行使，制定了《行政处罚法》《国家赔偿法》《法官法》《检察官法》《律师法》等法律；为进一步加强对环境与资源的保护，制定了《固体废物污染环境防治法》等法律，修改了《矿产资源法》等法律。

1997年，随着社会主义市场经济体制的逐步建立、对外开放水平的不断提高、民主法制建设的深入推进和各项事业的全面发展，党的十五大提出了21世纪第一个十年国民经济和社会发展的远景目标，确立了“依法治国，建设社会主义法治国家”的基本方略，明确提出到2010年形成中国特色社会主义法律体系。在中国特色社会主义法律体系已经形成后，2012年，党的十八大进一步提出“完善中国特色社会主义法律体系，加强重点领

域立法，拓展人民有序参与立法途径”的立法任务。2014年，党的十八届四中全会提出“完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施”的重大任务。2017年，党的十九大再次提出“坚定不移走中国特色社会主义法治道路，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家”的战略任务。2020年5月28日，第十三届全国人民代表大会第三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，这是中华人民共和国首部以法典命名的法律。《民法典》的颁布，是中国特色社会主义法律体系日臻完善的重要标志，是坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求，也是增进人民福祉、维护最广大人民民事权利的一个必然要求，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

► 以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系的完善

【分析】完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系可谓任重道远。在新的起点上完善中国特色社会主义法律体系，是推进中国特色社会主义制度发展完善的内在要求，也是今后立法工作面临的重要任务。

中国已经进入改革发展的关键时期。国内外形势的新情况新变化，广大人民群众的新要求新期待，改革、发展、稳定面临的新课题新矛盾，迫切需要法律制度建设予以回应和调整。具体而言，今后一段时间要着力加强和完善以下几个方面的立法：

第一，积极加强发展社会主义民主政治的立法。适应积极稳妥推进政治体制改革的要求，完善选举、基层群众自治、国家机构组织等方面的法律制度；加强规范行政行为的程序立法，完善审计监督和行政复议等方面的法律制度；适应司法体制改革要求，进一步修改《人民法院组织法》《人民检察院组织法》，完善诉讼法律制度；完善国家机关权力行使、惩治和预防腐败等方面的法律制度，扩大社会主义民主，加强对权力行使的规范和监督，不断推进社会主义民主政治制度的完善和发展。

第二，继续加强经济领域立法。适应社会主义市场经济发展要求，完善民事商事法律制度；适应深化财税、金融等体制改革要求，完善预算管理、财政转移支付、金融风险控制、税收等方面的法律制度，特别是加强税收立法，适时将国务院根据授权制定的税收方面的行政法规制定为法律；完善规范国家管理和调控经济活动、维护国家经济安全的法律制度，促进社会主义市场经济健康发展。

第三，突出加强社会领域立法。坚持以人为本，围绕保障和改善民生，在促进社会事业、健全社会保障、创新社会管理方面，进一步完善劳动就业、劳动保护、社会保险、社会救助、社会福利、收入分配、教育、医疗、住房以及社会组织等法律制度，不断创新社会管理体制机制，深入推进社会事业建设。

第四，更加注重文化科技领域立法。适应推进文化体制改革、促进科技进步的要求，完善扶持公益性文化事业、发展文化产业、鼓励文化科技创新、保护知识产权等方面的法律制度，推动社会主义文化大发展、大繁荣，建设创新型国家。

第五，高度重视生态文明领域立法。适应资源节约型、环境友好型社会建设的要求，完善节约能源资源、保护生态环境等方面的法律制度，从制度上积极促进经济发展方式转变，努力解决经济社会发展与环境资源保护的矛盾，实现人与自然和谐相处。

此外，还要**深入推进科学立法、民主立法，着力提高立法质量**。完善人大代表参与立法工作机制，充分发挥人大代表在立法工作中的作用；完善法律草案审议制度，建立健全科学民主的审议和表决机制；探索公众有序参与立法活动的途径和形式，完善立法座谈会、听证会、论证会和公布法律法规草案征求意见等制度，建立健全公众意见表达机制和采纳公众意见的反馈机制，使立法更加充分体现人民群众的意愿；建立健全立法前论证和立法后评估机制，不断提高立法的科学性、合理性，进一步增强法律法规的可操作性。同时，健全备案审查机构，完善备案审查机制，改进备案审查方式，加强对法规、规章、司法解释等规范性文件的备案审查；健全法律法规清理工作机制，逐步实现法律法规清理工作常态化，确保法律体系内在科学，和谐统一。

第七章 立法

第一节 立法概述

一、立法的概念

►立法的含义

【分析】立法，是法的制定的简称，又称法的创制、法的创立，是指有立法权的国家机关或经授权的国家机关，依照法定的职权和程序，创制、认可、修改或废止法律和其他规范性法律文件的专门性活动，是掌握国家政权的阶级把自己的意志上升为国家意志的活动。在法学上，立法一词有广义和狭义两种解释。广义的立法泛指有关国家机关按照法定的职权和程序，制定规范性法律文件的活动。狭义的立法仅指国家最高权力机关及其常设机关依照法定的权限和程序制定规范性法律文件的活动。

►立法的特征

【分析】立法具有如下特征：

第一，立法是国家的一项专门活动。现代国家的职能主要包括立法职能、行政职能、司法职能、监察职能等，其中立法职能是国家最为重要、最为根本的职能，是其他职能的基础和前提。立法是通过立法机构将统治阶级或人民的意志上升为国家意志的活动。

第二，立法的主体是特定的国家机关。立法活动是特定的国家机关依照法定职权进行的一项专门活动。立法权是国家权力体系中最重要、最核心的权力，立法只能由特定的享有立法权的国家机关来进行。立法活动就是行使立法权的具体过程和表现形式。

第三，立法是国家专门机关依照法定程序进行的活动。在国家产生之初，由于立法尚未上升为国家的一项专门性和经常性活动，所以没有固定、严格的程序，随意性很大。随着立法活动的逐步规范，要求立法必须遵循一套固定、严格的程序，避免随意立法，以保证社会关系和社会秩序的稳定。因此，现代国家都注重立法程序的规范化、格式化。

第四，立法是特定国家机关运用专门技术的活动。立法者要制定出符合社会发展需要的法律规则，必须运用专门的技术，即立法技术。立法技术运用的高低，不仅影响法律的形式表达，而且直接关系立法效果的好坏。

第五，立法是一项系统性、多层次性的综合性法律创制活动。立法的形式和方式是多样的，包括创制新的法律规范，认可现存的某些社会规范，修改、补充现存的法律规范以及终止某些法律规范的效力等。

第六，立法的目的在于产生具有普遍性、规范性、强制性的法律规范，将统治阶级或人民的意志上升为国家意志。立法的目的在于通过创制、认可、修改、废除法律规范的方式，将统治阶级或人民的意志上升为国家意志。立法是导致国家意志形成或变更的活动，不产生国家意志或者不改变法律内容的活动，不属于立法。

二、立法权与立法体制

►立法权的概念

【分析】立法权是一定的国家机关依法享有的创制、认可、修改或废止规范性法律文件的权力，是国家权力体系中最重要、最核心的权力。享有立法权是进行立法活动的前提。立法活动是行使立法权的过程和表现。在一个国家中，不是所有的国家机关都享有立法权，享有立法权的国家机关并非享有同等的立法权限。

►立法体制的概念

【分析】立法体制是关于立法权配置方面的组织制度，其核心是立法权限的划分问题。它既包括中央国家机关和地方国家机关关于立法权限划分的制度，也包括中央国家机关之间及地方各级国家机关之间关于立法权

限划分的制度。一个国家立法体制的形成，主要是由这个国家的国家性质、国家结构形式和文化传统等因素决定的。一般来说，国家结构形式对于立法体制形成的影响是非常明显的。实行单一制国家结构形式的国家，一般采用一元立法体制；实行联邦制国家结构形式的国家，一般采用二元或多元立法体制。

►我国现行的立法体制

【分析】我国现行的立法体制既不同于联邦制国家的二元或多元立法体制，也不同于单一制国家所采用的一元立法体制，而是综合了两种立法体制的一些特点，并结合我国的具体情况，确立的“既统一而又分层次”的立法体制。概括地说，就是在全国人民代表大会及其常务委员会统一行使国家立法权的同时，赋予国务院制定行政法规和省、自治区、直辖市、设区的市的人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规的权限，还赋予民族自治地方制定自治条例和单行条例，以及经济特区所在省、市制定经济特区法规的权限。

我国之所以实行“既统一而又分层次”的立法体制，是因为：第一，我国是单一制国家，不是联邦制。这决定了我国的立法权必须相对集中于中央。第二，我国实行人民代表大会制度，各级人民代表大会是人民行使国家权力的根本途径。这就决定了我国的立法权必须相对集中于国家权力机关。第三，我国地域辽阔，人口众多，各地经济、政治、文化、社会情况各不相同，特别是多民族性，决定了我国的立法权不能全部集中在中央，必须给民族自治地方一定的立法权，在少数民族聚居的地方实行民族区域自治，以适应各地的不同情况。第四，我国正在实行改革开放，法律尚不完备。这就决定了我国的立法权不能完全集中在国家权力机关的手中，必须给行政机关和省、自治区、直辖市、设区的市及部分经济特区以一定的立法权，以适应体制改革和对外开放的实际需要。总之，我国现行的立法体制是由各种因素决定的，是适应我国国情和客观实际需要的。

►党领导立法与人大主导立法

加强党对立法工作的领导与人大主导立法，既是我国立法工作的根本原则，也是我国立法实践经验的科学总结，是党的领导与人民当家作主有机统一在立法领域的具体表现，两者相辅相成，并不矛盾。党领导立法强调坚持党的政治领导原则，党通过确定立法工作方针、批准立法规划、提出立法工作建议、明确立法工作的重大问题、加强立法队伍建设等，把握正确的政治方向。人大主导立法是我国宪法确定的准则，我国是单一制国家，实行人民代表大会制度。有权的各级人民代表大会或人大常委会依法具体履行立法职责，落实立法工作任务，将人民的意志准确地体现在立法之中。其中，全国人大及其常委会在国家立法体制中处于核心地位。我国《宪法》第58条规定：“全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。”《立法法》规定了地方人大及其常委会行使制定地方性法规的权限。这些正是人大主导立法的具体体现。《法治中国建设规划（2020—2025年）》进一步强调要完善党领导立法与人大主导立法的体制机制。

第二节 立法原则

一、合宪和国家法制统一原则

►立法遵循宪法；依法立法；立法维护国家法制统一

【分析】立法要遵循宪法，要维护国家法制统一，这是维护和保障立法活动合法性的重要原则。

合宪原则是指享有立法权的立法机关在创制法律的过程中，应当以宪法为依据，符合宪法的理念和要求，遵循宪法的基本原则。立法合宪性的要求具体还包括立法主体的合宪性、内容的合宪性和程序的合宪性等。依法立法原则，是在前述合宪原则的前提下，立法还应遵循《立法法》。我国现行《立法法》不仅明确规定了立法原则，还规定了不同立法主体所具有的不同立法权限与程序。《立法法》特别对法律、行政法规、地方性法规与规章等的制定主体、内容与程序作了明确的规制。各主体均应严格依法立法，保证立法合法。国家法制统一原则是指立法应当依照法定的权限和程序，从国家整体利益出发，维护社会主义法制的统一和尊严。它同时要求

立法机关所创设的法律应内部和谐统一，做到法律体系内各项法律、法规之间相互衔接且相互一致、相互协调。国家法制统一的前提和基础是宪法，只有在严格遵守和维护宪法的前提下，才能保证法制的统一。

二、民主原则

►立法体现人民意志：坚持立法公开，保障公众参与立法

【分析】立法的民主原则，是指在立法过程中，要体现和贯彻人民主体地位，集中和反映人民的利益、要求和愿望，使立法机关与人民群众相结合，使立法活动与人民群众参与相结合。

立法的民主原则应该包括两个方面：一是立法内容的民主，二是立法过程和立法程序的民主。立法内容的民主是指立法必须从最大多数人的最根本利益出发，发扬社会主义民主，体现人民的意志，这是由我国法的社会主义性质决定的。我国宪法规定的公民的基本权利体现了民主立法的原则，但要使立法的内容更充分地体现民主原则，还要用其他法律将宪法规定的公民权利具体化。立法过程和立法程序的民主，首先要求立法主体的产生要民主；其次是立法过程要公开；最后是立法主体的活动要民主，保障人民通过多种途径参与立法活动。

三、科学原则

►立法从实际出发：科学合理地规定权利与义务、权力与责任；法律规范明确、具体，具有针对性和可执行性

【分析】立法活动应坚持从实际出发，尊重客观规律，维护和保障立法的科学性。立法不能脱离客观实际，不能凭主观臆想进行。从实际出发首先要求立法要从现实国情出发，适应经济社会发展和全面深化改革的要求；其次要求立法要尊重和反映客观规律。马克思深刻地指出，立法者应该把自己看作一个自然科学家，他不是在创造法律，不是在发明法律，而仅仅是在表述法律，他用有意识的实在法把精神关系的内在规律表现出来。

立法活动应该科学、合理地规定公民、法人和其他组织的权利和义务以及国家机关的权力与责任，这就要求在立法工作中首先要坚持权利本位，把保障权利作为权利义务设定的出发点；其次要考虑权利义务的平衡；此外，还应该要考虑弱势群体的实际承受能力。而国家机关的权力与责任应当是统一的。按照现代法治原则，国家机关并不是权力的天然享有者，权力的赋予必须以责任为基础，以维护公共利益、实现社会职能为目标。立法机关赋予国家机关以某种权力，必须与其承担的责任相对应。

立法的科学性原则还要求法律制定过程中要注意法律规范的明确、具体，具有针对性与可执行性。这就要求立法不仅要在语言上具有明确性和严谨性，而且要在内容上具有针对性和可执行性。法律不明确，执法者的自由裁量权就会扩大，法律的权威和效能会降低。

第三节 立法程序

一、立法程序的概念

►立法程序的含义

【分析】立法程序，有广、狭义之分，广义上是指有立法权的国家机关在创制、认可修改或废止规范性法律文件的活动中所必须遵守的步骤和方法。狭义的立法程序仅指国家最高权力机关创制、认可、修改或废止法律的程序。根据《全国人民代表大会议事规则》和《全国人民代表大会常务委员会会议事规则》的有关规定及我国的立法实践，我国最高权力机关及其常设机关立法的基本程序包括：法律草案的提出、法律草案的审议、法律草案的表决与通过、法律的公布等。

►立法程序的特点

【分析】立法程序具有以下特点：

第一，立法程序是法律规定的程序。立法程序法定既体现了立法活动的严肃性，也保证了立法活动的合法性，只有以法律形式确定立法程序，才能对立法活动具有高度的约束力。

第二，立法程序规定了立法步骤和方式。立法步骤是对立法活动先后顺序的具体安排，立法方式是对立法活动运作方法的规定，立法程序具有确定工作顺序和固定活动步骤的功能。

第三，立法程序是所有立法环节必须遵守的程序。立法活动的工作程序大多不需要由法律加以规定，可以在具体立法活动中进行调整甚至省略。但立法程序则由法律明确规定，是一切有立法权的国家机关在所有立法环节中必须遵循的程序。

二、我国法律的制定程序

►法律案的提出

【分析】法律案，亦称法律议案，是具有立法提案权的国家机关和人员向立法机关提出的关于法律的创制、认可、修改或废止的提案和建议。法律案的提出是立法程序中的第一个步骤。

《全国人民代表大会组织法》规定，全国人民代表大会的代表团或30名以上的代表联名、全国人民代表大会主席团、全国人民代表大会常务委员会、全国人民代表大会各专门委员会、国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院享有立法提案权。

►法律案的审议

【分析】法律案的审议是指立法机关为保证立法质量对法律案的审查和讨论。

法律案的审议阶段有二：第一，全国人大有关专门委员会进行审议；第二，立法机关全体会议的审议。在审议法律案的过程中，相应机关要对立法动机、立法精神、法律案与其他法律之间的协调性以及立法技术等问题进行审查。法律案的审议结果主要有：提付立法机关表决、搁置、终止审议。

►法律案的表决与通过

【分析】这是立法程序中具有决定意义的一个步骤。表决是有立法权的机关和人员对议案及法律案表示的最终态度：赞成、反对或弃权。关于通过法律的法定人数，世界各国有不同的规定。我国宪法的修改，由全国人民代表大会以全体代表的2/3以上的多数通过；法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

►法律的公布

【分析】法律的公布是指立法机关或国家元首将已通过的法律以一定的形式予以公布，以便全社会遵照执行。法律的公布是法律生效的前提。法律通过后，凡是未经公布的，都不能产生法律效力。法律的公布必须由特定的机关或人员采取特定的方式进行。我国法律的公布权是由国家主席根据最高权力机关的决定行使的。

第八章 法律实施

第一节 法律实施概述

一、法律实施

►法律实施的含义；法律实施的内容与分类；法律实施的意义；法律实施的状况与评价

【分析】法律实施，也叫法的实施，是指法在社会生活中被人们实际施行，即在社会生活中通过执法、司

法、守法等方式对法律贯彻落实。法的实施就是使法律从书本上的法律变成行动中的法律，使它从抽象的行为模式变成人们的具体行为，从应然状态到实然状态。

通常以实施主体和法的内容为标准，将法律实施的方式分为三种：法律的遵守(守法)、法律的执行(执法)和法律的适用(司法)。

法律实施是实现法的作用与目的的条件。法律实施是实现立法者的立法目的、实现法律的作用的前提，是实现法的价值的必由之路。法律实施是建立法治国家的必备条件。制定好的法律，并严格实施这种法律，被古希腊思想家亚里士多德认为是法治的两个重要条件。当前我国要加强宪法和法律实施，维护社会主义法制的统一、尊严、权威，形成人们不愿违法、不能违法、不敢违法的法治环境，做到有法必依、执法必严、违法必究。

法律实施的状况与评价。研究法律实施，就要对法律实施的状况作出评价或评估。改革开放以来，我国法律实施的情况在不断变好，但仍存在一些问题和不足：保证宪法实施的监督机制和具体制度还不健全；有法不依、执法不严、违法不究的现象在一些地方和部门仍然存在；关系人民群众切身利益的食品药品安全、环境保护、生产安全等执法司法问题还比较突出；滥用职权、失职渎职、执法犯法甚至徇私枉法，严重损害国家法律权威。对法律实施进行评价或评估，主要有以下标准：人们按照法律规定的行为模式行为的程度；刑事案件的发案率、案件种类、破案率及对犯罪分子的制裁情况；各类合同的履约率与违约率；普通公民和国家公职人员对法律的了解程度，他们的法律意识及法制观念的提高程度；社会大众对社会生活中安全、秩序、自由、公正、效率等法的价值的切身感受；法律的社会功能和社会目的是否有效实现及其程度；有关法律活动的成本与收益的比率。

二、法律实现

►法律实现的含义；法律实现的意义；影响法律实现的因素

【分析】法律实现是指法律的要求在社会生活中被转化为现实，达到法律设定的权利和义务的目的。法律实现与法律实施不同，法律实施是使法从应然状态到实然状态的过程和活动，而法律实现是法律实施活动的直接目的。法律实现也不同于法的实效，法的实效是法律被人们实际施行的状态和程度。法律实现是将法的实施的过程性与法的实效的结果性结合的一个概念。

法律实现有着重要意义。法作为一种通过规定人们的权利、义务关系来调整人们行为或社会关系的社会规范，只有将抽象的行为模式转化为人们现实的权利、义务关系，才能发挥其应有的功能。但法律实施并不必然意味着法的要求的实现，在法律实施过程中可能有各种因素阻碍着法的功能的发挥，因而不能产生立法者希望达到的结果。而要使法律产生实效，又必须以法律实施和法律监督为条件，只有将法律实施和法律监督与对法的实效的追求结合起来，使法真正得到实现，才能发挥法在社会生活中应有的作用。

根据辩证唯物主义关于事物之间普遍联系的观点，与法律实施过程相联系的各种社会因素都会影响法律在社会生活中的实现。其中有重要影响的因素包括：国家的阶级本质；法律、法规等规范性法律文件反映统治阶级或人民意志的程度；现行法律与社会生活(归根到底是与经济发展)相适应的程度；国家机关活动中贯彻法治原则的程度；社会成员的法律意识，法律文化水平；等等。影响法律实现的因素很多，应具体问题具体分析。

第二节 执法

一、执法的概念

►执法的含义；执法的特点

【分析】执法是法的执行的简称。人们通常在广义和狭义两种含义上使用执法这个概念。广义上的执法是

指所有国家行政机关、司法机关和法律法规授权、行政主体委托的组织及其公职人员依照法定职权和程序贯彻实施法律的活动，包括一切执行法律、适用法律的活动；狭义上的执法则专指国家行政机关和法律法规授权、行政主体委托的组织及其公职人员依照法定职权和程序行使行政管理职权、履行职责、实施法律的活动。本章在狭义上使用执法的概念。

与司法等法律实施活动相比较，执法的特点主要包括：**执法的主动性、执法的单方面性、执法内容的广泛性**。此外，执法活动还具有**主体法定性、国家权威性、强制性和灵活性**等特点。

二、执法的原则

► **依法行政原则；合理性原则；讲求效率原则；严格执法原则；正当程序原则；其他原则**

【分析】**依法行政原则**是指行政机关必须依照法定的权限、法定程序和法治精神进行执法活动。这是现代法治国家行政活动的一条最基本的原则。该原则的具体要求是：**第一，执法的主体合法**。国家行政机关的设立及其职权必须有法律依据，必须在法律规定的职权范围内活动，越权违法，越权无效。**第二，执法的内容合法**。执法活动是根据法律的规定进行的，执法的具体内容也要符合法律的规定。**第三，执法的程序合法**。要严格按照法定的步骤、顺序和时限执法，不得任意改变、省略和超越。

合理性原则是指执法主体在执法活动中，特别是在行使自由裁量权进行行政管理时，必须做到适当、合理、公正，即符合法律的基本精神和目的，具有客观、充分的事实根据和法律依据，与社会生活常理相一致。行政合理性原则要求执法主体要平等地对待行政相对人，对于实施了同样或类似行为的行政相对人应给予公平处理。行使自由裁量权时要以法律精神为指导，考虑相关因素，尽可能照顾到各方利益，在多方利益之间衡量时要合情合理，禁止偏袒，禁止谋私，严格控制自由裁量权的行使。对于法律只有原则规定或没有法律规定的，应以客观、充分的事实根据为基础，依据法律的基本精神和目的，遵循与社会公理相一致原则，公平合理地处理，执法还要尊重当地的善良风俗。

讲求效率原则是指行政机关应当在依法行政的前提下，讲求效率，主动有效地行使其权能，以尽可能低的成本取得最大的行政执法效益。与立法机关、司法机关相比，行政机关更强调效率，要求执法主体从保护公民权利和国家权益出发，对行政相对人的各项请求作出及时反应，对各种行政事务通过执法作出及时反应。效率原则是建立在行政合法性原则基础之上的，执法主体必须严格按照法定程序和法定权限执法，不能以效率为借口而违反法律规定。

严格执法原则是对政府机关及其公职人员提出的重要执法原则，它与依法行政属于同一范畴。坚持这一原则，要求执法者应当严谨、严肃、严明、公正地执法，应当在准确理解法律精神的基础上，严格规范地遵循法律，依法裁量当事人的行为，准确判断其是否符合法律的规定，是否需要依法惩处。反对任性执法、选择性执法、钓鱼式执法等非正常执法模式，强调执法者通过严格执法来维护法律权威。

正当程序原则是指执法机关在实施行政执法行为的过程中，必须遵循法定的步骤、方式、形式、顺序和时限，执法要做到程序公正，不单方面接触行政相对人，不在事先未通知和听取行政相对人申辩意见的情况下作出对相对人不利的处理。目的是使执法行为公平、公开、民主，保障公民、法人和非法人组织的合法权益，以促进行政权行使的合法性和合理性，提高行政效率。

在执法活动中还要坚持其他原则：

比例原则。指行政机关实施行政行为应兼顾行政目标的实现和相对人权益的保护，如果为了实现行政目标可能对相对人权益造成某种不利影响时，应使这种不利影响限制在尽可能小的范围和限度内，使二者处于适度的比例。其内涵分为三个方面：第一是**妥当性（适当性）原则**，指行政行为对于实现行政目的、目标是适当的。第二是**必要性原则**，指行政行为应以达到行政目的、目标为限，不能给相对人权益造成过度的不利影响，即行

政权的行使只能限于必要的度，以尽可能使相对人权益遭受最小的侵害。第三是均衡性原则，指行政行为的实施应衡量其目的达到的利益与侵犯相对人的权益二者孰轻孰重。只有前者重于后者时其行为才具合理性。行政行为在任何时候均不应给相对人权益造成超过行政目的、目标本身价值的损害。

诚实守信原则。其内涵分为两个方面：第一是行政信息真实原则。行政机关公布的信息应当全面、准确、真实。无论是向普通公众公布的信息，还是向特定人或者组织提供的信息，行政机关都应当对其真实性承担法律责任。第二是保护公民信赖利益原则。非因法定事由并经法定程序，行政机关不得撤销、变更已经生效的行政决定；因国家利益、公共利益或者其他法定事由需要撤回或者变更行政决定的，应当依照法定权限和程序进行，并对行政管理相对人因此而受到的财产损失依法予以补偿。

权责相统一原则。其内涵分为两个方面：第一是行政效能原则。行政机关依法履行经济、社会和文化事务管理职责，要由法律、法规赋予其相应的执法手段，保证政令有效。第二是行政责任原则。行政机关违法或者不当行使职权，应当依法承担法律责任。这一原则的基本要求是行政权力和法律责任的统一，即执法有保障、有权必有责、用权受监督、违法受追究、侵权须赔偿。

第三节 司法

一、司法的概念

►司法的含义；司法的特点

【分析】司法又被称为“法的适用”，通常指国家司法机关依照法定职权和程序，具体应用法律处理各种案件的专门活动。这种专门活动是以国家名义行使司法权的活动，是实施法律的一种方式，对实现立法目的、发挥法律的功能具有重要意义。

在许多情况下，只要公民和社会组织依照法律行使权利并履行义务，法律就能够在社会实际生活中得以实现，而无须法的适用。只有在两种情况下，才需要法的适用：一种情况是，当公民、社会组织和其他国家机关在相互关系中发生了自己无法解决的争议，致使法律规定的权利或义务无法实现时，需要司法机关适用法律裁决纠纷，解决争端；另一种情况是，当公民、社会组织和其他国家机关在其活动中遇到违法、违约或侵权时，需要司法机关适用法律制裁违法、犯罪，恢复权利。

司法权是指对案件事实和法律的判断权和裁决权。根据宪法及相关法律规定，我国的司法权包括审判权和检察权。审判权是适用法律处理案件，作出判决和裁定的司法权；检察权包括代表国家批准逮捕、提起公诉、不起诉、提起抗诉等司法权。

就法院的司法活动而言，它不同于国家行政机关、社会组织和公民实施法律的活动，它具有被动性、中立性、终局性、形式性和专属性的特点。

二、司法的原则

►司法法治原则

【分析】司法法治原则即以事实为根据、以法律为准绳的原则。我国的三大诉讼法都规定了这一原则。以事实为根据，就是指司法机关审理一切案件，都只能以与案件有关的事实作为依据，而不能以主观臆断作依据。以法律为准绳，就是指司法机关在司法过程中，要严格按照法律规定办事，把法律作为处理案件的唯一标准和尺度。在查办案件的全过程中，都要按照法定权限和法定程序，依据法律的有关规定，确定案件性质，区分合法与违法、一般违法和犯罪等，并根据案件的性质，给予恰当正确的裁决。以法律为准绳，意味着在整个司法活动中，法律是最高标准，这是社会主义法治对司法提出的必然要求。

认真贯彻这项原则，首先要求在司法工作中，应当**坚持实事求是、从实际出发的思想路线，重证据，重调查研究，不轻信口供**；其次要求在司法工作中，坚持维护社会主义法律的权威和尊严，**不仅要严格遵守实体法的规定，而且要严格执行程序法的规定**。另外，还要求在司法工作中，正确处理**依法办事与坚持党的政策的指导作用的关系**。一方面，**不能将坚持依法办事和坚持党的政策的指导作用对立起来**；另一方面，**也不能以政策改变、代替法律甚至取消法律，而是应当将两者统一起来**。

►司法平等原则

【分析】在法的适用领域，公民在法律面前一律平等的基本含义是：首先，在我国，法律对于全体公民，不分民族、种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、财产状况等，都是统一适用的。其次，**任何权利受到侵犯的公民一律平等地受到法律的保护，不能歧视任何公民**。再次，**在民事诉讼和行政诉讼中，要保证诉讼当事人享有平等的诉讼权利，不能偏袒任何一方当事人；在刑事诉讼中，要切实保障诉讼参与人依法享有的诉讼权利**。最后，**对任何公民的违法犯罪行为，都必须追究法律责任，依法给予相应的法律制裁，不允许有不受法律约束或凌驾于法律之上的特殊公民和组织，任何超出法律之外的特殊对待都是违法的**。

贯彻这一原则，要求在法治实践中**坚决反特权、反歧视**，要求司法工作者在司法活动中必须**忠于事实，忠于法律，忠于人民**。

►司法机关依法独立行使职权原则

【分析】我国宪法、人民法院组织法、人民检察院组织法、三大诉讼法都对司法机关依法独立行使职权作出了明确规定。根据宪法和有关法律的规定，这项原则的基本含义是：首先，**司法权的专属性**，即国家的司法权只能由国家各级审判机关和检察机关统一行使，其他任何机关、团体和个人都无权行使此项权利。其次，**司法权行使的独立性**，即人民法院、人民检察院依照法律独立行使自己的职权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。最后，**司法权行使的合法性**，即司法机关审理案件必须严格依照法律规定，正确适用法律，不得滥用职权，枉法裁判。

坚持司法机关依法独立行使职权原则，并不意味着司法机关行使司法权可以不受任何监督和约束。司法权如同其他任何权力一样，都要接受监督和制约。**对司法权的监督表现在以下几个方面：第一，司法权要接受党的领导和监督，这是司法权正确行使的政治保证。第二，司法权要接受国家权力机关的监督，司法权由国家权力机关产生，并对国家权力机关负责。因此，国家权力机关有权监督司法权的行使，司法机关也有义务接受国家权力机关的监督。第三，司法机关的上、下级之间以及同级之间也存在监督和约束，这种监督和约束是通过一系列具体的司法制度来体现和实现的。第四，司法权也要接受行政机关、监察机关、企事业单位、社会团体、民主党派和人民群众的监督。这些种类广泛的监督形式和监督机制，有利于更好地行使司法权，防止司法权的滥用等司法腐败现象和行为。**

►司法责任原则

【分析】**司法责任原则，是指司法机关和司法人员在行使司法权过程中侵犯了公民、法人和其他组织的合法权益，造成严重后果而应承担的一种责任制度。司法责任原则是根据权力与责任相统一的法治原则而提出的权力约束机制。司法机关和司法人员接受人民的委托，行使国家的司法权，承载着重大的责任。按照权力与责任相统一的原则，一方面，对司法机关和司法人员行使国家司法权给予法律保障，另一方面，对司法机关及其司法人员的违法和犯罪行为给予严惩。只有将司法权力与司法责任结合起来，才能更好地增强司法机关和司法人员的责任感，防止司法过程中的违法行为，并对违法行为进行法律制裁，以更好地维护社会主义司法的威信和社会主义法制的权威和尊严。我国的《国家赔偿法》《法官法》《检察官法》等法律确立了司法责任制度，对于实现公正司法、廉洁司法具有深远的影响。**

►司法公正原则

【分析】司法公正原则是指司法机关及其司法人员在司法活动的过程和结果中应坚持和体现公平和正义的原则。

司法公正是社会正义的重要组成部分，它包括实体公正和程序公正，其中实体公正主要是指司法裁判的结果公正，当事人的权益得到了充分的保障，违法犯罪者受到了应得的惩罚和制裁。程序公正主要是指司法过程的公正，司法程序具有正当性，当事人在司法过程中受到公平公正的对待。司法活动的合法性、独立性、有效性，裁判人员的中立性，当事人地位的平等性以及裁判结果的公正性，都是司法公正的必然要求和体现。

司法公正是司法的生命和灵魂，是司法的本质要求和终极价值准则。追求司法公正是司法的永恒主题，也是民众对司法的期望。当今中国正在进行司法改革，它包括制度、程序和体制的改革以及建立现代司法制度，其最终目的就是实现司法公正，并通过司法公正维护和促进社会公正。

三、深入推进司法改革

►深化司法体制综合配套改革

【分析】司法体制改革是指在宪法规定的司法体制基本框架内，国家司法机关和国家司法制度实现自我创新、自我完善和自我发展，建设中国特色社会主义现代司法体系和司法制度。

深化司法体制改革事关党和国家事业大局，必须树立科学的司法改革观，在司法改革中坚持正确的方向 and 原则：一是坚持正确的政治方向。坚持党对政法工作的领导，坚持党管政法干部原则，坚持走中国特色社会主义司法改革之路，努力创造更高水平的社会主义司法文明。二是坚持以宪法为根本遵循。我国宪法以国家根本法的形式确立了司法制度的基本框架和司法活动的基本准则，是组织实施司法体制改革的根本遵循。三是坚持以提高司法公信力为根本尺度。深化司法体制改革，必须坚持以提高司法公信力为根本尺度，以矛盾纠纷得到公正的解决、合法权益得到有效的维护为目标，确保取得人民满意的改革实效。四是坚持依法有序推进改革。凡是同现行法律规定不一致的改革举措，必须先提请立法机关修改现行法律规定，然后再开展改革。修改现行法律规定的条件尚不成熟的，应及时提请立法机关进行授权，在授权范围内进行改革试点。

当前司法改革的主要任务有：一是保证公正司法、提高司法公信力。重点包括推进以审判为中心的诉讼制度改革，改革法院案件受理制度，探索建立检察机关提起公益诉讼制度，实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制，完善人民陪审员和人民监督员制度等。完善行政诉讼体制机制，合理调整行政诉讼代理人管辖制度，切实解决行政诉讼立案难、审理难、执行难等突出问题。二是加强德才兼备的高素质法治工作队伍建设。重点包括完善法律职业准入制度，加快建立符合职业特点的法治工作人员管理制度，建立和完善法官、检察官逐级遴选制度，健全法治工作部门和法学教育研究机构人员双向交流与互聘机制，进一步深化律师管理制度改革。

►落实司法责任制

【分析】要深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。司法责任制改革被视为司法体制改革的关键。司法责任制改革作为必须紧紧牵住的“牛鼻子”，针对“审者不判、判者不审”问题对症下药，明确要求法官、检察官对案件质量终身负责。通过改革，形成以法官、检察官依法独立办案为前提，以法官、检察官员额制为配套，以完善法官、检察官职业保障为条件，以主客观相统一为追责原则的司法权力运行机制。

对于全面落实司法责任制，还应当完善一系列配套性措施，如完善法官、检察官入额遴选办法，加强编制和员额的省级统筹、动态调整，有条件的地方探索跨院入额；配套建立员额退出实施办法，让办案绩效不符合要求的法官、检察官退出员额；推广科学分案办法，以随机分案为主、指定分案为辅；加强领导干部办案情况分级考核和定期通报；利用信息化、大数据等辅助法官办案，建立类案与关联案件检索机制；加大民族地区双语法官、检察官培训力度，加强边疆民族地区人才培养等。

►完善人权司法保障制度

【分析】完善人权司法保障制度是我国司法体制改革的重要组成部分，也是建设公正高效权威的社会主义司法制度的重要内容。完善人权司法保障制度要正确处理打击犯罪与保护人权、程序公平与实体公正、追求公正与注重效率的关系，确保人民群众有尊严地参加诉讼，及时得到公正的裁判结果。

第一，完善人权司法保障要注重对法治原则的遵循。加强对人权的司法保障要以宪法和法律为依据，逐步健全人权司法保障的法律法规，完善制度设计，细化保障措施。在司法活动中，要切实遵守人权保障的相关规定，着力提升司法理念、加强保障力度、完善监督制约，做到尊重人权与防止侵权有机结合，充分发挥社会主义司法制度的优越性。**第二，完善人权司法保障要体现对基本人权的尊重。**国家尊重和保障人权是宪法的明确要求，司法活动直接涉及公民的人身、自由、人格尊严、财产权益等基本权利，要以完善人权司法保障改革为契机，不断提升人权司法保障的制度化、法治化水平。**第三，完善人权司法保障要突出对司法权力的监督和制约。**在司法活动中，当事人及诉讼参与人的权利相对于司法机关的公权力，处于弱势地位，容易受到侵犯。完善人权司法保障就要强化对司法权力的限制和制约，防止滥用权力侵犯人权。要完善外部监督制约，认真贯彻司法机关“分工负责、互相配合、互相制约”的基本原则，完善内部监督制约，改革人民陪审员制度，健全人民监督员制度，推进审判公开、检务公开，为公民维护自身权利提供坚实的制度保障。**第四，完善人权司法保障要强化对诉讼权利的保障。**树立理性、平和、文明、规范的执法理念，严禁刑讯逼供、体罚虐待。充分保障犯罪嫌疑人、被告人的辩护权、辩解权等诉讼权利。完善律师执业权利保障机制，发挥律师在依法维护公民和法人合法权益方面的重要作用。**第五，完善人权司法保障要加强对公民权利的救济。**完善人权司法保障，既要有效防止侵权行为的发生，又要切实保障公民权利在受到侵犯后，能及时得到有效救济。

►提高司法公信力

【分析】深化司法体制改革，建设公正高效权威的社会主义司法制度，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。要坚持司法体制改革的正确方向，坚持以提高司法公信力为根本尺度，坚持符合国情和遵循司法规律相结合。

保证公正司法、提高司法公信力在当前有六个方面的改革要求。一是完善确保依法独立公正行使审判权和检察权的制度。主要有：建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度等。二是优化司法职权配置。主要有：推动实行审判权和执行权相分离，统一刑罚执行体制，探索实行法院、检察院司法行政事务管理权和审判权、检察权相分离等举措。三是推进严格公正司法。主要有：推进以审判为中心的诉讼制度改革，实行办案质量个人负责制和错案责任倒查问责制等举措。四是保障人民群众参与司法。主要有：完善人民陪审员制度，构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制等举措。五是加强人权司法保障。主要有：健全落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则的法律制度。完善对限制人身自由司法措施和侦查手段的司法监督等举措。六是加强对司法活动的监督。主要有：完善检察机关行使监督权的法律制度，完善人民监督员制度。建立终身禁止从事法律职业制度等举措。

第四节 守法

一、守法的概念

►守法的含义；全民守法的意义

【分析】法的遵守有广义和狭义两个方面的含义。广义上的法的遵守，就是法的实施。狭义上的法的遵守，又称守法，专指公民、社会组织和国家机关以法律为自己的行为准则，依法行使权利、履行义务的活动。包括积极守法和消极守法(不违法)。

全民守法是社会主义法治的重要内容，也是维护社会秩序、实现法律目的的需要。认真遵守法律是广大人民群众实现自己根本利益的必然要求。在我国，法律是工人阶级领导的全体人民的共同意志和根本利益的体现。只有严格遵守法律，才能使体现在法律中的人民的根本利益得到实现，才能真正实现立法的目的。

二、守法的要素

►守法主体；守法范围；守法内容

【分析】守法包括守法主体、守法范围和守法内容等构成要素。

守法主体是指在一个国家和社会中应当遵守法律的主体，即一定守法行为的实施者。在我国，按照宪法的规定，守法的主体包括：一切国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业组织，中华人民共和国公民，在我国领域内的外国组织、外国人和无国籍人。

守法范围是指守法主体必须遵守的行为规范的种类。守法范围直接决定于一个国家法的渊源。在我国，守法的范围并不限于各种制定法，还包括有法律效力的非规范性法律文件，如人民法院的判决书、调解书、裁定书等。

守法内容包括履行法律义务和行使法律权利。履行法律义务可分为两种不同的形式：一是履行消极的法律义务。这是指人们遵守法律规范中的禁止性规范，不作出一定的行为。二是履行积极的法律义务。这是指人们遵守法律规范中的命令性规范，作出一定的行为。行使法律权利是指人们通过自己作出一定的行为或者要求他人作出或不作出一定的行为来保证自己的合法权利得以实现。依法行使权利也是守法的重要内容之一。

三、守法的原因和状态

►守法的原因

【分析】守法的原因是指人们遵守法律的理由。守法的理由问题是法理学的一个重要理论问题。西方不同的法哲学流派就此分别提出了不同的学说，主要有社会契约论、功利主义论、暴力威慑论和法律正当论四种。社会契约论将公民的守法理由归于自己的同意和承诺，公民都是社会契约的当事人，作为这个契约的当事人，应该遵守契约的内容，遵守自己同意的政府和法律。功利主义法学认为，当法律能给公民或社会带来更多的利益或者能更好地防范风险并因此而减少可能的损失时，公民就遵守法律。暴力威慑论把公民的守法理由归结于国家强制力的威慑和惩戒作用。这种理论认为，公民之所以守法是因为畏惧国家暴力，为了避免违反法律所招致的暴力制裁或经济损失，公民才采取遵守法律的行为。法律正当论则从公民法律信仰的角度回答公民为什么遵守法律。这种理论认为，公民之所以守法，是因为法律具有形式合法和内容合法的要件。法律是由具有合法性和权威性的国家机关或官员依照法定程序制定的，且与社会所认同的价值或道德即公平正义原则相符不悖。对于这样的法律，公民就有服从的义务。

上述各种理论和观点解释了人们守法的不同理由，但是每一种解释却又都不全面。一般而言，社会成员遵守法律往往出于多方面因素的考虑。在一个现代文明不太发达的社会里，守法多出于习惯、畏惧和道德等因素的考虑，而在法治文明较为发达的社会里，人们守法一般出于对法律的认同甚至信仰的考虑。

►守法的状态

【分析】守法的状态是指人们对法律的遵守程度。包括守法的最低状态、守法的中层状态和守法的高级状态这三种类型。守法的最低状态是不违法犯罪。守法的中层状态是依法办事，形成统一的法律秩序。守法的高级状态是守法主体不论是外在的行为，还是内在动机都符合法的精神和要求，严格履行法律义务，充分行使法律权利，从而真正实现法律调整的目的。人们守法的状态往往受到多种因素的影响和制约，如守法主体的主观心理状态和法律意识水平、守法主体所处的客观社会环境等都会对守法行为产生不同程度的影响。

第五节 法律监督

一、法律监督的概念

►法律监督的含义；法律监督的意义

【分析】法律监督目前我国法学界通常有狭义和广义两种理解。狭义上的法律监督是指由特定的国家机关依照法定职权和法定程序，对立法、执法和司法活动的合法性进行的监督。广义上的法律监督，是指由所有的国家机关、社会组织和公民对各种法律活动的合法性进行的监督。在法理学中，通常在广义上研究和使用的这一概念。法律监督体系是由一个国家各种形式的法律监督构成的有机联系的系统。受具体国情的影响，世界各国的法律监督体系有各不相同的特点。依据监督主体的不同，我国的法律监督体系由国家监督和社会监督两大系统构成。

法律监督是现代法治不可缺少的特殊组成部分，它贯穿于法律运行的全过程，对社会生活和经济生活有着广泛的影响。在我国，法律监督具有重要意义：法律监督是社会主义民主政治的保障和重要组成部分，是依法治国、建设社会主义法治国家的保证，是建立和完善社会主义市场经济和社会主义法治社会的需要。

二、当代中国的法律监督

►国家监督；社会监督；《监察法》制定的意义与主要原则

【分析】当代中国的法律监督分为国家监督与社会监督。国家监督包括国家权力机关的监督、国家监察机关的监督、国家司法机关的监督和行政机关的监督。

国家权力机关的监督，是指各级人民代表大会及其常务委员会为全面保证国家法律的有效实施，通过法定程序，对由它产生的国家机关实施法律的监督。这种监督在国家监督乃至全部法律监督中都处于核心和主导地位。国家权力机关的监督内容是非常广泛的，习惯上，人们将这种监督概括为法律上的监督和工作监督两种。法律上的监督，是指全国人大和地方人大及其常委会对法律实施的监督。工作监督主要是指对政府、检察机关和审判机关工作的监督。

国家监察机关的监督是由2018年修改的《宪法》和同年出台的《监察法》所规定的，是以国家监察机关为主体进行的监督，特点是实现对所有行使公权力的公职人员监察的全覆盖。

国家司法机关的监督是以国家司法机关为主体进行的监督。在我国，国家司法机关的监督包括检察机关的监督和审判机关的监督。检察机关的法律监督被称为检察监督，是一种专门监督。检察机关的监督分为三类：刑事诉讼监督、民事诉讼监督和行政诉讼监督。审判机关的监督也叫作人民法院的监督，分为三种：一是人民法院系统内的监督，二是人民法院对检察机关的监督，三是人民法院对行政机关的监督。

国家行政机关的监督是指以行政机关为监督主体进行的监督。它既包括国家行政系统内部上下级之间以及行政系统内部设立的专门机关的法律监督，也包括行政机关在行使行政权时对行政相对人的监督。国家行政机关的监督可以分为四类，即一般行政监督、专门行政监督、行政复议、行政监管。

社会监督，即非国家的监督，指由各政党、各社会组织和人民群众依照宪法和有关法律，对各种法律活动的合法性进行的监督。在我国，根据社会监督的主体不同，可以将其分为政党的监督、社会组织的监督、社会舆论的监督、人民群众的监督。这种监督主体范围十分广泛，民主性比较突出，虽然不具有法律效力，但发挥着非常重要的作用。

政党监督，在我国主要是指中国共产党的政治监督。中国共产党作为执政党，其政治监督显得尤其突出和具有成效。中国共产党的监督体现为各级党组织的监督与各级党的纪律检查委员会的监督。后者甚至直接体现

为纪委与国家监察机构合署办公，成为国家监督的重要组成部分。此点已有阐述，这里不再展开。

社会组织的监督，主要指**人民政协、民主党派、社会团体以及其他社会组织的监督**。人民政协在政治协商和民主监督方面发挥着重要作用。我国的各民主党派作为参政党，可以通过多种形式、多种途径积极开展法律监督的工作。社会团体的监督主要是指由工会、共青团、妇女联合会以及城市居民委员会、农村村民委员会、消费者协会等社会组织进行的监督。其他社会组织的监督是依法登记的社会组织所进行的法律监督，随着法治社会建设的逐步推进，此类监督的价值越来越受到重视。

社会舆论的监督主要指借助传媒手段进行的新闻舆论的监督。它既是宪法规定的公民享有言论、出版自由在法律监督领域的具体应用，也是人民群众的监督在新闻、出版领域中的体现。舆论监督最能体现社会监督的广泛性、公开性和民主性，能够十分有效地影响国家机关及其工作人员的行为，起到其他监督形式无法替代的作用。

人民群众的监督是指由人民群众直接进行的法律监督。这种监督的主体是公民个人，客体是所有国家机关及其工作人员、政党、社会团体、社会组织等。人民群众的监督行为是一种法律行为，它或者直接促使监督客体纠正错误、改进工作，或者可以启动诉讼程序或国家权力机关的监督，任何破坏或阻止人民群众行使监督权的行为，都是违法行为，应当受到法律的追究。

我国《监察法》制定的重要意义与主要原则：

第一，制定《监察法》是贯彻落实党中央关于深化国家监察体制改革决策部署的重大举措。制定《监察法》，对于创新和完善国家监察制度，实现立法与改革相衔接，以法治思维和法治方式开展反腐败工作，意义重大、影响深远。**第二，制定《监察法》是坚持和加强党对反腐败工作的领导，构建集中统一、权威高效的国家监察体系的必然要求。**《监察法》是一部对国家监察工作起统领性和基础性作用的法律，为整合反腐败资源力量、加强党对反腐败工作的集中统一领导、实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖提供法律依据。**第三，制定《监察法》是坚持党内监督与国家监察有机统一，坚持走中国特色监察道路的创制之举。**制定《监察法》就是通过立法方式保证依规治党与依法治国、党内监督与国家监察有机统一，将党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通起来，不断提高党和国家的监督效能。**第四，制定《监察法》是加强宪法实施，丰富和发展人民代表大会制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的战略举措。**

《监察法》立法工作遵循以下**思路和原则**：**一是坚持正确政治方向。**严格遵循党中央确定的指导思想、基本原则，即坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加强党对反腐败工作的集中统一领导，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。**二是坚持与宪法修改保持一致。**宪法是国家各种制度和法律法规的总依据。《监察法》相关内容及表述均与现行宪法关于监察委员会的各项规定相衔接、相统一。**三是坚持问题导向。**着力解决我国监察体制机制中存在的突出问题。**四是坚持科学立法、民主立法、依法立法。**贯彻落实党中央决策部署，充分吸收各方面意见，认真回应社会关切，严格依法按程序办事。

第九章 法律职业与法律方法

第一节 法律职业

一、法律职业的概念

►法律职业的含义：法律职业的特征

【分析】法律职业是指以法官、检察官、律师等为代表的，受过专门的法律专业训练具有娴熟的法律技能

与法律伦理的法律人所构成的自治性共同体。从狭义上说，法律职业主要包括法官、检察官、律师三种具体的职业。从广义上说，法律职业还包括一切受过法律专业训练、从事法律工作的人员，如司法辅助人员、公证员、企业和行政机关里从事法律事务的人、法学教师、法学研究人员等。法律职业共同体的成员是法律人，法律人是受过专门的法律专业训练，具有娴熟的法律技能与法律伦理的人。

法律职业具有以下特征：

一是法律职业的技能特征。法律职业技能来源于法学教育，没有发达的法学教育就没有法律职业的形成。法学教育提供给法律职业的是系统的而不是零星的，是统一的而不是相互冲突的法律知识。这也是法律职业技能统一的前提。对于从事法律职业的人来说，职业技能是通过正规的法科专业学习与系统训练而养成的。个别国家在法律职业形成历史上虽然有过“师徒式”的律师执业教育，但这种教育仍然是以统一的法律知识为基础的。形成法律职业的技能是法律职业形成或成熟的标志之一。

二是法律职业的伦理特征。法律职业必须具备本职业特有的伦理。法律职业伦理在法律人内部薪火相传。法律职业伦理有别于大众伦理和其他职业伦理，因为它受法律活动规律的制约，受法律职业技能的影响。比如，律师不得因委托人罪恶深重而拒绝接受委托；法官应当平和对待刑事被告，只能作无罪推定。法律职业伦理成为共同体内部的职业习惯、行为方式和信仰，从而维系着这个共同体的成员间关系，克服因职业技术理性所带来的职业弊端，并提升共同体的社会地位和荣誉。

三是法律职业的自治特征。法律人从事法律活动，具有相当大的自主性或自治性；对法律自治的追求也就出现了职业主义的倾向，因而也造就了专业化的法律人，进而也就形成了法律人的思维和方法。在现代社会，法律本身已经形成了自己的一整套概念体系和研究方法，成为一种独立的知识传统，这种独立的知识传统是法律职业自治特征能够形成的前提和基础。

四是法律职业的准入特征。要想加入法律职业必将受到认真考查，获得许可证，得到头衔。只有通过了某种法律职业资格考试，才有可能成为法律职业共同体的一员。根据中国现行法律的规定，中国公民要想成为一名法官、检察官、律师或公证员等法律职业者，必须通过国家统一法律职业资格考试并取得相应的法律执业资格。

我们也可以把法律职业这四个方面的特征作为一国法律职业成熟的标志。

二、国家统一法律职业资格制度

►国家统一法律职业资格考试制度的意义；法律职业人员范围；法律职业任职条件；建设德才兼备的高素质法治工作队伍

【分析】国家统一法律职业资格考试制度是国家统一组织的选拔合格法律职业人才的国家考试制度。司法部出台的《国家统一法律职业资格考试实施办法》是我国法律职业资格制度的第一部规章，它明确了法律职业资格考试的报名条件、考试组织、违纪处理、资格授予和管理等内容，对于规范法律职业资格考试的组织实施等工作具有重要作用。根据该办法，初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任法律类仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、法律顾问的公务员，应当通过国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格。

因此，我国法律职业人员范围主要包括：法官；检察官；律师；其他法律职业等。

取得国家统一的法律职业资格必须同时具备下列条件：(1)具有中华人民共和国国籍；(2)拥护中华人民共和国宪法，享有选举权和被选举权；(3)具有良好的政治、业务素质和道德品行；(4)具有完全民事行为能力；(5)具备全日制普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位，全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得法律硕士、法学硕士及以上学位，全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得相应学位且

从事法律工作满三年。而以下人员不得报名参加国家统一法律职业资格考试：(1)因故意犯罪受过刑事处罚的；(2)曾被开除公职或者曾被吊销律师执业证书、公证员执业证书的；(3)被吊销法律职业资格证书的；(4)被给予二年内不得报名参加国家统一法律职业资格考试处理期限未满或者被给予终身不得报名参加国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)处理的；(5)因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象并纳入国家信用信息共享平台的；(6)因其他情形被给予终身禁止从事法律职业处理的。

第二节 法律职业伦理

一、法律职业伦理的概念

►法律职业伦理的含义

【分析】伦理是人类社会生活关系之规范、原理、规则的总称，其基础建立于个人的良心、社会之舆论以及习惯。各种职业因其性质、内容与社会期待的不同，存在着各种职业的伦理。法律职业伦理是指法律人在其职业实践中必须遵守的一种道德。法律职业伦理会因时代的不同而在内容上有所差异，但基本内容是相同的。

二、法律职业伦理的主要内容

►法官伦理

【分析】法官伦理是法官从事审判工作应遵循的基本准则。法官是依法行使国家审判权的审判人员，包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院的院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长和审判员（删除：等人员）。法官的根本职责是依法参加合议庭审判案件或者独任审判案件。要实现司法审判的公正和效率，法官起着决定性作用。而从某种意义上讲，只有高素质的法官队伍才能确保审判的公正和效率。

根据最高人民法院出台的《法官职业道德基本准则》，法官职业道德的核心是公正、廉洁、为民。其基本要求是忠诚司法事业、保证司法公正、确保司法廉洁、坚持司法为民、维护司法形象。强调法官应当自觉遵守法官职业道德，在本职工作和业外活动中严格要求自己，维护人民法院形象和司法公信力。

根据我国《法官法》第10条，法官应当履行下列义务：(1)严格遵守宪法和法律；(2)秉公办案，不得徇私枉法；(3)依法保障当事人和其他诉讼参与人的诉讼权利；(4)维护国家利益、社会公共利益，维护个人和组织的合法权益；(5)保守国家秘密和审判工作秘密，对履行职责中知悉的商业秘密和个人隐私予以保密；(6)依法接受法律监督和人民群众监督；(7)通过依法办理案件以案释法，增强全民法治观念，推进法治社会建设；(8)法律规定的其他义务。

►检察官伦理

检察官伦理是检察官从事检察工作应遵循的基本准则。检察官是依法行使国家检察权的检察人员，包括最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员（删除：等人员组成）。检察官的职责是依法进行法律监督工作，代表国家进行公诉和对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查等。

根据最高人民检察院发布的《检察官职业道德基本准则》，检察官应忠诚、公正、清廉、文明。检察官的职业道德基本准则包含五个方面：一是坚持忠诚品格，永葆政治本色；二是坚持为民宗旨，保障人民权益；三是坚持担当精神，强化法律监督；四是坚持公正理念，维护法制统一；五是坚持廉洁操守，自觉接受监督。

►律师伦理

律师伦理，是指律师接受委托为当事人提供法律服务过程中应遵循的基本伦理道德准则。

律师是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。律师这一职业

具有以下三个特点：第一，律师必须是受过法律专业训练，具备丰富法律知识的人；第二，律师必须是依法取得律师执业证书的人；第三，律师是为社会提供法律服务的执业人员。

依据我国《律师法》的规定，律师应当维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义。律师执业必须遵守宪法和法律，恪守律师职业道德和执业纪律。律师执业必须以事实为根据，以法律为准绳。律师执业应当接受国家、社会和当事人的监督。律师依法执业受法律保护，任何组织和个人不得侵害律师的合法权益。同时，《律师法》第40条还明确规定了律师在执业活动中不得从事的八类行为，主要包括：(1)私自接受委托、收取费用，接受委托人的财物或者其他利益；(2)利用提供法律服务的便利牟取当事人争议的权益；(3)接受对方当事人的财物或者其他利益，与对方当事人或者第三人恶意串通，侵害委托人的权益；(4)违反规定会见法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员；(5)向法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员行贿，介绍贿赂或者指使、诱导当事人行贿，或者以其他不正当方式影响法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员依法办理案件；(6)故意提供虚假证据或者威胁、利诱他人提供虚假证据，妨碍对方当事人合法取得证据；(7)煽动、教唆当事人采取扰乱公共秩序、危害公共安全等非法手段解决争议；(8)扰乱法庭、仲裁庭秩序，干扰诉讼、仲裁活动的正常进行。

全国律师协会于2014年出台《**律师职业道德基本准则**》，主要包括以下六方面内容：**一是忠诚信念**。律师应当坚定中国特色社会主义理想信念，坚持中国特色社会主义律师制度的本质属性，拥护党的领导，拥护社会主义制度，自觉维护宪法和法律尊严。**二是执业为民**。律师应当始终把执业为民作为根本宗旨，全心全意为人民群众服务，通过执业活动努力维护人民群众的根本利益，维护公民、法人和其他组织的合法权益。**三是信仰法治**。律师应当坚定法治信仰，牢固树立法治意识，模范遵守宪法和法律，切实维护宪法和法律尊严。在执业中坚持以事实为根据，以法律为准绳，严格依法履责，维护法律正确实施。**四是维护正义**。律师应当把维护公平正义作为核心价值追求，为当事人提供勤勉尽责、优质高效的法律服务，努力维护当事人合法权益。**五是恪守诚信**。律师应当牢固树立诚信意识，自觉遵守执业行为规范，在执业中恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责、严格自律。**六是履职尽责**。律师应当热爱律师职业，珍惜律师荣誉，树立正确的执业理念，不断提高专业素质和执业水平，注重陶冶个人品行和道德情操，忠于职守，爱岗敬业。

第三节 法律解释

一、法律解释的概念

►法律解释的含义；法律解释的必要性

【分析】法律解释是指一定的人或组织对法律规定含义的说明。法律解释既是人们日常法律实践的重要组成部分，又是法律实施的一个重要前提。与一般解释相比，法律解释的特点主要表现为：**第一，法律解释的对象是法律规定**。法律解释的任务是要通过研究法律文本及其附随情况，即制定时的经济、政治、文化、技术等背景情况，探求它们所表现出来的法律意旨。**第二，法律解释与具体案件密切相关**。法律解释往往由待处理的案件所引起，法律解释需要将条文与案件事实结合起来进行。**第三，法律解释具有一定的价值取向性**。法律解释的过程是一个价值判断和价值选择的过程。人们创制并实施法律是为了实现一定的目的，而这些目的又以某些基本的价值为基础。这些目的和价值就是法律解释所要探求的法律意旨。**第四，法律解释受解释学循环的制约**。解释学循环是解释学中的一个中心问题，它是指“整体”只有通过理解它的“部分”才能得到理解，而对“部分”的理解又只能通过对“整体”的理解来实现。

法律解释的必要性是由法律调整的特殊性及其运作的规律所决定的。**第一，由于法律具有概括性、抽象性的特点**，因此需要法律解释化抽象为具体，变概括为特定。**第二，由于人们在认识能力、认识水平上以及利益**

与动机的差别，会对同一法律规定有不同的理解，特别是对法律规定中一些专门术语有不同的理解。这就需要有权权威性的法律解释，来统一人们的理解，保证法的实施的统一性。第三，对于立法缺憾，需要通过法律解释来改正、弥补。任何法律体系中都不可避免地存在着应规定的而未作规定、规定不够准确清晰或界限不明等诸如此类的法律漏洞。为了弥补法律漏洞，使法律规范得以实施，有效地进行法律调整，法律解释就是必不可少的手段。第四；通过法律解释解决法律的稳定性与社会发展之间的矛盾。法律规范是相对稳定、定型的规则，而社会生活却是不断发展变化的。要把相对确定的法律规定适用于不断变化的法律实际，就需要对法律规范作出必要的解释。第五，通过法律解释普及法律知识，开展法治教育。开展法制宣传教育的法律解释工作，对全面推进依法治国，建设社会主义法治国家的伟大进程具有十分重要的意义。

二、法律解释的分类

►正式解释、非正式解释；限制解释、扩张解释和字面解释

【分析】根据解释主体和解释效力的不同区分，法律解释可以分为正式解释与非正式解释两种。是否具有法律上的约束力是区别正式解释与非正式解释的关键。正式解释，通常也叫法定解释，有时也称有权解释，是指由特定的国家机关、官员或其他有解释权的人对法律作出的具有法律约束力的解释。根据解释的国家机关的不同，法定解释又可以分为立法解释、司法解释和行政解释三种。非正式解释，通常也叫学理解释，一般是指由学者或其他个人及组织对法律规定所作的不具有法律约束力的解释。这种解释是学术性或常识性的，一般不被作为法律实施的依据。虽然如此，非正式解释在法律适用、法学研究、法学教育、法制宣传以及法律发展方面仍然有着很重要的意义。

根据解释尺度的不同，法律解释可以分为限制解释、扩张解释与字面解释三种。限制解释是指在法律条文的字面含义明显比立法原意广时，为贯彻立法意图，反映社会发展的实际需要，而作出比字面含义窄的解释。扩张解释是指在法律条文的字面含义显然比立法原意窄时，作出比字面含义广的解释。在我国，扩张解释不能任意扩大法律的内容，因此，它始终必须以立法意图、目的和法律原则为基础。字面解释是指严格按照法律条文字面的通常含义解释法律，既不缩小，也不扩大。

三、法律解释的方法

►文义解释；历史解释；系统解释；目的解释；其他解释方法

【分析】法律解释的方法是解释者在进行法律解释时为了达到解释的目标所使用的方法。对于法律解释的方法，大陆法系国家和普通法法系国家的概括和表述是有所不同的，国内学者以往的概括也多有不同。法律解释的方法大体上可概括为文义解释、历史解释、系统解释、目的解释等方法。这些方法有时是综合使用的。

文义解释，也称语理解释、文法解释、文理解释，是指遵循法律规范的字面含义的解释。这种解释按照法律条文的语言表述的字义、语法和通用的表达方式以及逻辑规律进行解释，目的在于使人们正确理解法律规范的含义和立法语言的含义。这种解释的特点是将解释的焦点集中在语言上，而不顾及根据语言解释出的结果是否公正、合理。

历史解释是指通过对法律文件制定的时间、地点、条件等历史背景材料的研究，或者通过将这一法律与历史上同类法律规范进行比较研究来阐明法律规范的内容和含义。进行历史解释的目的，主要是探求某一法律概念如何被纳入法条中来，立法者是基于哪些价值作出的决定。

系统解释，又称体系解释，是指通过分析某一法律规范在整个法律体系和所属法律部门中的地位和作用，来揭示其内容和含义。这种解释之所以必要，是因为每一个法律规范都是统一的法的整体的一部分，也是某一法律部门的一部分。它是在与相关法律规范的相互配合下发挥作用的。因此，要正确了解和适用某一法律规范，

就必须同其他法律规范联系起来理解，以便更好地了解它的真实内容和含义。

目的解释是指从制定某一法律的目的来解释法律。这里所讲的目的不仅可以指原先制定该法律时的目的，也可以是探求该法律在当前条件下的需要；既可以指整部法律的目的，也可以指个别法条、个别制度的目的。按照这种方法，在解释法律时应当首先了解立法机关在制定法律时所希望达到的目的，然后以这个目的或这些目的为指导，去说明法律的含义，尽量使有关目的得以实现。如果由于社会关系发展变化，原先的立法目的不能适应新的社会形势的需要，解释者可以通过这种解释方法，根据需要确定该法律的新的目的。

其他解释方法还有：

社会学解释，是指着重于社会效果的预测和社会利益的衡量，根据各种社会因素对法律规范的社会目的和社会效益进行解释，以更深刻地理解法律的社会内容和利益所在，适应社会的发展变化，使法律适用符合社会政策。

比较解释，是指通过比较外国的立法和判例及其原则、经验和效果，对本国法律进行解释。其不仅有助于在法的适用中准确理解立法原意，同时有助于弥补法律漏洞。

四、当代中国的正式法律解释

►立法解释；司法解释；行政解释

【分析】法律解释体制是指国家法律解释权限划分的制度。根据宪法和相关法律的规定，我国建立了以**全国人大常委会的解释权为核心和主体的各机关分工配合的法律解释体制**。相应来讲，法律解释分为立法解释、司法解释和行政解释三种形式。

立法解释。立法解释有广义和狭义两种理解。广义上的立法解释，泛指有权制定法律、法规的国家机关或其授权机关对自己制定的法律、法规所作的解释。对于狭义上的立法解释，有两种不同的观点：一种认为专指全国人大常委会对宪法和法律(狭义的法律)的解释，另一种认为立法解释还包括有关地方人大常委会对地方性法规的解释。这里我们采用狭义的理解，在狭义的理解中又限于国家最高立法机关全国人民代表大会常务委员会对法律的解释，也就是说，在我国，立法解释权属于全国人大常委会。立法解释包括对宪法的解释和对法律的解释，这里所说的法律是指狭义的法律。凡关于法律条文本身需要明确界限或补充规定的，由全国人大常委会进行解释或用法律加以补充规定。全国人大常委会的法律解释同法律具有同等效力。

在我国，立法解释的主要任务是：第一，阐明法律实施中产生的疑义。即对法律规定本身不十分清楚、明确的条文进行说明，或者规定本身虽然清楚、明确，但实施法律的人不了解立法者的立法精神，因此需要立法解释的。第二，适应社会发展，赋予法律规定以新含义。在没有对原法律进行修改、补充、废止之前，通过赋予法律规定新含义的方法以补充法律。第三，解决法条冲突以及司法解释之间的冲突。立法解释的主要方式是通过决定、决议进行有针对性的解释。

司法解释(包括审判解释和检察解释)。司法解释是国家最高司法机关对司法工作中具体应用法律问题所作的解释。司法解释分为最高人民法院的审判解释和最高人民检察院的检察解释。审判解释是指由最高人民法院对人民法院在审判过程中具体应用法律问题所作的解释。我国的审判解释权由最高人民法院统一行使，地方各级人民法院都没有对法律的审判解释权。检察解释是指由最高人民检察院对人民检察院在检察工作中具体应用法律问题进行的解释。在司法实践中，审判机关和检察机关为了更好地协调和配合，有时会采用联合解释的形式，共同发布司法解释文件。

司法解释的基本作用是为司法机关适用法律审理案件提供说明。这种作用具体表现为：第一，对法律规定不够具体而使理解和执行有困难的问题进行解释，赋予比较概括、原则的规定以具体内容。第二，通过法律解释适应变化了的社会情况。法律调整应当与社会现实相协调，应当随社会的发展而赋予某类行为以相应的法律

意义，作出适合社会发展的评价。第三，对适用法律中的疑问进行统一的解释。一种情况是在适用法律过程中对具体法律条文理解不一致，通过解释，统一认识，正确司法；另一种情况是为统一审理标准，针对某一类案件、某一问题或某一具体个案，就如何理解和执行法律规定而作出的统一解释。第四，对各级法院之间应如何依据法律规定相互配合审理案件，确定管辖以及有关操作规范问题进行解释。第五，通过解释活动，弥补立法的不足。

行政解释。行政解释指由国家最高行政机关，即国务院及其主管部门对有关法律和法规进行的解释。它包括两种情况：一种是对不属于审判和检察工作中的其他法律如何具体应用的问题所作的解释，另一种是国务院及其主管部门在行使职权时对自己制定的法规进行的解释。有权进行行政解释的机关包括制定行政法规的国务院以及制定行政规章的各部委。为了保证国家法制的统一，行政解释不得与宪法和法律相抵触。全国人大常委会会有权撤销国务院及其主管部门违反宪法和法律的解释。

第四节 法律推理与论证

一、法律推理的概念

►法律推理的含义；法律推理的特征

【分析】推理通常是人们逻辑思维的一种活动，即从一个或几个已知的判断(前提)得出另一个未知的判断(结论)。这种思维活动在法律领域中的运用泛称为法律推理。法律推理通常是指以法律与事实两个已知的判断为前提，运用科学的方法和规则，为法律适用提供正当理由的一种逻辑思维活动。法律推理的应用范围特别广泛，立法、执法、司法、法律监督乃至公民的法律意识中都有法律推理的活动，尤其是在法律适用过程中，法律推理占有显著的地位。

法律推理与一般的推理相比，其特征主要表现在：第一，法律推理是法律运用中的一种思维活动。它不仅需要对抽象的法律规范进行理解和选择，而且还需要将这种抽象的法律规范应用于具体案件之中，因此，它可能是一系列复杂的推理和论证活动的综合。第二，法律推理以法律与事实为两个已知的判断作为推理的前提。在法律规范所作出的规定和已判明的法律事实之间建立合理的联系，以此为前提，推理论证出适用结果，也就是“以事实为根据，以法律为准绳”。法律推理要受到现行法律的约束，现行法律是法律推理的前提和制约法律推理的条件。在缺乏明确的法律规定的情况下，有时法律原则、政策、法理等也会成为法律推理的前提。第三，法律推理运用多种科学的方法和规则进行。其中除了最基本的逻辑推理方法外，还需要应用一些非逻辑的分析和论证，比如价值分析判断等。第四，法律推理的目的是为法律适用提供正当理由。法律推理的结果与法律适用的理由相关，法律推理为适用结论提供正当理由，故推理过程实际上带有说明理由的成分。第五，法律推理的结果往往涉及当事人的利害关系。在许多情况下，法律推理的结论事关当事人是否拥有权利、是否应承担义务、是否应负法律责任等，而这些问题直接关系当事人的利益。

推理的方法有两大类：一是形式逻辑方法，二是辩证逻辑方法。法律推理按照这两种方法可以分为形式推理和实质推理两大类。

二、法律推理的方式

►形式推理；实质推理

【分析】形式推理又称分析推理，它是指运用演绎推理、归纳推理和类比推理解决法律问题的方法。演绎推理又可以称为三段论推理，它是从一般到特殊的推理形式，即从一般的知识推出特殊知识的推理活动。它是一种必然性推理。在成文法国家，这是一种主要的法律推理方式。在法律推理过程中，演绎推理的特

点是,法院有可以适用的**法律规则或原则(大前提)**,也有通过审理确定的、可以归入该规则或原则的**案件事实(小前提)**,由此法院可以作出一个确定的**判决(结论)**。

归纳推理是从特殊到一般的推理,即从个别知识推出一般知识的推理活动。它是一种或然性推理。在法律推理中,归纳推理是在没有现成的对号入座的法律规则或原则的情况下,法院从以往判例中总结出法律规则或原则的活动。它主要适用于**判例法国家**。由于归纳推理意味着确立新的规则,因此这实际上是一种立法活动。

类比推理是一种从个别到个别的推理,它是根据两类对象的某些属性的相似性推出它们在另一些属性方面也具有相似性的推理活动,也是一种或然性推理。在法律推理中,法院有时可以在确定两个案件的事实存在相似性的情况下,推定两个案件适用的法律以及判决结果也应相似。这就是所谓的“**类似案件,类似处理**”。在判例法国家,这是一种基本的法律推理方法。

实质推理又称**辩证推理**,它是指这样一种情形:当作为推理前提的是两个或两个以上的相互矛盾的法律命题时,借助辩证思维,从中选择出最佳的命题,以解决法律问题。辩证推理的作用主要是为了解决因法律规定的复杂性而引起的疑难问题。辩证推理是法官对法律或案件客观事实的辩证推理过程,它必须建立在事物的辩证法的客观基础之上,而绝不应该是从法官的主观想象中得出结论。

三、法律论证的概念

►法律论证的含义;法律论证的特点

【分析】论证,就是举示出一些论据来支持某种主张或判断。法律论证(legal argument),主要是指在司法过程中对判决理由的正当性、合法性或合理性进行论证,即在诉讼过程中,诉讼主体运用证据确定案件事实、得出结论的思维过程。法律论证的目的,是从多种合理甚至合法的法律主张中论证出最佳选择。它属于演绎论证和归纳论证之外的似真论(plausible argument),即合情理论证。

法律论证一般由两个部分组成,即法律问题和事实问题。由于事实、法律、社会等因素的变化,论证的结论有可能被证伪或被修正,因此,法律论证的结论不是绝对的,具有可废止性(defeasibility)。

四、法律论证的正当性标准

►内容融贯性;程序合理性;依据的客观性和逻辑有效性;效果最优性

【分析】对司法过程中判决理由的正当性论证需要达到一定的正当性标准,这些标准有:

一是内容的融贯性。所谓融贯性,是指法律体系本身的价值与事实、整体与部分、规则与原则、原理与精神的系统性、连贯性和一致性,以及法律体系与外部社会之间的内外融贯。融贯性标准不仅是在寻求一种法律意义上的合法性,而且是在追求一种广泛意义上的正当性,即社会认同,包括道德评价和利益平衡以及消弭事实与价值之间的差异,等等。

二是程序的合理性。法律论证理论建立在对结论的非绝对性、非唯一性认知上,论证过程的合理、公正决定着结论的正当性。因此,应建立相应的程序标准。谈判、调解、仲裁、听证会、论证会、法庭辩论和审判等各种机制和程序,各有特定的程序规则。如司法程序注重公开性、严格性和对抗性,而非司法程序则强调非公开性、灵活性和非对抗性;司法和行政执法程序以法律的运用和落实为主要目的,而民间机制则追求结果的合理性,并通过多元化和合理的程序,达致不同的正义结果。

三是依据的客观性和逻辑有效性。法律论证不是完全主观和随意的主张,而是必须依据基本的法律和社会规范以及合理的逻辑规则达成。尽管评价性判断的依据可能是多元的,但必须是客观的,如法律规则、政策、公共道德准则、科学依据、统计数据、行业惯例、地方习俗、民族习惯等。在论证中需要遵循基本的形式逻辑规则,如概念的一致性、逻辑的严谨性、因果关系的客观性等。不恰当的炒作、不确定的舆论、流言或臆测都

不符合法律论证的基本要求。

四是效果最优性。衡量法律论证的优劣，既要看形式、看过程，也要重结果、重实效。

当代中国法律论证，要跳出形式主义、教条主义的窠臼，充分考量方案所产生的社会效果，努力实现法律效果、政治效果、社会效果相统一。

第十章 法律关系

第一节 法律关系概述

一、法律关系的概念

►法律关系的含义：法律关系的特征

【分析】法律关系是根据法律规范产生、以主体之间的权利与义务关系的形式表现出来的特殊社会关系，即在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。在历史上，法律关系的观念最早来源于罗马法中“法锁”的观念，直到19世纪，法律关系才作为一个专门的概念而存在。

法律关系具有如下特征：

第一，法律关系是依法建立的社会关系。这一特征包含四个方面的含义：首先，法律规范的存在是法律关系产生的前提。如果没有相应的法律规范的存在，就不可能产生法律关系。其次，法律关系不同于法律规范调整或保护的社会关系本身。社会关系是一个庞大的体系，其中有些领域是属于法律所调整的，有些是不属于法律调整或法律不宜调整的，还有些是法律所保护的对象，这些被保护的社会关系不属于法律关系本身。再次，法律关系是法律规范的实现形式，是法律规范的内容在现实社会生活中得到的具体贯彻。人们按照法律规范的要求行使权利、履行义务并由此而发生特定的法律上的联系，既是一种法律关系，也是法律规范的现实状态。最后，法律关系是人与人之间符合法律规范的社会关系。在社会生活中，往往存在着大量的事实关系，它们没有严格的合法形式，甚至完全违背法律，如未经认可的收养关系、以规避法律为目的的契约关系、无效或失效的合同关系等。这些事实关系，都不能看作是法律关系，但是又可能与法律适用相关联，是法律适用过程中必须认真处理的一类法律事实。

第二，法律关系是一种体现意志性的特殊社会关系。法律关系属于思想社会关系和上层建筑现象。首先，法律关系是根据法律规范建立的，而法律规范是国家意志的体现。从实质上看，法律关系作为一种社会关系的特殊形式，正在于它体现了国家意志，从这个意义上讲，破坏了法律关系，其实也就违背了国家的意志。其次，法律关系参加者的意志对于法律关系的建立和实现也有着重要的作用。有的法律关系的建立要根据法律关系参加者的意志，如合同法律关系的建立，除了要有一般规定外，签订合同的各方还需要意思表示一致，不能把一方的意思强加给另一方；有的法律关系的建立只需要法律关系参加者一方的意志即可成立，如绝大部分行政法律关系；有的法律关系的产生可以不通过人的意志，而仅由于某种不以当事人的意志为转移的事件发生，如出生、死亡、自然灾害等。在法律关系产生或实现的过程中，国家意志和法律关系参加者的意志是相互作用的，一方面，法律关系参加者的意志必须符合国家意志，否则该法律关系得不到国家的确认和保护，法律关系不可能建立起来。在这个意义上，国家意志对于法律关系的产生和实现起着主导作用。另一方面，体现在法律规范中的国家意志，只有通过法律关系参加者的意志才能实现，否则法律规范所体现的权利和义务就只能是一种抽象的可能性和必然性，不能变成现实，在这个意义上，法律关系参加者的意志对于法律规范中所体现的国家意志的实现又是必不可少的。

第三，法律关系是以法律上的权利和义务为内容的社会关系。法律规范与法律关系中都包含着主体的权利

与义务，但它们在法律规范和法律关系中的表现形式不同。在法律规范中，主体的权利和义务只是一种可能性，是主体能做和应该做的行为，并不是现实行为，是在假定某种事实发生的情况下，设定主体有什么权利和义务，并不表明主体实际已经有了某种权利和义务。而在法律关系中，主体的权利和义务是现实的，法律规范所假定的事实已经发生，从而使主体之间产生了实际的权利义务关系。因此，法律权利和义务的内容是法律关系区别于其他社会关系的重要标志。

二、法律关系的分类

►基本法律关系与普通法律关系；平权型法律关系与隶属型法律关系；绝对法律关系与相对法律关系；其他分类

【分析】基本法律关系与普通法律关系是按照法律关系所体现的社会内容的性质所作的分类。基本法律关系是由宪法或宪法性法律文件所确认或创立的、直接反映该社会经济制度和政治制度基本性质的法律关系。基本法律关系主要包括公民与国家的关系、国家机构之间的关系、中央与地方的关系、民族之间的关系、所有制关系和分配关系等内容。基本法律关系是社会根本性的权利和义务关系，直接反映社会基本利益结构，并构成其他法律关系的基础。普通法律关系是依据宪法以外的法律而形成的，存在于各类权利主体和义务主体之间的法律关系。法律关系中的大部分是普通法律关系。

平权型法律关系与隶属型法律关系是按照法律关系主体的法律地位是否平等所作的分类。平权型法律关系是存在于法律地位平等的当事人之间的法律关系。所谓法律地位平等，指的是当事人之间没有隶属关系，也就是既不存在职务上的上、下级关系，也不存在一方当事人可以依据职权而支配对方的情形。这种平权型的法律关系以民事法律关系最为典型。当然，在民事行为领域之外也存在许多种平权型法律关系。隶属型法律关系是一方当事人可依据职权而直接要求他方当事人为或不为一定行为的法律关系。隶属型法律关系既存在于具有职务关系的上、下级之间，也存在于依法享有管理职权的国家机构和在其管辖范围内的各种主体之间。在这种法律关系中，行使职权的机关可通过单方面的意思表示而要求相对人服从。绝大部分行政法律关系属于隶属型法律关系，在这种法律关系中，行使职权的机关可以通过单方面的意思表示要求相对人服从。

绝对法律关系与相对法律关系是按照法律关系主体是否完全特定化所作的分类。绝对法律关系指的是权利主体特定而义务主体不特定的法律关系。绝对法律关系的特点是，只有权利主体是特定的、具体的，而义务主体则是不特定的、不具体的。绝对法律关系以“一个人对一切人”的形式表现出来，即一个特定的人与其他相对人之间的法律关系。相对法律关系是存在于特定的权利主体和特定的义务主体之间的法律关系。相对法律关系的特点是参加法律关系的双方或数方均是特定的、具体的人，其表现形式是“某个人对某个人”。

此外，根据法律关系产生的依据、作用和实现规范的内容不同，还可以将法律关系分为调整性法律关系与保护性法律关系。调整性法律关系是基于人们的合法行为产生的、发挥法的调整作用的法律关系，它所实现的是法律规则逻辑结构中的行为模式的内容。调整性法律关系不需要适用法律制裁措施，法律主体之间即能够依法行使权利、履行义务，如各种依法建立的民事法律关系、行政合同关系等。保护性法律关系是由于违法行为而产生的、旨在恢复破坏的权利和秩序的法律关系，如刑事法律关系，它发挥着法的保护作用，所实现的是法律规则逻辑结构中的法律后果的内容，是法的实现的非正常形式。

第二节 法律关系的构成要素

一、法律关系的主体

►法律关系的含义；法律关系的类型；法律关系主体的权利能力和行为能力

【分析】法律关系的主体是指法律关系的参加者，即法律关系中权利的享有者和义务的承担者。法律关系的主体具有法律性和社会性。法律关系主体的法律性是指法律关系主体是由法律规范所规定的，不在法律规定的范围内，不得任意参加法律关系，成为法律关系的主体。例如，低于法定结婚年龄的人不得成为婚姻法律关系的主体。法律关系主体的社会性是指法律规范规定什么人和社会组织能够成为法律关系主体，这不是任意的，而是由一定的物质生活条件决定的。比如，在奴隶制国家的法律中，只有自由民才是法律关系的主体，奴隶不是法律关系的主体。这一法律规定是由奴隶制生产方式决定的。可见，法律关系主体的范围虽然表面上是法律规定的，但是法律规范并不是确定其主体资格的最终根源。立法者不能任意规定权利主体的范围。

在我国，能够参与法律关系的主体包括自然人(公民)、法人、其他社会组织和国家。自然人是指有生命并具有法律人格的个人，包括中国公民、居住在中国境内或在中国境内活动的外国公民。在我国，外国公民参加法律关系的范围是有限制的，以我国有关法律以及我国与有关国家签订的条约为依据。法人是与自然人相对称的概念，指具有法律人格，能够以自己的名义独立享有权利或承担义务的组织，是由法律赋予人格并将其视同自然人一样有独立的意志和利益的社会组织体。有时国家也作为特殊的法人参加民事法律关系或国际法律关系。

法律关系主体参加法律关系还有资格上的限制，这在法学上被称为权利能力和行为能力。权利能力是权利主体享有权利和承担义务的能力，它反映了权利主体取得享有权利和承担义务的法律资格。

公民的权利能力分为一般权利能力和特殊权利能力两种。一般权利能力为所有公民普遍享有，始于出生，终于死亡，如人身权利能力等。特殊权利能力须以一定的法律事实出现为条件才能享有，如参加选举的权利能力须以达到法定年龄为条件。法人的权利能力始于法人依法成立，终于法人被解散或撤销。法人权利能力的内容和范围与法人成立的目的直接相关，并由有关法律和法人组织的章程加以规定。

行为能力是权利主体能够通过自己的行为取得权利和承担义务的实际能力。行为能力以权利能力为前提，自然人有权利能力并不一定有行为能力，法人的权利能力和行为能力是一致的。例如，我国《民法典》根据年龄和认知状态的不同，将自然人的民事行为能力划分为三种情况。一是已满18周岁且精神正常的自然人具有完全的民事行为能力；二是已满8周岁的未成年人，具有限制民事行为能力；三是未满8周岁的未成年人无民事行为能力。与此相应，精神病人和间歇性精神病人等因不能正确认知，分别归入无民事行为能力人和限制民事行为能力人范畴。

二、法律关系的内容

►法律权利；法律义务；法律权利与法律义务的相互关系

【分析】法律意义上的权利一词最早来源于罗马法。从形式意义上讲，法律权利的一般含义是，国家通过法律赋予法律关系主体可以自主决定做出某种行为的能力或资格。法律意义上的权利与其他性质之权利的主要区别在于，它是体现国家意志的法律、法规所承认和保护的权利。权利和法一样受着社会经济关系的制约，权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会文化发展。广义上的法律权利包含了权力，从字面上讲，职权、权限、权力等词与权利一样。但是在实际使用中，它们与权利的主要区别在于：第一，在我国现行宪法中，对中央国家机关使用职权一词，对地方国家机关使用权限一词，对公民则使用权利一词。第二，权利主体一般是公民与法人和其他社会组织，权力主体则只能是被授予权力的国家机关及其特定的工作人员。第三，权利和权力的自由度不同。权利主体对其享有的某些权利是可以转让或放弃的，职权不能放弃、不可让与。第四，权力的强制性是直接的，权利的强制性则是以权力为中介的，是间接的。

法律义务是指国家通过法律对法律关系主体的行为作出的限制和约束，包括作为义务和不作为义务。

法律权利和法律义务是一对表征法律主体关系和状态的范畴，是法学范畴体系中最基本的范畴。义务是权利的关联词或对应词，两者相辅相成，有权利即有义务，有义务即有权利，没有无权利的义务，也没有无义务

的权利，二者互为目的，互为手段。从本质上看，权利是指法律所保护的某种利益；从行为方式的角度看，它表现为要求权利相对人可以怎样行为，必须怎样行为或不得怎样行为。权利的实现离不开义务的履行，它反映着主体在社会关系中独立自主和相互协作的关系的状态。人是社会生活的主体，也是社会发展的主体，同时，人又是社会发展所要保护和实现的目标。在社会生活中，每个人都有生存的需求，有满足自己基本利益和需求的愿望，人的生活需求既是一切社会活动的动机，也是权利概念存在的前提。但是，由于社会分工和利益资源的制约，每个人自身利益的实现和满足又离不开他人的协作和帮助，每个人必须为社会承担一定的责任，这就构成了义务概念存在的客观基础。

三、法律关系的客体

►法律关系的含义；法律关系的类型

【分析】法律关系客体是指法律关系主体之间权利和义务所指向的对象。它是构成法律关系的要素之一。法律关系客体是一个历史的概念，随着社会历史的不断发展，其范围、形式和类型也在不断地变化。总体来看，由于权利和义务类型的不断丰富，法律关系客体的范围和种类有不断扩大和增多的趋势。归纳起来，法律关系客体包括物、行为、精神产品(非物质财富)、人身、数据信息。

物。法律意义上的物是指法律关系主体支配的、在生产上和生活中所需要的客观实体。它可以是天然物，也可以是生产物；可以是活动物，也可以是不活动物。作为法律关系客体的“物”与物理意义上的“物”既有联系，又有不同，它不仅具有物理属性，而且应具有法律属性。物理意义上的物要成为法律关系客体，须具备以下条件：第一，应得到法律的认可。第二，应为人类所认识和控制。不可认识和控制之物(如地球以外的天体)不能成为法律关系客体。第三，能够给人们带来某种物质利益，具有经济价值。第四，须具有独立性。不可分离之物(如道路上的沥青、桥梁之构造物、房屋之门窗)一般不能脱离主物，故不能单独作为法律关系客体存在。

行为。在很多法律关系中，其主体的权利和义务所指向的对象是行为。作为法律关系客体的行为是特定的，即义务人为了满足权利人的利益要求而完成的行为，包括作为和不作为，又称积极行为和消极行为。

精神产品。精神产品是人通过某种物体(如书本、砖石、纸张、胶片、磁盘)或大脑记载下来并加以流传的思维成果。精神产品不同于有体物，其价值和利益在于物中所承载的信息、知识、技术、标识(符号)和其他精神文化，也不同于人的主观精神活动本身，而是人的主观精神活动的物化、固定化。精神产品属于非物质财富。

人身。人身是由各个生理器官组成的生理整体(有机体)。它是人的物质形态，也是人的精神利益的体现。在现代社会，随着现代科技和医学的发展，人身不仅是人作为法律关系主体的承载者，而且在一定范围内还会成为法律关系的客体。但必须注意的是：第一，活人的(整个)身体，不得视为法律上之“物”，不能作为物权、债权和继承权的客体，禁止任何人(包括本人)将整个身体作为“物”参与有偿的经济法律活动，不得转让或买卖。第二，权利人对自身的人身不得进行违法或有伤风化的活动，不得滥用人身或自贱人身和人格。第三，对人身行使权利时必须依法进行，不得超出法律授权的界限，严禁对他人人身非法强行行使权利。

数据信息。作为法律关系客体的数据信息，是指以数据形式存在的有价值的信息或资讯，如工商业情报、国家机密、个人信息等，其中既有人工处理的数据信息，也有很多自然生成的数据信息。因此它既不是物，也不等同于精神产品。随着以互联网、物联网、数码存储和处理技术的发展为主要表征的信息新时代的到来，数据信息作为法律关系客体的地位将愈加重要。

第三节 法律关系的产生、变更与消灭

一、法律关系产生、变更与消灭的条件

►抽象条件；具体条件

【分析】法律关系的产生、变更和消灭称为法律关系的演变。由于社会生活本身是不断变化的，法律关系也就不能不具有某种流动性，每一法律关系自产生后都可能在一定条件下趋于变更或消灭。**法律关系的产生指的是在主体之间出现了权利、义务关系；法律关系的变更指的是法律关系的主体、客体或内容中的任何一项发生了变化；法律关系的消灭指的是主体间权利义务关系完全终止。**

法律关系的产生、变更与消灭不是随意的，必须符合两方面的条件：**一是抽象的条件，即法律规范的存在，这是法律关系形成、变更与消灭的前提和依据。二是具体的条件，即法律事实的存在，也就是法律规范中假定部分所规定的各种情况，一旦这种情况出现，法律规范中有关权利和义务的规定以及有关行为法律后果的规定就发挥作用，从而使一定的法律关系产生、变更或消灭。**

二、法律事实

►法律事实的含义；法律事实的分类：法律事件和法律行为

【分析】**法律事实是指能够引起法律关系产生、变更或消灭的各种事实的总称。**法律事实与一般意义上的事实有重要区别。法律事实是一种**规范性事实**，没有法律规范就不会有法律事实。法律事实不仅是客观事实，而且还是**能用证据证明的客观事实**。法律事实是一种**具有法律意义的事实**。

按照**法律事实是否与当事人的意志有关**，可以把法律事实分为**法律事件和法律行为**，这是一种最基本、最重要的分类。

法律事件，是法律规范规定的、与当事人意志无关的，且能够引起法律关系产生、变更或消灭的客观事实。根据事件**是否由人们的行为而引起**可以划分为**绝对事件和相对事件**。**绝对事件**不是由人们的行为而是由**某种自然原因引起**的，例如人的出生和自然死亡、时间的流逝等自发性质的现象。人的死亡引起婚姻法律关系的消灭、劳动关系的消灭，人的出生引起父母与子女的法律关系的产生等。**相对事件**是由**人们的行为引起**的，但它的出现在该法律关系中并不以法律关系主体意志为转移。总之，事件的出现与当事人的意志无关。导致事件发生的原因，既可以来自社会，也可以来自自然，另外也可能来自时间的流逝，如各种时效的规定等。

从法律关系的角度看，**法律行为指的是与当事人意志有关的，能够引起法律关系产生、变更或消灭的作为和不作为。**行为一旦作出，也是一种事实，它与事件的不同之处在于当事人的主观因素成为引发此种事实的原因。因此，当事人既无故意又无过失，而是由于不可抗力或不可预见的原因而引起的某种法律后果的活动，在法律上不被视为行为，而被归入意外事件。法律上所说的行为仅指与当事人意志有关且能引起法律关系后果的那些行为。

需要注意的是，**同一个法律事实可以引起多种法律关系的产生、变更和消灭。**例如，工伤致死，不仅可以导致劳动关系、婚姻关系的消灭，而且也导致劳动保险合同关系、财产继承关系的产生。**有时候一个法律关系的产生、变更或消灭需要同时有两个或两个以上的法律事实。**在法学上，人们常常把两个或两个以上的法律事实构成的一个相关整体称为“**事实构成**”。

第十一章 法律责任与法律制裁

第一节 法律责任

一、法律责任的概念

►法律责任的含义；法律责任的种类

【分析】**法律责任是指行为人由于违法行为、违约行为或者由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果。**

法律责任是社会责任的一种，它与其他社会责任的区别在于，承担法律责任的最终依据是法律，法律责任具有国家强制性。产生法律责任的原因主要有三类，即违法行为、违约行为和法律规定。**法律责任的目的在于保障法律上的权利、义务、权力得以生效**，在它们受到阻碍而使法律所保护的利益受到侵害时，通过适当的救济，使对侵害发生有责任的人承担责任、消除侵害并尽量减少未来发生侵害的可能性。法律责任的目的是通过其**惩罚、救济和预防**三个功能的发挥来实现的。

法律责任包括刑事责任、民事责任、行政责任和违宪责任。

刑事责任是指行为人因其犯罪行为所必须承受的，由司法机关代表国家所确定的否定性法律后果。它是犯罪人向国家所负的一种法律责任，追究刑事责任的唯一法律依据是刑事法律。刑事责任是一种惩罚性的责任，是所有法律责任中最严厉的一种。刑事责任通常由个人承担，也有一些刑事责任由法人或其他组织承担。

民事责任是指行为人由于违反民事法律、违约或者由于民法规定所应承担的一种法律责任。民事责任主要是一种**救济责任**，其功能主要在于救济当事人的权利，赔偿或补偿当事人的损失。当然，民事责任也具有**惩罚的功能**，比如违约金本身就含有惩罚的意思。民事责任主要是一种**财产责任**，比如赔偿损失、支付违约金等都是**以财产为内容的**。民事责任主要是一方当事人对另一方的责任，在法律允许的情况下，民事责任可以由当事人协商解决。民事责任可以分为违约责任和侵权责任。

行政责任是指因违反行政法规定或因行政法规定而应承担的法律责任。承担行政责任的主体是**行政主体和行政相对人**。产生行政责任的原因是行为人的行政违法行为或法律法规的规定。与刑事责任和民事责任相比，行政责任的承担方式较为多样化，可以是行为责任、精神责任、财产责任，甚至还可以是人身责任。这些责任方式共同执行着行政责任惩罚、救济和预防的功能。

违宪责任是指由于有关国家机关制定的某种法律、法规和规章与宪法规定相抵触，或有关国家机关、社会组织或公民从事了与宪法规定相抵触的活动，而产生的法律责任。违宪责任产生的原因是违宪行为。

二、法律责任的构成

►责任主体；违法行为；损害结果；因果关系；主观过错

【分析】法律责任的构成要件是指承担法律责任必须具备的各种条件或必须符合的标准，它是国家机关要求行为人承担法律责任时进行分析、判断的标准。根据违法行为的一般特点，我们把法律责任的构成要件概括为责任主体、违法行为、损害结果、因果关系、主观过错五个方面。

责任主体是指承担法律责任的主体。责任主体必须具有法定责任能力，能够成为违法主体并且承担法律责任的自然人必须是达到法定年龄并具有责任能力的人；能够成为违法主体并且承担法律责任的组织必须是能够独立承担民事责任或具备刑事责任能力的法人或组织。

违法行为是指违反法律规定的义务、超越权利的界限行使所谓的权利以及侵权行为的总称。广义上的违法行为包括一般违法行为和犯罪行为。狭义上的违法行为仅指除犯罪以外的一般违法行为。一般情形或多数情形下，违法行为是法律责任产生的前提，没有违法行为就没有法律责任。但在**特殊情况下，法律责任的承担不以**

违法行为为构成条件，而是以法律规定为构成条件。

损害结果是指由于违法行为所导致的损失和伤害的事实，包括人身、财产和精神方面的损失和伤害。损害应当具有确定性，必须是一个确定的现实存在的事实。有些法律责任的承担不以实际损害结果的存在为条件，比如危害国家安全犯罪。财产损害一般包括实际损害、丧失所得利益及预期可得利益。

因果关系即违法行为与损害结果之间的因果关系，它是存在于自然界和人类社会中的各种因果关系的特殊形式。法律归责原则上要求证明违法行为与损害结果之间的因果关系。

主观过错指承担法律责任的主体在主观上存在的故意或者过失。故意和过失在不同的法律领域中具有不同的意义。在刑事法律领域，行为人故意或过失的心理状态是判定其主观恶性的的重要依据，也是区别罪与非罪、此罪与彼罪、罪轻与罪重的重要依据。在民事法律领域，故意和过失被统称为过错，是构成一般侵权行为的要素。在行政法律领域，实行过错推定的方法，一般只要行为人实施了违法行为就视其为主观有过错，法律另有规定的除外。

三、归责与免责

►归责的含义；归责的原则；免责的含义；免责的条件

【分析】归责，也叫法律责任的归结，是指由特定的国家机关或国家授权的机关依法对行为人的法律责任进行判断、确认、追究和减免的活动。不同的法律责任具有不同的构成要件。责任的成立与否，取决于行为人的行为及其后果是否符合责任的构成要件。

归责是一个复杂的责任判断过程，判断、确认、追究以及免除责任时必须依照一定的原则。归责的原则是特定法律制度价值取向的体现，它一方面指导着法律责任的立法，另一方面指导着法律实施中对责任的认定与归结。

在我国，归责的原则主要包括责任法定原则、因果关系原则、责任相称原则、责任自负原则等。

责任法定原则，是指法律责任作为一种否定的法律后果应当由法律规范预先规定，包括在法律规范的逻辑结构之中，当出现违法行为或法定事由的时候，按照事先规定的责任性质、责任范围、责任方式等追究行为人的责任。责任法定原则的内容包括：刑事法律是追究刑事责任的唯一法律依据，罪刑法定；由特定的国家机关或国家授权的机构归责；反对责任擅断；反对有害追溯；同时，允许人民法院行使一定的自由裁量权，准确认定和归结行为人的法律责任。

因果关系原则，是指在认定行为人违法责任之前，首先应当确认行为与危害或损害结果之间的因果关系；其次应当确认意志、思想等主观方面因素与外部行为之间的因果关系；再次还应当区分这种因果关系是必然的还是偶然的，直接的还是间接的。

责任相称原则，是指法律公正精神在法律责任归结上的具体表现。其含义是指，法律责任的性质与违法行为性质应当相适应，法律责任的轻重和种类应当与违法行为的危害或者损害相适应，还应当与行为人主观恶性相适应。

责任自负原则，是指违法行为人应当对自己的违法行为负责，不能让没有违法行为的人承担法律责任，即反对株连或变相株连；要保证责任人受到法律追究，也要保证无责任者不受法律追究，做到不枉不纵。当然，在某些特殊情况下，为了法律秩序特别是财产保护上的需要，也产生责任转承问题，比如监护人对被监护人承担替代责任，上级对下级承担替代责任等。

免责，也称法律责任的减轻和免除，是指法律责任由于出现法定条件被部分或全部地免除。免责不同于“不负责任”或“无责任”，因为免责以法律责任的存在为前提，而后两者并不存在责任。不应把未达到法定责任年龄、精神失常、正当防卫、紧急避险等不负法律责任的条件当作免除责任的条件。免责并不意味着被免责的违

法行为是合理的、法律允许的或法律不管的，更不意味着被免责的行为是法律所赞成或支持的。

在我国的法律规定和法律实践中，免责的条件和情况是多种多样的。免责的条件主要包括时效免责、不诉免责、自首立功免责、有效补救免责、自助免责、协议免责等。

时效免责，指违法者在其违法行为发生一定期限后不再承担强制性法律责任，如果没有法律的特别规定，违反法律的行为超过一定的期限将不再被追究法律责任，法律责任因时间流逝而消失。

不诉免责，即所谓“告诉才处理”“不告不理”。在我国，不仅大多数民事违法行为是受害人或有关人员告诉才处理，而且有些刑事违法行为也是不告不理。不告不理意味着当事人不告，国家就不会把法律责任归结于违法者，亦即意味着违法者实际上被免除了法律责任。

自首立功免责，指对那些违法之后有自首或立功表现的人，免除其部分或全部法律责任。

有效补救免责，指对于那些实施违法行为，造成一定损害，但在国家机关归责之前采取及时补救措施的人，免除其部分或全部责任。

自助免责，指对自助行为所引起的法律责任的减轻或免除。所谓自助行为是指权利人为保护自己的权利，在情势紧迫而又不能及时请求国家机关予以救助的情况下，对他人的财产或自由施加扣押、拘束或其他相应措施，而为法律或公共道德所认可的行为。自助行为可以免除部分或全部法律责任。

协议免责，指加害人和受害人在法律允许的范围内通过协商的方式减轻或免除法律责任。此种免责一般适用于民事违法行为，而不适用于犯罪行为和行政违法行为。

第二节 法律制裁

一、法律制裁的概念

►法律制裁的含义：法律责任与法律制裁的关系

【分析】法律制裁是由特定的国家机关对违法者(或违约者)依其所应承担的法律责任而实施的强制性惩罚措施。根据违法行为、违约行为和法律责任的性质不同，法律制裁可以分为刑事制裁、民事制裁、行政制裁和违宪制裁。

法律责任与法律制裁具有密切关系。法律制裁是承担法律责任的一个重要方式。应承担法律责任是实施和接受法律制裁的前提，法律制裁是具体承担法律责任的结果或体现。法律责任与法律制裁又有明显的区别。法律责任并不等于法律制裁，有法律责任并不一定就有法律制裁。

二、法律制裁的种类

►刑事制裁；民事制裁；行政制裁；违宪制裁

【分析】法律制裁的种类有如下几种：

刑事制裁是司法机关对于犯罪者根据其所应承担的刑事责任而确定和实施的强制性惩罚措施。刑事制裁以刑罚为主，承担刑事责任的主体既可以是公民，也可以是法人或其他组织。

根据我国刑法的规定，刑罚分为主刑和附加刑两类。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括罚金、剥夺政治权利和没收财产等。刑罚是一种最严厉的法律制裁。

民事制裁是由法院确定并实施的，对民事责任主体依其所应承担的民事责任而给予的强制性惩罚措施。我国现行民事制裁的方式主要有：停止侵害，排除妨碍，消除危险，返还财产，恢复原状，修理、重作、更换，赔偿损失，支付违约金，消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。这些方式可以单独适用，也可以合并适用。我国人民法院审理民事案件，除适用以上制裁方式外，还可以对违法者予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动

的财物和非法所得等。民事制裁在制裁目的、制裁程序和制裁方式上不同于刑事制裁。民事制裁是以财产关系为核心的、适用范围最为广泛的法律制裁形式。

行政制裁是指国家行政机关对行政违法者实施的强制性惩罚措施。根据行政违法的社会危害程度、实施制裁的方式等不同，行政制裁又可分为行政处分和行政处罚两种。**行政处分**是国家行政机关或其他组织依照行政隶属关系，对于**违法失职的国家公务员或所属人员**实施的惩罚措施，主要有**警告、记过、记大过、降级、撤职、开除**等形式。**行政处罚**是由特定机关依法对**违反行政法规的公民或社会组织**实施的惩罚措施，其处罚方式主要有**警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或吊销许可证、行政拘留**等。其中，限制人身自由的处罚，只能由法律设定。

违宪制裁是对违宪行为所实施的一种强制措施。在我国，监督宪法实施的**全国人民代表大会及其常务委员会**是行使违宪制裁权的机关。承担宪法责任的主体主要是国家机关及其领导干部。制裁措施有：**撤销或改变同宪法相抵触的法律、行政法规、地方性法规，罢免违宪的国家机关、领导成员**等。

第十二章 法治

第一节 法治概述

一、法治的概念

►法治的含义

【分析】法治是一种治国方略，是将国家权力的行使和社会成员的活动纳入完备的规则系统，以保障公民权利和自由得以实现的国家治理方式。在不同的时代，人们赋予法治不同的社会内涵和意义。在各种不同的表达方式中，法治包含着多种内涵和意义：首先，法治意指一种崇尚法律至上的治国方略或社会调控方式，在这个意义上，法治是相对于人治而言的；其次，法治意指良好的法律秩序，即在内容上以保护公民权利和限制国家权力为目的；最后，法治代表某种包含特定价值规定性的社会生活方式，是对社会所进行的符合特定价值的治理。

►法治与法制

【分析】法制一词具有多种含义。但是，其通常在两种意义上使用：一种是静态意义上的法制，即法律和制度；另一种是动态意义上的法制，即指立法、执法、司法、守法和法律监督的活动和过程。

法治与法制相比，两者的不同主要表现在以下几个方面：

第一，法治不仅包括形式意义上的法律制度及其实施，更强调实质意义上的法律至上、权利保障的内涵；而法制则侧重于形式意义上的法律制度及其实施。

第二，法治关注法律制度的内容，讲究“良法”之治，强调法律的至高权威，强调法律的公正性、稳定性、普遍性、公开性和平等性，以及对权力的制约与对人权的保障；而法制则侧重于关注法的规范性和有效性，要求严格依法办事，以实现立法者期望的法律秩序，对法律本身的内容和价值取向并无特殊的规定性。只要有法律和制度存在就有法制存在，但这不一定就是法治。

第三，法治与人治是相对立的，法治要求“法律的统治”，将法律置于统治者的权力之上，要求公共权力必须依法取得和行使；而法制与人治并不截然对立，历史上，专制君主和法西斯独裁统治者为了建立有利于他们的统治秩序，也可以在一定时期建立或推行法制。

第四，法治的政治基础是民主政治，其根本意义在于制约国家权力，以确认和保障公民的权利和自由，实现公民对国家和社会事务的管理。在没有民主和宪治的时代，不可能有真正的法治；法制的问世则先于法治，

早在没有民主和宪治的时候，就已经存在法制。古代东方和西方都有倡导法制者，那时的法制与民主和宪治无关，而是专制和主权的统治工具。

►法治与人治

【分析】法治是与人治对立的治国方略。在古代和近代史上，这种对立的内容和表现形式是不尽相同的。在古代中国，法治论者强调把社会关系纳入法律的轨道，用带有权威性、强制性的法律规范或严刑峻法治理社会，这种法治论与近现代意义上的法治论有着本质上的区别，实际上属于法制的范畴。人治论者则认为“为政在人”（出自《论语·为政》，强调重视人的作用。在古希腊，法治强调法律的理性及其一般的指引作用，人治则强调圣贤的智慧及其解决具体问题的个别指引作用。近代以来，法治与人治的对立主要表现为主权在民与主权在君、法律与当权者个人意志之间的对立。法治与人治的区别主要表现为：法治是民主政治，人治一般是君主专制或贵族政治；法治依据的是反映众人意志的法律，人治依据的是统治者个人或少数人的意志；当法律与当权者个人的意志发生冲突时，法治国家中的法律高于个人意志，而在人治国家中则相反。

►法治与民主

1. 法治与民主的一般关系

【分析】“民主”（democracy）一词源于古希腊语，其最初的含义就是“人民的权力”或“多数人的统治”，指的是一种国家制度、政治制度。作为一种制度，民主的最大特点在于，它以公民的意志作为其政治合法性的基础。作为政治制度，民主不仅指国家的组织形式，即政体，而且也指国家的本质，即国体，即什么阶级在国家中占有支配地位。

民主与法治都是人类文明进步一直追求的价值目标，现代民主制可能是最易与法治原则相融合的制度。一方面，法治是一种以民主宪治为核心的政治法律制度，法治与民主息息相关，没有民主就没有法治。作为一种政治法律制度，法治必须建立在民主基础上，民主化是实现法治的先决条件。另一方面，从民主的发展史来看，民主理念要在国家统治中得到实现，离不开法治。法治用程序保障了民主制的正常运行，没有法治及相关的意识形态建设，民主政治就缺乏根本，甚至会走向反面，法治的确立有助于培养与民主相适应的思想和道德。法治将民主制度化、法律化，为民主创造一个可操作的、稳定的运行和发展空间，把民主容易偏向激情的特性引导到理性的轨道，为民主的健康发展保驾护航。

2. 社会主义法治与社会主义民主的关系

【分析】社会主义民主是社会主义法治的前提，社会主义法治是社会主义民主的保障。

社会主义法治与社会主义民主有着非常密切的关系，两者相互依存，不可分离。如果开社会主义民主讲法治，法治就可能改变性质；如果离开社会主义法治来讲民主，民主就可能失去强有力的保障，就可能偏离社会主义方向。

社会主义民主是社会主义法治的前提或基础，社会主义民主对社会主义法治的积极作用主要表现在：第一，从民主作为一种国家制度来看，社会主义民主是社会主义法治的政治前提或基础；第二，从民主作为一种公共决策方法和机制来看，社会主义民主决定着法的创制的质量；第三，社会主义民主是社会主义法治的力量源泉；第四，社会主义民主在促进社会主义法治发展方面也有重大作用。

社会主义法治是社会主义民主的保障。社会主义民主内在需要社会主义法治，要求法治原则贯穿于民主发展的全过程。没有社会主义法治也就不会有真正的社会主义民主，应当通过法治来积极推进民主的进程。社会主义法治对社会主义民主的积极作用主要表现在：第一，社会主义法治确认人民群众当家作主的地位，确认国家的基本民主体制及其活动原则的合法性；第二，社会主义法治确认和保障广大人民群众享有广泛的民主权利和自由，为政治参与提供畅通的渠道；第三，社会主义法治确认和规范社会主义民主的范围以及实现社会主义民主的程序和方式；第四，社会主义法治是保卫社会主义民主的重要武器。

二、法治的基本原则

►法律至上原则；权利保障原则；权力制约原则；正当程序原则

【分析】法律至上是法治区别于人治的根本标志，也是法治的首要条件。法律至上原则是指法律具有至高无上的地位与权威的法治原则，它是法治中最基本的重要原则，其中宪法至上是法律至上原则的核心。不确立法律至上原则，即使法律完全建立在民主基础上，也仅是“纸上的法律”，人权保障、法律面前人人平等、政府权力受制约等原则均无法实现。法律至上原则意在强调法律在整个社会规范体系中具有至高无上的地位，其他任何社会规范都不能否定法的效力或与法相冲突。

权利保障原则的内容主要包括国家尊重和保障人权、法律面前人人平等和权利与义务相一致。从一定意义上说，法治的所有价值目标都可以归结为国家充分尊重和保障人权，促进公民自由意识和能力的提高。对国家权力的法律限制本身就是对人权的有力保障。法律至上的最终目标也是为人的权利和自由发展服务的。因此可以说，充分尊重和保障人权是法治的终极性的目的价值。首先，法律面前人人平等是民主和法治的基本要求。法治原则首先要求法律运用上的平等，即在执法和司法过程中，对一切公民权利和自由的平等保护，对一切主体义务的平等要求，对违法行为平等地追究法律责任，不承认任何法外特权。其次，法律面前人人平等还要求在立法上平等分配各种社会资源。此外，平等还意味着尊重社会主体的多元价值观和生活方式，消除歧视与偏见。法治的权利保障原则还要求在法的制定和实施过程中贯彻主体的权利与义务相一致原则。没有无权利的义务，也没有无义务的权利，这是平等原则的必然要求。对国家权力而言，在资源分配上不能将权利只分配给一部分人，而将义务分配给另一部分人；对社会主体而言，在行使权利时，也必须尊重他人和社会的相应权利，不能只享有权利而不承担义务。

法治要求对国家权力进行合理的分配和有效的制约。权力如何分配和制约是法治国家权力结构的基本问题。法治的目的在于运用法律防止国家权力的专横、恣意和腐败，保障公民的权利和自由。法治所强调的对国家权力进行制约，是权力之间的相互制约。让权力之间互相监督，是维护法的权威、保证国家权力的执行者不违背法律的有力措施。法治原则特别强调对国家行政权力的制约，要求严格依法行政。因为行政机关执掌着大量日常公共生活的组织指挥权能，代表公权力，能够通过各种抽象和具体的行政行为直接干预公民和社会组织的活动，行政权力行使的广泛性、主动性和强制性、单方面性等都使得对行政权的约束成为法治的重点。

正当程序原则主要是针对国家公权力而言的，即国家机关在行使权力时，应当按照公正的程序采取公正的方法进行。它强调程序正义，如个人不能作自己的法官、法官应听取双方当事人的意见等内容。正当程序原则的理论根据主要是自然公正原则。自然公正原则要求，任何权力的行使都必须公正，对涉及当事人利益的事项作出裁判要听取当事人的意见，平等地对待各方当事人，不偏袒任何一方。确立正当程序原则的法律最早源于英国，后来美国联邦宪法修正案对“正当法律程序”作出了规定：不经正当法律程序，不得剥夺任何人的生命、自由或财产。从此，奠定了正当法律程序原则在美国的宪法地位。在我国，随着全面依法治国方略的确立和实施，正当程序原则正在被广泛地应用到立法、行政、司法和监察等社会生活领域。

三、社会主义法治

►社会主义法治的含义

【分析】社会主义法治的核心内容就是要实行依法治国。依法治国，就是广大人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济文化事业，管理社会事务，保证国家各项工作都依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，是发展社会主义市场经济的客观需要，是社会文明进步的重要标志，是国家长治久安的重要保障。

►中国特色社会主义法治的发展历程

【分析】中国是一个具有五千年文明史的古国，中华法系源远流长，成为世界独树一帜的法系，为人类法制文明作出了重要贡献。鸦片战争后，为了改变国家和民族的苦难命运，一些仁人志士试图将近代西方国家的法治模式移植到中国，以实现变法图强的梦想。但由于各种历史原因，他们的努力最终归于失败。在中国共产党的领导下，中国人民经过革命、建设、改革和发展，逐步走上了建设社会主义法治国家的道路。

1949年中华人民共和国的成立，开启了中国法治建设的新纪元。当代中国法治建设的发展历程可以分为三个历史时期：第一个历史时期从1949年至1978年，为社会主义法制的初创和磨炼时期。这三十年又可以分为两个历史阶段，一是1949年至1965年的初创时期；二是1966年至1978年社会主义法制建设遭到严重破坏的时期，这个时期以“文革”的破坏法制到十一届三中全会之前“文革后遗症”为标志。第二个历史时期从1979年至1996年，是社会主义法制建设的恢复和初步发展时期。法制的初步发展以整个20世纪80年代的法制建设和20世纪90年代初社会主义市场经济体制确立和国家加强经济立法为标志。第三个历史时期从1997年至今，为依法治国方略确定直至全面推进依法治国的法治繁荣时期。

1997年召开的中国共产党第十五次全国代表大会，将“依法治国”确立为治国基本方略，将“建设社会主义法治国家”确定为社会主义现代化的重要目标，并提出了建设中国特色社会主义法律体系的重大任务。1997年和1998年，中国分别加入两个重要的国际人权公约。1999年，将“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家”载入宪法。中国的法治建设揭开了新篇章。

进入21世纪，经过多年的努力，中国终于加入世界贸易组织，中国的法治建设继续向前推进。2002年召开的中国共产党第十六次全国代表大会，将社会主义民主更加完善，社会主义法制更加完备，依法治国基本方略得到全面落实，作为全面建设小康社会的重要目标。2004年，将“国家尊重和保障人权”载入宪法。2005年至2006年，提出“社会主义法治理念”这一具有重要战略意义的法治命题并在全国广泛宣传。2007年召开的中国共产党第十七次全国代表大会，明确提出全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家，并对加强社会主义法治建设作出了部署。2008年，中国政府向世界发布《中国的法治建设》白皮书，以后每年定期发表中国法治发展报告。在此前后，具有标志性意义的《物权法》和《侵权责任法》相继出台，意味着我国民事领域基本法全部完成，为中国特色社会主义法律体系的形成提供了重要的支撑。2011年，时任全国人大常委会委员长吴邦国宣布：中国特色社会主义法律体系已经形成。

2012年中国共产党第十八次全国代表大会召开，进一步作出推进依法治国的战略部署。2013年党的十八届三中全会将“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标。2014年，载入中国法治史册的党的十八届四中全会召开，大会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》（本章以下简称《决定》）。这是建党90多年来全会第一次以“依法治国”为主题作出的重大战略部署。《决定》提出了“建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家”的总目标。《决定》还提出了全面推进依法治国应坚持的五大基本原则与七大根本任务，提出的重大法治改革举措有180多项，其核心是“良法善治”。

2017年，中国共产党第十九次全国代表大会再次肯定了全面依法治国的总目标，并提出了全面深化依法治国。2019年，党的十九届四中全会通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，专门提出“坚持和完善中国特色社会主义法治体系，提高党依法治国、依法执政能力”。继我国《宪法》第五次修正案通过后，全国人民代表大会分别于2018年通过《监察法》，2020年通过《民法典》。这些重要法律的出台，对于完善我国法治体系，促进国家治理体系与治理能力现代化具有重大而深远的意义。

2020年以来，在习近平法治思想引领下，中央出台了系列关于法治中国、法治政府与法治社会建设的重要

文件，简称“一规划两纲要”，即《法治中国建设规划(2020—2025年)》《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》《法治社会建设实施纲要(2020—2025年)》。“一规划两纲要”共同构建起新时代中国特色社会主义法治建设的顶层设计，是“十四五”时期统筹推进我国法治建设的总蓝图、路线图、施工图。2022年10月召开的党的二十大标志着全面依法治国进入新的历史节点。党的二十大报告首次单独将“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”列为专章，并提出了“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”的时代新命题。

►法治思维与法治方式

【分析】我们讲的法治是社会主义法治，而“法治思维”是指按照社会主义法治的逻辑来观察、分析和解决社会问题的思维方式，它是将法律规定、法律知识、法治理念付诸实施的认识过程。

法治思维要求将法律作为判断是非和处理事务的准绳，要求崇尚法治、尊重法律，善于运用法律手段解决问题和推进工作。运用法治思维解决问题，要求国家工作人员，特别是领导干部，在行使国家公权力时，无论是决策，还是执行，都应始终关注至少以下五个方面的内容，即目的是否合法、权限是否合法、内容是否合法、手段是否合法以及程序是否合法。此外，法治思维还可以从以下方面进行理解：

第一，法治思维是规则思维。法律实际上是一种规则。法律规则具有明确性、稳定性和可预测性，可以为人们提供基本的行为准绳。有了它，人们对于自己乃至他人的行为及其法律后果就有了稳定的预期，便会依此对自己的行为进行调整和规范。规则思维要求制定良好的法律，并贯彻它、遵守它。

第二，法治思维是平等思维。法律的一个重要价值取向是平等，即权利平等、机会平等、规则平等。平等思维要求每一个人都抛弃特权思想，自觉将自己置于法律的监督和制约之下。法律的制定需要贯彻平等原则，不允许个别人或个别集团将自己的特权法制化；法律的实施更要落实平等原则，任何人不得凌驾于法律之上，不得有法外特权。

第三，法治思维是权力受制约思维。权力受制约思维要求制定科学的制度机制，使权力得到制约，使权力行使具有明确边界。依据法治思维，权力体制与机制必须保证权力在相互制约的前提下相互配合。因此，应逐条梳理权力事项，进一步强化对公权力的监督制约，努力形成科学有效的权力运行机制，促使手中握有公权力的人慎重对待权力行使的边界，把自己置于监督约束之下。

第四，法治思维是程序思维。程序正义是实体正义的重要保证。程序思维要求分析问题特别是处理问题按照法定程序进行。必须遵循规律，为公权力的行使设立科学、合理的程序，并确立违反程序的制裁性后果，从而防止破坏法定程序的行为。

法治方式与法治思维是外在和内在的关系，法治方式就是法治思维实际作用于人的行为的外在表现。法治思维影响和决定着法治方式。法治方式广义上包括立法、执法、司法、守法与监督等多种法律手段与方式。要提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，努力推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境，在法治轨道上推动各项工作。这标志着我们党对执政规律的认识、对法治的认识、对领导干部素质和能力建设认识都提到了新高度，对于建设社会主义法治强国具有重要意义。

第二节 习近平法治思想与全面依法治国

一、习近平法治思想的核心要义

►全面依法治国的政治方向；全面依法治国的重要地位；全面依法治国的工作布局；全面依法治国的重点任务；全面依法治国的重大关系；全面依法治国的重要保障

【分析】习近平法治思想是内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备的科学理论体系治国等一系列重大问

题，指明了全面依法治国的政治方向、重要地位、工作布局、重点任务、重大关系、重要保障。习近平法治思想的主要内容和理论精髓，集中体现为习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上提出的“十一个坚持”和相关重要论述，从理论逻辑上可以划分为以下几个方面。

全面依法治国的政治方向。全面依法治国的政治方向决定法治建设的成败得失，它集中体现在全面依法治国由谁领导、为了谁、依靠谁、走什么路等问题上，习近平法治思想科学回答了这些根本性问题，为我们提高法治领域的政治判断力、政治领悟力和政治执行力提供了科学指导。第一，“坚持党对全面依法治国的领导”，自觉地把党的领导贯彻到依法治国全过程和各方面，更好落实全面依法治国基本方略。第二，“以人民为中心”是社会主义法治的核心价值，全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，必须坚持为了人民、依靠人民，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感、公平感。第三，“中国特色社会主义法治道路”是社会主义法治建设成就和经验的集中体现，是建设社会主义法治国家的唯一正确道路，在法治建设实践中自觉坚持党的领导、坚持中国特色社会主义制度、贯彻中国特色社会主义法治理论。要从中国国情和实际出发，走适合自己的法治道路。

全面依法治国的重要地位。习近平法治思想从坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的长远考虑出发，科学指明了全面依法治国的战略定位。第一，全面依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中具有基础性、引领性、支撑性作用。第二，全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，要敢于啃硬骨头、涉险滩、闯难关，大刀阔斧地推进法治领域的改革，坚决破除一切妨碍依法治国、依法执政、依法行政、依法治军、依法办事的体制机制弊端和思想观念。第三，全面依法治国既是中国特色社会主义的本质要求，也是中国特色社会主义的重要保障。我们要重视法治、厉行法治，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要保障作用，有效地运用法治应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。

全面依法治国的工作布局。如何推进全面依法治国，工作布局很关键、是引领。习近平总书记从坚持和发展中国特色社会主义的总体布局 and 战略全局出发，提出“坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化”“坚持建设中国特色社会主义法治体系”“坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设”三个理论命题，科学回答了全面依法治国谋篇布局的问题，既为全面依法治国指明了总目标，又为全面依法治国推出了总抓手。

全面依法治国的重点任务。在确定全面依法治国战略和工作布局的同时，习近平总书记从全面建设社会主义现代化国家的目标要求出发，提出了当前和今后一个时期全面依法治国的重点任务。全面贯彻实施宪法是全面依法治国的首要任务，要坚持依宪治国、依宪执政，更好展现国家根本法的力量、更好发挥国家根本法的作用。科学立法、严格执法、公正司法、全民守法是全面依法治国的关键环节，要坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，继续推进法治领域改革，解决好立法、执法、司法、守法等领域的突出矛盾和问题。同时，还要坚持统筹推进国内法治和涉外法治，坚决维护国家主权、尊严和核心利益。

全面依法治国的重大关系。全面依法治国涉及一系列重大辩证关系，如何正确认识和处理这些重大辩证关系，事关法治道路、法治效能和法治成败。习近平总书记深刻分析了政治和法治、民主和专政、改革和法治、发展和安全、依法治国和以德治国、依法治国和依规治党等关系，并一一作出了科学论述，厘清了这些问题上的模糊认识和错误观点，为正确认识和处理这些关系释明了马克思主义的立场、观点和方法。

全面依法治国的重要保障。全面依法治国需要坚强有力的保障体系，包括政治保障、制度保障、思想保障、组织保障、人才保障、运行保障、科技保障等。习近平总书记深刻论述了全面依法治国的各项保障问题。其中，基于人才强国、人才强法的基本理念，强调全面依法治国必须重视法治工作队伍建设，必须抓住领导干部这个“关键少数”，重视发挥领导干部关键作用，要求各级领导干部带头尊崇法治、敬畏法律，了解法律、掌握法律，

不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，做尊法学法守法用法的模范。

二、全面依法治国

►全面依法治国的目标与原则

【分析】党的十八届四中全会首先提出全面依法治国的总目标，其内容是：建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。即在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。中共中央印发的《法治中国建设规划(2020—2025年)》，对上述目标作了进一步明确，即建设法治中国，应当实现法律规范科学完备统一，执法司法公正高效权威，权力运行得到有效制约监督，人民合法权益得到充分尊重保障，法治信仰普遍确立，法治国家、法治政府、法治社会全面建成。该文件强调，到2025年，党领导全面依法治国体制机制更加健全，以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系更加完备，职责明确、依法行政的政府治理体系日益健全，相互配合、相互制约的司法权运行机制更加科学有效，法治社会建设取得重大进展，党内法规体系更加完善，中国特色社会主义法治体系初步形成。到2035年，法治国家、法治政府、法治社会基本建成，中国特色社会主义法治体系基本形成，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，国家治理体系和治理能力现代化基本实现。

实现这个总目标，必须坚持以下基本原则：第一，坚持中国共产党的领导。把党的领导贯彻到依法治国的全过程和各方面，是我国社会主义法治建设的一条基本经验。必须坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，把依法治国基本方略同依法执政基本方式统一起来，把党总揽全局、协调各方同人大、政府、监察机关、审判机关、检察机关依法履行职能统一起来，把党领导人民制定和实施宪法法律同党坚持在宪法法律范围内活动统一起来。第二，坚持人民主体地位。人民是依法治国的主体和力量源泉，人民代表大会制度是保证人民当家作主的根本政治制度。必须坚持法治建设为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民，以保障人民根本权益为出发点和落脚点，保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务，维护社会公平正义，促进共同富裕。第三，坚持法律面前人人平等。平等是社会主义法律的基本属性。任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威，都必须在宪法法律范围内活动，都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务，都不得有超越宪法法律的特权。第四，坚持依法治国和以德治国相结合。必须坚持一手抓法治、一手抓德治，既重视发挥法律的规范作用，又重视发挥道德的教化作用，以法治体现道德理念、强化法律对道德建设的促进作用，以道德滋养法治精神、强化道德对法治文化的支撑作用，实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。第五，坚持从中国实际出发。必须从我国基本国情出发，同改革开放不断深化相适应，总结和运用党领导人民实行法治的成功经验，围绕社会主义法治建设重大理论和实践问题，推进法治理论创新。汲取中华法律文化精华，借鉴国外法治有益经验，但绝不照搬外国法治理念和模式。

►全面依法治国的基本格局

【分析】坚持中国特色社会主义法治道路，既要建成一套高效严密、统一协调的法治体系，更要以此为前提，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化，建成社会主义法治国家。

科学立法是法治的前提。科学立法，一要尊重客观规律。不仅要按照客观经济规律尤其是市场经济的价值规律、市场和自由关系的内在规定性等来及时地进行法律的废、改、立，而且要充分反映社会规律，将社会文化

以及民主政治建设和生态文明发展规律及时用法律的形式加以固定和强化。**二要体现民意。**立法应当回应人民群众的真实关切和心愿，而不是部门利益至上、利用立法搞地方保护主义。人民性是法律的最根本特征，也是衡量法律质量的根本标准。凡是人民群众呼声高、要求强的，就应当及时进行立法；凡是与人民利益和意志不相符或根本相背离的，必须及时进行废、改。**三要切合实际。**立法必须立足现实，以解决现实问题和现实利益诉求为导向，既要有预见性和超前性，又要增强针对性和务实性。**四要完善程序。**民主立法是科学立法的保障，科学民主的立法程序是良法产生的基本途径，拓宽立法渠道、加强开门立法，为科学立法奠定基础。**五要符合科学。**立法应当按照科学的法治原理和原则加以完善，既要将人类法治发展史上凝聚的宝贵法治遗产，如罪刑法定、无罪推定和非法证据排除等吸纳到立法之中，又要增强可操作性和逻辑性，明确具体的适用条件、行为模式和法律后果，克服权利义务关系不明、责任抽象的局限性。

严格执法是对行政机关的正当要求，是指行政机关应当严格、严明和严肃地执行国家法律。所谓**严格**是指**行政机关及其工作人员**严守法定的实质标准和程序要求，坚持在法律的轨道内按照法律的标准行使行政权力、执行法律法规；所谓**严明**是指**执法作风端正、执法纪律严明**，坚决消除“慵、懒、散”，杜绝乱作为、瞎折腾；所谓**严肃**是对**执法态度、执法精神**方面的要求，执法者应当奉行法治精神、严肃认真地履行执法职责，确保公正执法、文明执法、理性执法。此外，**应当依法惩处各类违法行为，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度。**完善执法程序，建立执法全过程记录制度。明确具体操作流程，重点规范行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查等执法行为。严格执行重大执法决定法制审核制度。

公正司法是对司法机关的基本要求。司法是正义的最后防线，也是法治的生命线。司法不公，则权利受损；司法不公，则社会不稳；司法不公，则法治不存。**司法不公的深层次原因在于司法体制不完善、司法职权配置和权力运行机制不科学、人权司法保障制度不健全。**所以，必须完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

全民守法是**法治建设的基础工程**，法治根系于社会大众对法律的信守和遵从。全民守法是指**全体社会成员和一切国家机关、政党、社会团体、企事业单位，都必须尊重宪法法律权威，都必须在宪法法律范围内活动，都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务，都不得有超越宪法法律的特权。**正如卢梭所言：“一切法律之中最重要的法律，既不是铭刻在大理石上，也不是刻在铜表上，而是铭刻在公民的内心里。”为此，必须维护国家法制统一、尊严、权威，切实保证宪法法律有效实施，绝不允许任何人以任何借口任何形式以言代法、以权压法、徇私枉法。**必须深入开展法治宣传教育，大力弘扬社会主义法治精神，努力建设社会主义法治文化，增强全社会厉行法治的积极性和主动性；必须依法抑恶扬善，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围；必须发挥法治建设的强大效能，引导人民群众按照法律的规定和程序，依法表达利益诉求、依法维护自身权益；必须完善国家工作人员学法用法制度，坚持把领导干部带头学法、模范守法作为树立法治意识的关键，充分发挥领导干部率先垂范的带动效应，使全体人民都成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。**

此外，还应注重**人才强法**，加强法治队伍建设和法治人才培养。从法律大国向法治大国和法治强国的发展是治国强国的强大保障，而**法治人才则是其中的主体性力量。**法治与人治相对，但法治社会绝不是要否定人的作用，相反，人的素养和主观能动性对法治的成败意义重大。**无论是法律的制定，还是法律的实施，抑或法律的监督，都需要高素质的法治人员。**《决定》指出：“全面推进依法治国，**必须大力提高法治工作队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准，着力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的社会主义法治工作队伍，为加快建设社会主义法治国家提供强有力的组织和人才保障。**”

►全面依法治国的基本途径

【分析】**依法治国**是党和人民治国理政的根本方略，是**以法律至上为核心、以权力制约为机制、以人权保障为目标的治理模式。**社会主义法治国家所要推进的依法治国，如前所述，其主体是广大人民群众。

依法执政是中国共产党的执政方式在新时期的重要转变，是指党依据宪法和法律以及党内法规体系治国理政和管党治党，实现党和国家政治生活的法律化、制度化、规范化。全面推进依法治国、建设社会主义法治国家，关键在于执政党依法民主科学执政。依法执政的基本内容：一是党领导立法，保证党的主张和意志通过法定程序上升为国家意志；二是依照宪法和法律，党领导国家政权，运用国家政权，实现党的宗旨、目标和任务；三是保证和支持行政机关依法严格执法、司法机关公正司法，确保民主的法律化、制度化；四是带头遵守宪法法律，自觉维护宪法法律权威；五是通过依法执政的体制机制改革，自觉提升运用法治思维和法治方式执政的意识和能力；六是依法保障和规范党的机关和党员干部执掌和运用权力的行为，反对以言代法、以权压法、徇私枉法。

依法行政是指各级政府在党的领导下，依法行使行政管理权和依法执行法律。无论是哪一层级的政府及其部门，其权力的设定、取得、运行和监督都必须依法进行，确保始终不偏离法治的轨道。其基本要求是，以合法性原则为基本指导，坚持法定职责必须为、法无授权不可为、违法行为必追究。为此，应当改革行政执法体制，推进综合执法、严格执法责任，构建权责统一、权威高效、程序严谨的依法行政体制，切实防止选择性执法、多头执法、违法执法，牢固树立权力来源于人民、权力依法授予、权力为了人民并受人民监督的法治观念。

依法治国、依法执政和依法行政是相互联系、相辅相成的关系，具有价值取向的一致性、基本要求的统一性、运行机制的关联性。依法治国是全局、依法执政是核心、依法行政是关键，三者缺一不可、不可偏废，应当通盘谋划、共同推进。

法治国家是全面依法治国的根本目标。法治国家是指依法赋予、运行和制约国家权力、通过公正司法和严格执法来维护法律权威并实现人民权利的国家存在形式。其含义包括：其一，法律之治。国家的政治、经济、社会、文化所涉及的一切国家权力形式之间及其与公民权利之间的关系，均被纳入法律调控的范围，接受法律的治理。其二，权力制约。国家权力不是无限的，更不可主观任性地运行。相反，应当是有限的、分立的、受法律监督制约的。其三，注重程序。无论是司法过程、执法行为，还是政治决策与民主政治活动，都应该有一整套程序规范引导，并固化为法律程序，获得全体组织和所有人的一体遵循。程序是法治国家不同于人治国家的重要分水岭。其四，法律权威。法律与人尤其是领导者个人的权威比较是否具有至上性是人治与法治的最根本区别。当法律权威高于领导者个人的权威时，便是法治，反之，便只会是人治国家。其五，人权保障。坚持人民主体地位，以人民的基本权利和利益为最高价值追求，是法治国家的生命力之所在。其六，良法善治。不仅要有完备的法律体系，更需要抛弃恶法、弘扬良法，用文明进步的良善价值来主导和统率法律规范；不仅要依法治理，更要构建法治先行、透明公开、公平正义、以人为本、高效理性、权责统一的现代治理体系。

法治政府是政府依据宪法法律设立、政府权力法定、政府决策和行为严格依据法律程序进行并对其后果承担相应责任的政府。其一，政府依法行政和严格执法，是法治的重心。政府的决策与执法活动是否符合法治精神和法治原则，不仅关系到法治国家能否建成，更关系到社会的稳定和人民的幸福。因此，必须牢牢抓住这个关键，在规范政府权力的行使、防止权力滥用、明确权力价值取向上作出全面的法治制度安排，并确保在法治实践中得到有效落实。其二，法治政府是有限政府，其权力受到法律的界分和限定，不能超越法律的界限运行。其三，法治政府是责任政府，有权必有责，有责必承担；法治政府是人民政府，以人的基本自由和权利为依归。其四，法治政府是程序政府，一切重大决策和行动都必须通过公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定；法治政府是阳光政府，实行信息公开，赋予社会大众广泛的知情权和参与权，以民主决策和民主监督来实现公开公正、保障政府的法治本色。其五，法治政府是诚信政府，应当自觉维护法律权威、自觉履行职责，为政令畅通、政民和谐奠定基础。按照中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》的精神，我们要加快构建职责明确、依法行政的政府治理体系，全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴

复兴的中国梦提供有力法治保障。

法治社会是社会依法治理、社会成员人人崇尚法治和信仰法治、社会组织依法自治、社会秩序在法治下和谐稳定的社会。没有法治社会，便没有法治国家。依据中共中央发布的《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》，法治社会建设应遵循以下原则：坚持党的集中统一领导；坚持以中国特色社会主义法治理论为指导；坚持以人民为中心；坚持尊重和维护宪法法律权威；坚持法律面前人人平等；坚持权利与义务相统一；坚持法治、德治、自治相结合；坚持社会治理共建共治共享。法治社会建设具体包括：第一，全社会树立法治意识。法律的权威来自人民的内心拥护和真诚信仰。通过法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神、建设社会主义法治文化，使全体人民自觉依法行使权利、履行义务、承担社会和家庭责任。第二，社会组织多层次多领域依法治理。坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，提高社会治理法治化水平，支持各类社会主体自我约束、自我管理。第三，党和国家依据宪法法律治理社会。法治社会建设还要求，建设完备的法律服务体系。推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，加强民生领域法律服务；完善法律援助制度；健全依法维权和化解纠纷机制。强化法律在维护群众权益、化解社会矛盾中的权威地位，引导和支持人们理性表达诉求、依法维护权益，解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。总之，法治国家、法治政府和法治社会三者内在统一、相互融合、相互促进，共同成长为社会主义法治国家。

►建设中国特色社会主义法治体系

【分析】中国特色社会主义法治体系是全面推进依法治国总目标的内容之一，有其形式标准与内容。

第一，建设完备的法律规范体系，以良法促进发展、保障善治。为此必须做到：健全宪法实施和监督制度；完善我国的立法体制；深入推进科学立法、民主立法；并加强重点领域立法，进一步形成完善的、科学规范的中国特色社会主义法律规范体系。

第二，建设高效的法治实施体系，深入推进严格执法、公正司法、全民守法。在行政执法领域必须做到：依法全面履行政府职能；健全依法决策机制（包括公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定）；深化行政执法体制改革；坚持严格规范公正文明执法；全面推进政务公开（坚持以公开为常态、不公开为例外原则，推进决策公开、执行公开）。公正是法治的生命线，实现公正司法必须做到：完善确保依法独立公正行使审判权和检察权的制度；优化司法职权配置（让公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关各司其职）；推进严格司法（坚持以事实为根据、以法律为准绳）；保障人民群众参与司法；加强人权司法保障；加强对司法活动的监督。进一步保障全民守法的落实。

第三，建设严密的法治监督体系，切实加强对立法、执法、司法工作的监督。特别是要强化对行政权力的制约和监督，通过加强党内监督、人大监督、民主监督、监察监督、司法监督、审计监督、社会监督、舆论监督制度的建设，努力形成科学有效的权力运行制约和监督体系，增强监督合力和实效。同时，加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。要完善政府内部监督机制，建立常态化监督制度。完善纠错问责机制，健全责令公开道歉、停职检查、引咎辞职、责令辞职、罢免等问责方式和程序。逐步完善监察体制机制，完善监督主体、范围、程序与责任，有效发挥监察机关对权力运行的监督作用。

第四，建设有力的法治保障体系，筑牢法治中国建设的坚实后盾。这方面主要应当强化两大保障体系，一是加强法治工作队伍建设，二是加强和改进党对全面推进依法治国的领导。在加强法治工作队伍建设方面，主要包括：建设高素质法治专门队伍；加强法律服务队伍建设，特别是加强律师队伍思想、政治与组织建设；创新法治人才培养机制。在加强和改进党对全面推进依法治国的领导方面，必须加强和改进党对法治工作的领导，把党的领导贯彻到全面推进依法治国全过程。强化依法执政的法治意识，让各级党组织和领导干部深刻认识到依法执政是依法治国的关键。将进一步完善党内法规、从严管党、从严治党上升到法治国家建设保障体系的高度。

第五，建设完善的党内法规体系，坚定不移推进依规治党。这是党中央针对全面从严治党的新战略提出的全新主张，也是依法治国与依规治党相结合的具体体现。党的十八大以来，中央出台了一系列准则、条例和规则，包括修改党章，还出台了《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党问责条例》《中国共产党地方委员会工作条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《干部教育培训工作条例》等。截至2024年3月（2023年6月），全党现行有效党内法规共3890（3802）部。其中，包括党中央制定的中央党内法规221（200余）部，中央纪律检查委员会以及党中央工作机关（有关部门）制定的部委党内法规近202（200）部，省、自治区、直辖市党委制定的地方党内法规3467（3400余）部。这些为从严治党提供了规则基础。

►在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家

【分析】中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。中国式现代化必须走中国特色社会主义法治道路，全面建设社会主义现代化国家必须坚持全面依法治国。

全面依法治国是我国社会主义建设伟大实践的基本经验，是全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是提高党治国理政水平的重要途径。为此，必须坚持在党的领导下谋划推进法治建设，紧扣全面建设社会主义现代化国家谋划推进法治建设，围绕保障和促进社会公平正义谋划推进法治建设，坚持以系统观念谋划推进法治建设。中国特色社会主义实践每向前推进一步，社会主义法治国家建设就要跟进一步。新征程上，谋划和推进全面建设社会主义现代化国家，要把法治摆在更加突出的位置，以国家各项工作法治化水平不断提高推动经济社会持续健康发展。

第十三章 法与社会

第一节 法与社会的一般关系

一、法与社会的相互作用

►社会是法律的基础；法律是社会关系的调整器

【分析】第一，社会是法律产生与形成的基础。

法是社会的产物。**社会性质决定法律性质，社会物质生活条件最终决定着法律的本质**。不同的社会就产生不同的法律。即使是同一性质或历史形态的社会，在其不同的发展阶段上，法律的内容、特点和表现形式也往往不尽相同。

社会是法的基础，即社会是法赖以产生或形成的基础。如果相反，以法律为社会的基础，那么，实质上就可能强迫社会接受那些已经被这一社会生活条件及物质生产本身宜判无效的法律，把法律看成了永恒不变的东西。新的法律不可能产生于旧的社会基础之上，旧的法律也不可能长期在新的社会基础上生存和延续。马克思说，社会不是以法律为基础的。那是法学家的幻想。相反地，法律应该以社会为基础。法律应该是社会共同的、由一定的物质生产方式所产生的利益和需要的表现，而不是单个人的恣意横行。法的社会基础的另外一层含义，就是制定、认可法律的国家以社会为基础，国家权力以社会力量为基础；同时还可以说，国家法以社会法为基础，“纸上的法”以“活法”为基础。总之，法以社会为基础，不仅指法律的性质与功能决定于社会，而且还指法律变迁与社会发展的进程基本一致。

第二，法律是社会关系的调整器。

首先，法对社会的调整，是通过调和社会各种冲突的利益，进而保证社会秩序得以确立和维护。在历史发展过程中，对社会的调整手段主要有三种，即法律、道德和宗教。近代以来，法律已成为对社会进行调整的首要工具。所有其他的社会调整手段必须从属于法律调整手段或者与之相配合，并在法律确定的范围内行使。其次，法对社会的调整还表现为通过法律对社会机体的疾病进行治疗。具体而言，就是运用法律解决经济、政治、文化、科技、道德、宗教等方面的各种社会问题，由此实现法的价值，发挥法的功能。

当然，法律不是万能的。首先，在某些社会关系领域，法律的控制不是唯一的手段，或者说不是最佳的手段。如果强行以法律进行控制，就可能导致社会成本过大，得不偿失，甚至造成法律的暴政。历史上不乏此类教训。如“秦法繁于秋荼，而密于凝脂”，结果招致天下仇怨。其次，我们还应当看到“徒善不足以为政，徒法不能以自行”。（删除《孟子·离娄上》）当然，一个社会的不同地区、不同阶层的人对不同的法律认知程度及使用能力参差不齐，必定会使法律在不同地区、不同阶层中有着不同的实施效果。所以，普及法律知识，提高全民法律意识，其意义绝不仅仅在于号召民众守法，更重要的还在于教育民众“用法”。只有人人都善于使用法律，法律的作用才能得以充分发挥。

二、法与社会治理

► 社会治理的内涵

【分析】社会治理是指政府、社会组织、企事业单位、社区以及个人等多种主体通过平等的合作、对话、协商、沟通等方式，依法对社会事务、社会组织和社会生活进行引导和规范，最终实现社会公共利益最大化的过程。

当代中国的社会治理，是指在党的领导下，由政府主导，吸纳社会组织等多方面治理主体参与对社会公共事务依法治理的活动；以实现和维护人民利益为核心，发挥多元治理主体的作用，针对国家治理中的社会问题，完善社会福利、保障改善民生，运用法治思维与法治方式化解社会矛盾，促进社会公平，推动社会有序发展的过程。因此，社会治理也被认为是新时代确立的一种以人民为中心的科学的法治化多元治理方式。

► 当代中国社会主义法在社会治理中的作用

【分析】中国社会主义法在社会治理中有着不可替代的地位。

第一，从经济与社会发展的角度看，社会主义法是解决社会复杂矛盾、维护社会稳定的利器。经济不断发展，会导致贫富差距加大等一系列社会问题，导致各种利益关系矛盾凸显，要化解这些矛盾，最好的解决方式就是将这些问题纳入法治轨道。

第二，从政治运行角度看，社会主义法是政治权力认可并制定的行为规则。社会主义法治是党通过领导国家的立法、司法、行政机关，制定、贯彻、落实良法，将人民的意志集合为国家意志，并运用国家的强制力加以实施。党的领导是社会主义法治的一个突出特点。

第三，从社会治理和法治本质看，以人民为中心是社会主义法治的本质要求。社会主义法以维护广大人民群众根本利益为根本目标。法治作为一种社会治理形式，其最根本的目的就是使人民的利益得到实现。

第四，从价值追求看，社会主义法坚定不移地追求社会公平正义。公平正义是社会主义法治的价值追求。实现公平正义，首先要从程序正义来实现，也就是司法过程的公正，它是从立法公正通往现实公正的路径。

第五，从公众参与看，社会主义法广泛引导社会参与。要适应全面深化改革的新形势、新任务、新要求，规范政府的社会管理权力，提升社会组织、社区居民参与社会治理的地位、权利，完善其法定程序，实现政府社会治理权责体系的明晰化、科学化和法治化

总之，依法治国作为治国理政的基本方式，在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基础性地位和作用。在社会治理过程中，通过推进国家与社会治理法治化，让发展成果更多更公平地惠及全体人民，使法治现

代化成为全面实现建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的根本保障

►依法治理网络空间

【分析】依法治理网络空间，是指社会治理依法向网络空间覆盖，建立健全网络综合治理体系，加强依法管网、依法办网、依法上网，全面推进网络空间治理法治化，实现网络空间内秩序与自由的有机统一。依法治理网络空间主要包括以下措施：

第一，完善网络法律制度。通过立改废释并举等方式，推动现有法律法规延伸适用到网络空间。完善网络信息服务方面的法律法规，修订互联网信息服务管理办法，研究制定互联网信息服务严重失信主体信用信息管理办法。完善网络安全法配套规定和标准体系，建立健全关键信息基础设施安全保护、数据安全管理和网络安全审查等网络安全管理制度。修订预防未成年人犯罪法，制定未成年人网络保护条例。

第二，培育良好的网络法治意识。坚持依法治网和以德润网相结合，弘扬时代主旋律和社会正能量。加强和创新互联网内容建设，实施社会主义核心价值观、中华文化新媒体传播等工程。加强全社会网络法治和网络素养教育，制定网络素养教育指南，引导网民文明上网、理性表达。

第三，保障公民依法安全上网。牢固树立正确的网络安全观，依法防范网络安全风险。落实网络安全责任制，明确管理部门和网信企业的网络安全责任。同时，加强对网络空间通信秘密、商业秘密、个人隐私以及名誉权、财产权等合法权益的保护。建立健全信息共享机制，积极参与国际打击互联网违法犯罪活动。

►通过法律实现“共建共治共享”的社会治理新理念

【分析】通过法律实现“共建共治共享”的社会治理新理念，核心是推进社会治理法治化，全面提升社会治理法治化水平，依法维护社会秩序、解决社会问题、协调利益关系、推动社会事业发展，培育全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，促进社会充满活力又和谐有序。它主要包括以下几个方面的内容：

第一，完善社会治理体制机制。完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，打造共建共治共享的社会治理格局。健全地方党委在本地区发挥总揽全局、协调各方领导作用的机制，完善政府社会治理考核问责机制。引领和推动社会力量参与社会治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保社会治理过程人民参与、成效人民评判、成果人民共享。加强社会治理制度建设，推进社会治理制度化、规范化、程序化。

第二，推进多层次多领域依法治理。推进市域治理创新，依法加快市级层面实名登记、社会信用管理、产权保护等配套制度建设，开展市域社会治理现代化试点，使法治成为市域经济社会发展的核心竞争力。深化城乡社区依法治理，在党组织领导下实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。区县职能部门、乡镇政府(街道办事处)按照减负赋能原则，制定和落实在社区治理方面的权责清单。加强基层群众性自治组织规范化建设。全面推进基层单位依法治理，企业、学校等基层单位普遍完善业务和管理活动各项规章制度。广泛开展行业依法治理，推进法治化治理方式。依法妥善处置涉及民族、宗教等因素的社会问题，促进民族关系、宗教关系和谐。

第三，发挥人民团体和社会组织在法治社会建设中的作用。人民团体要在党的领导下，通过各种途径和形式依法参与管理国家事务，管理经济文化事业，管理社会事务。促进社会组织健康有序发展，推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用。加大培育社会组织力度，重点培育、优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织。推动和支持志愿服务组织发展，开展志愿服务标准化建设。完善政府购买公共服务机制，促进社会组织在提供公共服务中发挥更大作用，等等。

第四，增强社会安全感。加快对社会安全体系的整体设计和战略规划，贯彻落实加快推进社会治理现代化开创平安中国建设新局面的意见。完善平安中国建设协调机制、责任分担机制，健全平安建设指标体系和考核

标准。

第五，（删除：推进诉源治理，）依法有效化解社会矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，努力将矛盾纠纷化解在基层。全面落实诉讼与信访分离制度，深入推进依法分类处理信访诉求。充分发挥人民调解的第一道防线作用，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。充分发挥律师在调解中的作用，建立健全律师调解经费保障机制。

第二节 法与经济

一、法与经济基础

►经济基础决定法，法反作用于经济基础

【分析】法律是上层建筑的组成部分，它与经济基础之间的关系是形式与内容的关系。一方面，法律只能在经济基础所蕴含的可能性范围内选择，而不能任意地选择；法律的性质、内容和发展趋势等，都主要是由其赖以建立的经济基础的状况和要求所决定的。另一方面，法律虽然根源于经济基础，但作为一种超经济的力量，对经济基础既具有依赖性，又具有一定的反作用和相对独立性。

法律与经济基础的关系主要表现为经济基础对法律的决定作用，主要体现为三个方面：首先，经济基础决定法律的性质；其次，经济基础决定法律的基本内容；最后，经济基础的发展变化决定法律的发展变化。但在法律与经济基础的关系中，法律也并不是消极地被决定的。法律是在归根结底决定于一定的经济基础的同时，又服务于该经济基础，对经济基础具有能动的反作用。法律对经济基础的反作用包括下列四个方面：第一，法律对经济基础具有选择和确认作用；第二，法律对经济基础具有加速或延缓其发展的作用；第三，法律对经济基础具有保障和促进作用；第四，法律对生产关系的某些方面具有否定、阻碍或限制作用。

二、法与市场经济

►法与社会主义市场经济的关系

【分析】与其他现代市场经济一样，社会主义市场经济也与法有着密切的联系。法律对社会主义市场经济的作用主要表现在：第一，社会主义市场经济是**主体独立**的经济，市场主体的行为需要法律来规范，市场主体的地位需要法律来确认和保障；第二，市场经济关系是**契约关系**，现代市场经济运行过程中的各种活动，几乎都是通过契约来实现的，契约关系是一种法的关系，具有法律约束力，也需要法律来确认和保障；第三，市场经济是**自由竞争、平等竞争**的经济，法律就是竞争的规则，为市场主体的平等竞争提供公平的执法司法保障；第四，市场经济的运行需要有**正常的秩序**，需要有正常的市场进入、市场交易秩序，这些都离不开法律的作用；第五，市场经济还是**开放性经济**，要求主权国家不仅要完善国内法律体系，而且要善于运用国际法律、规则和惯例等。另外，法律在社会主义市场经济**宏观调控**方面还发挥着重要作用，主要表现为对市场经济运行的引导、促进、保障和必要的制约。

三、法与科技

►法与科技的关系：科技对法的影响；法对科技的作用

【分析】现代社会是科技社会，科技产品也越来越成为满足我们需要的各种工具，我们的生活几乎已经被科技完全包围。人类已经从发展科技、利用科技，转变成为受科技影响，被科技所控制。互联网、大数据与人工智能等新科技的面世，也将深刻影响法律的发展。法律当然也不可能对这种强势力量毫无回应。法与科技

术的关系，大致可以从两个方面来解释。

一是科技对法的影响：首先，科学技术影响法的内容，成为法律规定的重要依据。科学技术进步所形成的新的科学知识，不断被运用到法律领域，成为法律规定的重要的科学依据。其次，科学技术的发展扩展了法律调整的领域。在科学技术的研究发明和推广应用的实践活动中出现的大量新的社会关系需要法律规范的调整。再次，科学技术的发展引起了有关的传统法律概念和原则的变化。随着科技的发展，科学技术知识内容的立法所占的比重不断增加，而这类专业性、技术性比较强的立法任务要求立法者具备一定的专门性的科学文化知识，需要将这类立法工作委托给专门的机关或人员，这导致“委任立法”范围的不断扩大。最后，科学技术的发展完善了法律调整机制，为立法和执法提供了新的技术和手段，对法的制定和实施产生重大影响，如互联网法院的设立、人工智能在法的制定与实施中的运用等。此外，科学技术的发展也影响了法学教育、法制宣传和法学研究的方式和内容，促进其方式和内容的更新和发展。

二是法对科技的作用：首先，法保证科学技术的顺利发展有良好的社会环境。其次，法为组织科学技术活动提供必要的准则。法确认和保证科学技术发展在国家社会生活中的优先地位，确定国家科技发展战略，确立科技管理体制和科技运行机制。法在推动国际科学技术合作，促进科学技术成果的全球共享和高效能运用方面也有重要作用。最后，法是鼓励科学技术发展的有效手段。法通过规定对公民的创造性劳动的保护和鼓励措施，如授予职称、荣誉称号和物质奖励等，激发人们为科技发展作出贡献的热情。

当然，科学技术本身具有两面性，法律也要防范其负面作用，如通过确立一些重要的科技伦理原则来规范科技行为。

第三节 法与政治

一、法与国家的关系

►国家是法律存在的政治基础

【分析1 国家权力是法的支持和保障，这主要表现在以下方面：第一，国家是法的产生和发展直接的推动力之一。从历史发展的观点看，国家政权的建立是一个国家的法得以产生的政治前提；政权的稳固是法的发展的基本条件之一；政权职能和发展也推动了法的内容和作用的变化。第二，国家权力是创制法的直接力量。国家权力是创制法的直接主体，借助于国家权力，立法能够最大限度地表达社会关系所决定的利益和意志。第三，国家权力以其强制力参与和保障法的实现。在现代社会，法的实施和实现除了依靠传统、习惯、舆论、利益引导等积极因素外，也必须依靠国家权力的支持。

►法律对国家权力的支持和制约作用

【分析】法律不是完全依附于国家，而是具有相对于国家权力的独立性的。这使得它能够对国家权力的运行及其结果产生重大的影响。法本身的相对独立性和法的调整能力使得法有可能，也必须把国家权力纳入法律调整，但这并不是说法律可以脱离国家权力而存在。

具体而言，法对国家权力的支持和制约作用表现在：第一，法确认国家权力的合法性。国家权力需要借助合法性信念来巩固自身，而法律是确立现代国家权力合法性的最重要的方式之一。第二，通过法来组织和完善国家权力机构体系。这就是说，以法律来规定国家机构的权限和职责范围，保障各个机构各司其职、各安其位。第三，通过法律制约和监督国家权力的运行。法律作为一种有效的约束手段，可以把国家权力分散到不同部门、不同层次的机关，使得权力之间可以相互制约；同时又可把国家权力的各部分整合为统一的等级体系，使得权力之间通过相互配合而发挥更大的作用。第四，法有助于提高国家权力运行的效率。法为国家权力的行使规定了方向、原则和界限等，以此促进国家权力行使的合理化。这种合理化就意味着其运行效率的提高。法还可通

过传播一定的价值观来发挥其思想教育作用，为提高国家权力的运行效率、完成其功能提供良好的社会氛围。

二、法与政治的关系

►政治对法的影响和制约作用；法对政治的确认、调整和影响作用

【分析】法与政治都属于上层建筑，都受一定的经济关系制约并反作用于一定的经济关系。但二者仍有不同：(1)政治通过把利益关系集中、上升为政治关系来反映经济关系，法以规则、程序和技术形式使经济关系制度化。(2)政治突出体现社会生活的组织性，法突出体现社会生活的规则性和秩序性。(3)政治的控制和调整功能通过政治行为和过程实现，法通过对主体权利义务的确认和保障实现对社会的控制和调整。

法与政治的相互作用体现在如下方面：

一是政治对法的影响和制约作用。一般认为，由于政治在上层建筑中居主导地位，因而总体上法的产生和实现往往与一定的政治活动相关，反映和服务于一定的政治，政治活动和政治关系的发展变化必然在一定程度或意义上影响法律的内容或价值追求的发展变化。

二是法对政治的确认和调整作用。法作为上层建筑相对独立的部分，对政治并非无所作为。特别是在近现代，可以说，法在多大程度上离不开政治，政治也便在多大程度上离不开法，法对政治具有确认、调整和影响作用。具体表现为：(1)法与政治体制。政治体制指政治权力的结构形式和运行方式。在集权型权力结构中，法的被需要还只是作为人治这种权力运行方式的点缀或辅助，而在分权型权力结构中，权力的配置和行使都须以法为依据。(2)法与政治功能。政治的基本功能是把不同的利益交融和冲突集中上升为政治关系，对社会资源进行权威性分配和整合。法不仅贯穿经济关系反映和凝聚为政治关系的过程，且将利益和各种社会资源的权威性分配以规范、程序和技术性形式固定下来，使之具有形式上共同认同的性质，并因此具有形式上的正统性。(3)法与政治角色的行为。法对于国家机构、政治组织、利益集团等政治角色行为和活动的程序性和规范性控制，以及 20 世纪初期开始的政党法治化趋势，都表明了法对重要政治角色行为控制、调整的必然性和必要性。(4)法与政治运行和发展。政治运行的规范化，政治发展中政治生活的民主化(如政治过程的透明、公民政治参与的途径等)和政治体系的完善化，离开法的运作都无从谈起。

三、法与政策的关系

►政策对法的实施的指导作用，法对政策实施的保障作用

【分析】政策通常是指一定政党或其他政治组织为达到一定时期的政治目标，处理国家事务、社会公共事务而提出并贯彻的路线、方针、规范和措施的总称。执政党的政策最具影响力，与国家政权的联系最为密切。下面重点分析执政党政策与法的关系。

执政党政策与法作为社会调整的两种基本形式，它们之间不仅有着内在的一致性，也有着明显的区别，又都有各自不可替代的作用。法与执政党政策的一致性主要表现在：它们都产生并服务于社会的经济基础，都体现着一定阶级的意志和要求，它们的基本指导思想和价值取向是一致的，它们所追求的社会目的从根本上说也是一致的。法与执政党政策的区别主要表现在：意志属性不同、表现形式不同、实施的途径和保障方式不同、稳定性程度和程序化程度不同。

►中国社会主义法与中国共产党政策的关系

【分析】中国共产党的政策与社会主义法在本质上具有一致性，但在外部形式和调整方式上具有不同特点。首先，党的政策是社会主义法的核心内容；其次，社会主义法是贯彻党的政策，完善和加强党的领导的不可或缺的基本手段；最后，党的政策充分发挥作用，能够保障、促进社会主义法的实现。正确认识社会主义法与党的政策的关系，既不能把二者割裂、对立起来，也不能把二者简单等同。

具体而言，中国社会主义法体现为以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，是在中国共产党领导下制定和不断完善的，是通过将党的政策转化为法律的方式形成和发展起来的庞大体系。党领导人民制定宪法法律，也领导人民实施宪法法律，党自身必须在宪法法律范围内活动。宪法和法律的实施，也是保障党的基本路线方针政策得以贯彻落实的重要途径。

第四节 法与文化

一、法律意识与法律文化

►法律意识的概念

【分析】法律意识是法律文化的重要组成部分。它是社会意识的一种特殊形式，是人们关于法律的思想、观念、知识、心理的总称，包括对法律本质、作用的想法，对现行法律的态度和评价，以及对人们行为的法律评价等。

法律意识是社会主体在法律实践活动中所形成的主观体验和认识在意识中的反映，是对法律现象本身的价值作出的主观价值判断。法律意识涉及的对象是法律现象，这是法律意识与其他社会意识相互区别的主要特点。虽然政治意识、道德意识以及其他社会意识有时也涉及法律现象，但它们都不以法律现象为专门的对象。法律意识与其他社会意识相比，具有较强的强制性，对人们的行为具有明确的指令性，它对社会生活的法律要求或法律调整的反映比较及时、敏感；而其他社会意识对人们的行为和社会的影响，常常是通过思想指导、情感熏陶、心理感召、习俗的维护等方式潜移默化地起作用，对社会生活的法律要求作用缓慢而持久。在法律文化观念中，法律意识居于核心地位。

►法律意识的分类

【分析】法律意识可以按照不同的标准进行分类。

依据法律意识主体的不同，可以将法律意识分为个人法律意识、群体法律意识和社会法律意识。个人法律意识是具体的个人对法律现象的思想、看法、意见和情趣，它是个人独特的社会地位和社会经历的反映。群体法律意识是指家庭、集体、团体、阶级、阶层、民族、政党等不同的社会集合体对法律现象的意识。这种法律意识最为复杂。社会法律意识是指社会作为一个整体对法律现象的意识，是一个社会中个人法律意识、各种群体法律意识相互交融的产物，因此这种法律意识往往是对一个国家法制状况的总的反映。

依据法律意识的专门化、职业化的不同程度，可以将法律意识分为职业法律意识与非职业法律意识。职业法律意识是指法官、检察官、律师、法学研究与教学人员等专门法律工作者的法律意识。非职业法律意识是广大人民群众对法律现象的最一般的理解。

从认知阶段来看，法律意识可以分为低级阶段的法律心理和高级阶段的法律思想体系。法律心理是人们在日常生活中形成的关于法律的零星的感觉、情绪、习性等。法律思想体系是对法律思想观点的理论概括，是思想化、理论化、系统化的法律意识，是法律意识的高级阶段。法律心理和法律思想体系是法律意识两个不可分割的组成部分，两者是相互影响和相互转化的。

从法律意识的社会政治属性角度，可以将法律意识分为占统治地位的法律意识与不占统治地位的法律意识。占统治地位的法律意识与不占统治地位的法律意识对于社会经济制度和法律制度有着不同的作用，一般来说，前者的作用是正面的、积极的，后者的作用是负面的、消极的和破坏性的。

►法律意识的作用

【分析】法律意识在很大程度上制约和影响法律实践活动。就占统治地位的法律意识而言，它既渗透到法的制定和实施中，成为法律调整全过程时刻不可脱离的因素，又可独立于法律调整，发挥社会意识形态所固

有的思想教育作用，灌输国家的法律意识形态、价值观，普及法律知识、文化，为实现法律调整、实行法治创造良好的思想、心理条件。

任何社会的法律实践都是在特定的社会条件下进行的，因而不可避免地要受到该社会法律文化观念以及法律意识的制约和影响。在法律的创制过程中，立法者的法律意识直接影响着法律创制活动的效果。如果立法者能正确认识和反映一定社会关系的客观要求，有效地进行创制法律的活动，那么这样的法律就会促进经济的发展和社会的进步。在法律适用的过程中，司法人员法律意识的水准对于适用法律的活动以及案件的审判影响很大。它直接关系到司法人员能否准确理解法律规范的精神实质，能否合法、公正地审理案件，能否有效地维护国家利益和公民权利。此外，法律实践还是一个生动现实的过程，在一个急剧变化的社会里，随着从传统社会向现代社会的转型，法律也必然要发生变化。在这种情况下，新的法律意识往往会成为社会变革的推动力量。

►法律文化的概念

【分析】法律文化是一种特殊的文化现象。法律文化一般是指在一定社会物质生活条件的作用下，掌握国家政权的统治阶级所创制的法律规范、法律制度或者人们关于法律现象的态度、价值、信念、心理、感情、习惯以及学说理论的复合有机体。法律文化由两个层面组成，其一是物质性的法律文化，诸如法律制度、法律规范等，即制度形态的法律文化；其二是精神性的法律文化，诸如法律学说、法律心理、法律习惯等，即观念形态的法律文化。

法律文化与现行法、法律实践、法律意识等法律现实有着密切的联系。法律文化的载体是法律现实，法律文化蕴涵其中。但是法律文化并不等于现行法、法律实践以及法律意识，也并非简单地等同于这些法律现象的总和。法律文化是这些法律现象中所包含的知识、智慧和经验，是其中一切有价值的、流传久远的行为方式或思想方式，是一种文化传统。它是一个国家、地区和民族从事法律活动的过程中长期起作用的“定式”，是一种习惯。法律文化不包括现行法、法律实践、法律意识中一切因偶然因素、个别事件而变化的成分。

在不同的国家和不同的历史发展阶段，法律文化会有很大的差异。法律文化作为一个整体，一方面受到经济基础的制约，反映社会发展的客观需要和统治阶级的意志，具有阶级性；另一方面又具有相对独立性，它是一个民族长期积累起来的通过法律调整社会关系、进行社会管理的智慧、知识和经验的结晶，反映了历史上形成的有价值的法律思想和法律技术，反映了一个民族法律调整所达到的水平，具有民族性。法律文化的多样性使法律文化的交流与传播成为可能。随着社会的历史演进，法律文化的交流与融合日益增进。在这一过程中，不同类型的法律文化之间不可避免地要发生矛盾和冲突。因此，冲突与融合是法律文化变迁与发展的一条基本规律。

►当代中国的法律文化

【分析】当代中国的法律文化受到多种法律文化的影响，主要包括：中国传统的法律文化、西方法律文化、苏联的法律文化以及我国社会主义建设过程中所形成的法律文化。这些法律文化在不同的历史时期、不同的条件下对不同的社会阶层发挥着不同的影响。总的来讲，在我国社会主义法治实践基础上形成的法律文化对整个社会的影响更大，而中国传统法律文化则在其中发挥着潜在的作用。在传统法律文化、外来法律文化和中国当代法治实践基础上形成的法律文化中，既包含着有利于社会主义现代化建设的成分，也包含着不利于其发展的因素，对它们应当采取一分为二的态度。对我国社会主义法律文化现代化的研究，一方面要立足中国，注重总结自己的实践经验，保持自己的优秀法律传统；另一方面要把中国的法律文化放到世界法律文化的整体中去观察和研究，注重从外国法律文化中吸取经验和教训。

►弘扬社会主义法治精神、建设社会主义法治文化

【分析】党的十八届四中全会《决定》指出：“必须弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，增强全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围，使全体人民都成为社会主义法治的

忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。”历史发展表明，只有法律成为人们自觉遵守的规则，内化于心、外化于行，法的意义、法的精神才能真正展现出来，法治的理想才能最终落地。因此，在全面推进依法治国的过程中，“全民守法”对于弘扬法治精神和法治文化具有特殊重要的意义。

要达到“全民守法”的目标，必须以法治政府的建立促进法治社会的发育，以司法的严谨、执法的严格来培育公民守法的自觉性。这就要求我们，一方面要加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府；另一方面要充分发挥司法公正对于社会公正的引领作用，并在此基础上，推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，健全依法维权和化解纠纷机制、利益表达机制、协商沟通机制、救济救助机制，畅通群众利益协调、权益保障法律渠道。只有让人民群众在每一件具体的司法案件中建立对法治的信心、在日常工作生活中感受到法律的权威，他们对法律的态度才能由认识到遵守，由信任到信仰。

推动社会主义法治文化和法治精神建设，还离不开类型多样的法治宣传与教育。从20世纪80年代至今，我国已经完成了以全体公民为教育对象的多个“法治宣传教育五年规划”，普法内涵不断丰富、领域不断拓宽，已经成为推进依法治国、建设社会主义法治国家的一项重要基础性工作。同时，将法治教育纳入正式的国民教育系列也是必不可少的重要举措。

二、法与道德

► 法与道德的区别

【分析】道德是人们在社会生活中形成的关于善与恶、好与坏、美与丑、正义与非正义、公正与偏私、诚实与虚伪等伦理观念、思想、原则、标准的总和。法与道德之间具有密切联系，二者相互影响，相互渗透，相互作用。同时，作为社会上层建筑的不同部分，法与道德又有显著的区别：

第一，产生方式不同。法一般是通过特定的机构、程序、方式而形成，依赖团体公共权力而实现。法律是自觉的、有形的。道德随人的自然生活而逐渐产生，依赖教育培养而积累长成。道德是自发的，有时是无形的，一般不通过专门的公共机关和人员来制定，也不一定要通过专门的组织和制度来实现。在时间上，道德具有先在性，它的产生早于法律，是法律的产生、形成、发展、运作和实现的基础。

第二，表现形式不同。法作为一种规范形式，是由国家制定、认可和解释的，具有普遍性、规范性、确定性、一般性的特点，通常是以成文方式表现出来，它的存在形式主要为法典、单行法规、判例、条例、条约等规范性文件。道德则不同，它主要体现在人们的意识、信念和心理之中，通过人们的言论、行为、内心信念、社会舆论、风俗习惯等形式表现出来。道德规范出于人们社会生活的日积月累、约定俗成，无须经过某个专门的国家机关制定、认可和解释，它的运作、功能的发挥也不必通过一定的程序或某个行政命令而实现。

第三，实现方式不同。法和道德作为人们的行为准则，都具有一定的约束性和强制性。然而两者在约束性和强制性的方式与程度方面有极大的差别。法具有较强的约束性，具有国家的强制性，它往往以国家的强制力为坚强后盾，依靠强制手段来加以推行和实施，法主要是一种外在强制力。道德对人的行为的界定十分模糊，一般只对人提出做或不做一定行为的倾向性要求，没有设定明确的行为模式，它本身所具有的约束性、强制性也没有法那样严厉和显著。它的实施、实现也不是依靠国家的强制力，而主要是依靠社会舆论、社会评价的力量，依靠人们的内心信念、内在修养、传统、风俗习惯和社会教育的力量来维持，诉诸人的心理，通过人们的内在的自觉而进行的，道德是一种内在强制力。

第四，调整范围不完全相同。法所调整的范围主要是人的行为，与建立和维护正常的社会秩序息息相关的人的行为和社会关系。道德所调整的范围远比法律广泛得多，它几乎涉及人们在社会生产、生活、交往中的一切领域、一切活动、一切人际关系，涉及人的外在行为和内在思想、动机。法所调整的绝大部分对象，同样也可以用道德来调整，而道德所调整的对象不一定可以通过法律来调整。

第五，评价的尺度不同。法评价人的行为的标准和尺度是合法与不合法，有效与无效。只要人的行为符合法律、法律规范的规定，就是有效的和合法的。道德评价人的行为的尺度和标准主要是一定社会的价值观念体系，是一定社会、一定人群集合体的善恶观、公正观、是非观、荣辱观、美丑观。人们的行为只要符合一定的道德观念、道德价值，就是正当的和合理的。因此，法的标准与道德的标准具有一定的差别，法律标准远比道德标准明确和规范。

第六，权利义务的特点不同。道德和法都是以权利和义务为内容的，都是通过权利和义务的配置而实现社会调控的。但法主要是以权利为本位，道德主要是以义务为主体。法的权利和义务是法定的，是以法为根据和基础的，是法律化、制度化、规范化的权利和义务，在社会中主要体现为一种实在形态，具有确定性、可预测性的特征。道德的权利和义务具有应然性，是一种应有的权利和义务，在社会中主要体现为观念形态、理想形态。

► 法与道德的联系

【分析】道德是法的基础和评价标准，主要表现在以下几个方面：

第一，道德是法的理论基础。道德理论、理念、观点、学说是法律理论、理念、观点、学说产生、形成和发展的前提，没有道德理念、思想的更新和发展，没有道德理念、原则、信条不断地转化为法律理念、原则、规定和规范，就没有法律理论、法律规定、法律制度的更新和发展，就不可能形成法律大厦的坚实地基。

第二，道德是法的价值基础。道德是衡量良法与恶法的标准，是引导人们进行法律制度、法律秩序建设和改革的指针。没有道德及价值观念体系作为基础，法就缺乏内在支柱，它的合法性将最终失去。

第三，道德是法运作的社会基础。法的权威、力量、合法性的发挥和实现是建立在道德这一基石之上的。法治的形成和实现都离不开道德信念的支持，人们的道德水平越高，守法的程度也越高，选择法所认可的合法行为的程度也越高。在具体的法律运作过程中，人们的道德信念和道德水平的高低，特别是法官、律师、检察官、警察的道德信念、原则、水平的状态，直接影响法的实施和实现。

第四，道德是弥补法律漏洞的基础。任何一个社会的法都存在某种程度的不足，通过道德这种社会控制方式，通过建立良好的道德秩序，协调、引导、调整 and 评价人们的行为，可以弥补法的漏洞。

法是传播道德、保障道德实施的有效手段。主要表现在以下三个方面：

第一，通过立法，将社会中的道德理念、信念、基本原则和基本要求法律化、制度化、规范化，赋予社会的道德价值观念以法的强制力，进一步强化、维护、实现道德规范。法的强制性和强制力远比道德的强制性和强制力更为有力，它能够有效地促使人们自觉地遵守道德的信念、原则和要求，从而在更大、更广的范围内维护社会秩序，促进、保障和维护人们的正当生活。通过道德法律化的形式和方式，社会规范真正实现了自律与他律的结合。

第二，法是道德的承载者，它弘扬、发展一定社会的道德理念、信条和原则，促进社会道德的更新和变革。在社会中，许多法律规定本身就是最低的基本的道德要求，比如“法律面前人人平等”“诚实信用”等原则就是道德中的平等性、诚实性的表现和升华。法律通过把道德理念、原则、信条和要求具体化，把社会中的道德准则、义务和要求确定为法的准则、义务和要求，促使人们更明确自己的道德义务，更为积极地认同和接受道德的制约。

第三，法是形成新的道德风貌、新的精神文明的强大力量。一个社会通过法律形式，把适合社会生活需要的道德法律化、制度化、规范化，使之成为法律规范，这实际上确立和形成了一个法定的基本道德体系和标准，促进和改善了社会的精神风貌。法通过自身特殊的制度性机制，推动道德的更新与进步，促进精神文明的发展，从而改造人和人性，改造社会，这是其积极的社会使命和功能。

总之，法与道德是人类生存的两大支柱，人类社会和文明要求法与道德并举并重，相互配合，相互协调。

只有法与道德互助共生，才能真正形成和保持和谐稳定的社会秩序。

►法与道德的冲突与解决

【分析】在多元化的社会规范体系中，道德与法是社会关系调控的根本规范，但是这两种基本的社会规范并不总是协调一致的，而是时常处于相互冲突之中。

法与道德在日常法律适用中的冲突主要表现为情理与法理上的冲突，主要表现为“合法不合理”与“合理不合法”两种情况。第一种情况是道德上不许可，但法律上是许可的。例如，根据法律上关于民事权利诉讼时效的规定，债权超过法定诉讼时效后，债权人就丧失了诉讼上的胜诉权，法律不再支持和保护其债权。但在道德上，“欠债还钱”是天经地义的道德义务。这就出现了“合法不合理”的冲突。第二种情况是道德上许可，但法律上不许可。比如，关于安乐死的问题。从安乐死本身来说，它是符合人道主义的。但因为安乐死操作难等原因，我国法律对它仍持禁止态度。此外，还有大义灭亲而获罪等也存在着道德与法律的碰撞。道德与法相冲突往往出现两种结果：一是没有坚实社会基础的法律在道德面前必须修改或崩溃，适应道德的新法律产生；二是在法律的影响下，一些旧道德退出历史舞台，形成与法律相适应的新道德。解决法律与道德在日常法律适用领域中冲突的措施主要有：提高立法质量，尽量避免出现法律的漏洞，要最大限度地减少法律与道德进行不必要碰撞的概率。同时在宣传法律过程中，对旧道德进行批判，使道德与法律尽量吻合。

►社会主义法与社会主义道德的关系

【分析】作为上层建筑重要组成部分的社会主义法与社会主义道德之间具有极为密切的联系，二者相互渗透，相互作用，相互促进。

社会主义道德对社会主义法的作用主要表现在：

第一，社会主义道德是社会主义法制定的价值指导。社会主义法的创制以道德为指导，体现了法的合理性、正义性。社会主义道德通过对社会关系和人的行为的正义与非正义的衡量，把它转换为法律上的权利和义务，把合理与否转换为合法与否，构成权利义务关系。如果社会主义立法不以道德为指导，将失去其合理性。另外，社会主义立法以道德为指导，不能脱离社会现实的道德基础，要受实际道德水平的制约。

第二，社会主义道德对法的实施的促进作用。社会主义法的实施需要国家强制力的保证，也需要社会主义道德的驱动。良好的道德状况有助于法的更有效实现。执法人员执行法律，运用国家强制力，既依靠法律制度的保证，也要有执法人员内在素质的保证，包括道德素质因素。执法人员具有高度的职业道德，公正无私，刚直不阿，有助于正确合法地执行法律。法律遵守要依靠人民群众的舆论道义支持。道德觉悟的提高是顺利实施法律的重要条件，否则将助长对法律的机会主义态度。社会道德风尚会提高维护社会主义法的自觉性和积极性。

第三，社会主义道德可以弥补社会主义法在调整社会关系方面的不足。由于法本身存在一定的局限性，对法律不宜调整的社会关系，可以由社会主义道德加以调整。

社会主义法对社会主义道德建设的作用主要表现在：

第一，社会主义法以法律规范的形式把社会主义道德的某些原则和要求加以确认，使之具有法的属性。我国宪法和有关法律的规定，公民在行使权利的时候，不得侵害国家、集体和他人的合法权益，体现了集体主义精神。我国公务员法规定国家公职人员必须全心全意为人民服务；《民法典》规定民事活动应当遵循自愿、公平、等价、有偿、诚实信用等原则，并规定父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的义务，禁止家庭成员间的虐待和遗弃等。这些都是社会主义法对道德的确认。

第二，社会主义法是进行社会主义道德教育的重要方式。由于社会主义法的规范深刻体现了社会主义道德的基本精神和要求，所以通过法律教育和法律实施活动，可以促进社会主义道德，提高人们的道德素质。一般来说，凡是法律所禁止的行为通常也是社会主义道德所谴责的行为，法律所鼓励的行为也是社会主义道德所要求的行为。通过对违法犯罪行为的处理，不仅使人们看到什么行为是法律禁止的，而且也使人们认识到什么行

为是道德所谴责的。通过对合法行为的保护和奖励，表扬先进、树立榜样，培养人们的道德观念。

总之，社会主义道德是法律的评价标准和推动力量，社会主义法是传播社会主义道德、保障道德要求实现的有效手段。社会主义核心价值观是当代中国社会主义道德原则的集中体现，它既是社会主义法律制定的价值指导，也对社会主义法的实施具有促进作用。社会主义道德还可以弥补社会主义法在调整社会关系方面的不足。社会主义法以法律规范的形式把社会主义道德的某些原则和要求加以确认，使之具有法的属性。社会主义法是传播社会主义道德和进行社会主义道德教育的重要方式。

三、法与宗教

►宗教的含义

【分析】与法律、道德、习惯等一样，宗教也是一种社会现象，它包括人们对于超自然、超社会的力—“神灵”的信仰以及祭祀规范、仪式和活动等内容。恩格斯说，一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。

在历史上，宗教和法律是两种有着密切联系的社会现象。当代世界各国，特别是发达国家，大多实行政教分离的制度，反对宗教干预国家事务，并把这一点作为文明社会的一个标志。宗教规范由宗教团体制定，只对其成员有约束力，它是社会团体规范的一种；而法律规范则是由国家颁布的，对所有人，无论是否教徒，无论信奉何种宗教，都有约束力。

►法与宗教的联系与区别

【分析】法与宗教的联系，表现在精神、规则、组织结构三个层面上。但是，在不同民族以及不同历史发展阶段中，这种联系又各有不同。概括地说，在政教合一的国家中，宗教与法在精神、规则和组织结构三个层面都是融为一体的。在精神层面，宗教的精神就是法的精神，法贯穿着宗教精神，法的正当性、行为的正当性均从宗教教义的基本精神来解释；在规则层面，宗教规范即是法律规范，不仅调整和管理宗教事务，也同时调整和管理世俗事务；在组织结构层面，有时宗教领袖亦即国家的领袖，不过，更多的情况是世俗国家的领袖从属于宗教，其世俗统治权来源于宗教(国王即位由宗教领袖加冕或授予权杖，是国王被授予世俗统治权的形式)。同时，宗教的神职人员也是法律的实施者。欧洲中世纪基督教国家，历史上及现代一些伊斯兰教国家，都曾经出现和存在这类情况。

在现代国家，普遍实行政教分离的制度。在政教分离的条件下，国家不得确立或禁止某个宗教，国家行为与宗教分离，宗教不得干预国家活动，不得干预国家设立的各项制度。公民有宗教信仰自由，宗教组织管理宗教事务，宗教活动在社会公共领域须遵守国家的法律。但在实际上，由于宗教在历史上有长期的影响，特别是它作为一种文化现象，与一个民族的文化积淀是有紧密联系的，因此，即使在一些实行政教分离的现代西方国家中，宗教的精神和社会活动方式对法仍存在着比较深刻的影响。

宗教也是一种社会规范，与法律规范的区别在于：(1)产生方式不同。宗教规范是宗教创始人和领袖借助神的名义规定的。(2)实施方式不同。宗教规范主要通过信仰机制，依靠自愿行为。(3)适用原则不同。宗教规范以属人主义原则为标准，只对教徒具有约束力，不同于法律的属地主义和属人主义相结合的原则。

►我国法律在处理宗教问题中的作用

【分析】在对待宗教的态度上，我国社会主义法不是运用行政命令的办法强制消灭宗教，不允许人们有宗教信仰，而是贯彻“宗教信仰自由”的原则。我国《宪法》第36条规定：“中华人民共和国公民有宗教信仰自由。任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。国家保护正常的宗教活动。”我国《刑法》第251条规定：“国家机关工作人员非法剥夺公民的宗教信仰自由和侵犯少数民族风俗习惯，情节严重的，处二以下有期徒刑或者拘役。”

我国法律为什么一方面提倡唯物主义、反对唯心主义，另一方面又要贯彻宗教信仰自由的原则?这是由于：第一，宗教信仰属于思想领域的问题，对待思想问题，采用简单的强制办法是不能奏效的。第二，宗教具有群众基础和民族性。我国是多民族的国家，宗教问题往往同民族问题相联系。宗教问题处理不好，就会伤害民族感情，影响民族团结。第三，实践证明，奉行宗教信仰自由的政策，不但不会削弱社会主义制度和共产党领导，而且有利于社会安定团结；反之，在宗教信仰问题上处理得不好，就会激化社会矛盾，不利于社会主义制度的巩固。第四，宗教信仰不仅是宗教问题，而且是文化问题，如伊斯兰教和基督教，其形成和发展就直接与东方文化、阿拉伯文化和西方文化紧密联系在一起。贯彻宗教信仰自由的原则有利于我们建立最广泛的统一战线，反之，不学会与不同文化、不同宗教信仰的人们和平共处，互相尊重，只能使我们在国际关系中处于不利地位。

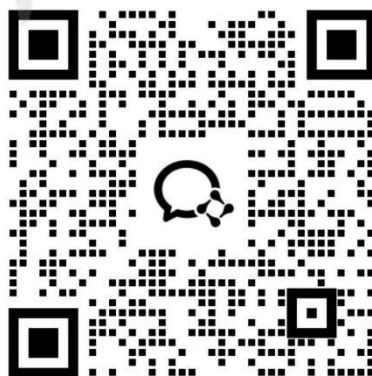
宗教信仰自由的内容包括：每个公民既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由；有信仰这种宗教的自由，也有信仰那种宗教的自由；有过去不信教现在信教的自由，也有过去信教现在不信教的自由；在同一宗教内，有信仰这个教派的自由，也有信仰那个教派的自由。总之，不论信教或者不信教，也不论信什么教，公民自己完全有自由。任何国家机关、社会团体和个人，都不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。我国宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

坚持宗教信仰自由的原则，必须坚决反对邪教。宗教有合法的组织，有正式的教义、教规，有固定的活动场所和仪式。而邪教是指冒用宗教、气功或者其他名义建立，神化、鼓吹首要分子，利用制造、散布迷信邪说等手段蛊惑、蒙骗他人，发展、控制成员，危害社会的非法组织。邪教活动不是宗教信仰自由，而是破坏国家法律的行为。

总之，贯彻宗教信仰自由的原则，依法加强对宗教事务的管理，目的在于引导宗教与社会主义社会相适应。宗教是一种历史现象，在社会主义社会中将长期存在。要改革不适应社会主义的宗教制度和教条，利用宗教教义、教规和宗教道德中的某些积极因素为社会主义服务。只有社会主义才能救中国和发展中国，这是全体中国人民的共识，也是宗教能够与社会主义社会相适应的政治基础。

扫码加微，获取更多免费资料



扫描二维码，添加企业成员进行联系